

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



# БИЛТЕН



Ниш, 2018. године



**АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ**

# **БИЛТЕН**



Pravna i ekonomska izdanja  
za uspešno i zakonito poslovanje

---

Ниш, 2018. године

# БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

**ПРИРЕЂИВАЧ:** Апелациони суд Ниш

**За приређивача:** Драган Јоцић, председник суда

**ИЗДАВАЧ:** Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

**За издавача:**

**ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:** Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

**ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА:** Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

**РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР:** Драган Јоцић, председник суда,  
Зоран Поповић, Снежана Милошевић,  
Гордана Павловић, Данијела Николић,  
Марина Милановић, Ружица Јовановић,  
судије Апелационог суда

**СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ:** Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

**РЕДАКЦИЈСКА ПРИПРЕМА СЕНТЕНЦИ:** Мирјана Милутиновић и Јелена Додић, судијски помоћници Апелационог суда у Нишу

**ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА И ДИЗАЈН:** Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

**ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОМОТА:** Наталија Стојановић

**ШТАМПАРИЈА:** Београф, Нова Пазова

CIP - Каталогизација у публикацији  
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.11)

БИЛТЕН/Апелациони суду Нишу; главни одговорни уредник Драган Јоцић. - 2010, бр. 1- . - Нови Сад : Paragraf Lex, 2010- (Нова Пазова : Београф). - 21 cm

Два до четири пута годишње.

ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу  
COBISS.SR-ID 179852044

---

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика). Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

---

## Садржај

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ .....                 | 5  |
| РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ ..... | 9  |
| Деветомесечни извештај 2018.године .....      | 19 |

### **КРИВИЧНО ПРАВО**

#### **ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА .....23**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| COURT OF APPEAL AND LEGALITY OF THE SOLUTIONS<br>TO CRIMINAL MATTERS ..... | 56 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|

### **ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА .....73**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА ..... | 75 |
|-----------------------------------|----|

### **КРИВИЧНО ПРАВО**

#### **СУДСКА ПРАКСА .....85**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО ..... | 87 |
| КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО .....    | 90 |

## **ГРАЂАНСКО ПРАВО ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА .....103**

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПРЕТХОДНОГ ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА У<br>КОНТЕКСТУ ПРАВА НА ДЕЛОТВОРАН ПРИСТУП ПРАВДИ..... | 105 |
| МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР ЗАБРАНЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ.....                                                   | 125 |
| СУДСКА МЕДИЈАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ .....                                                                | 140 |
| JUDICIAL MEDIATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA .....                                                        | 157 |
| О ПРИМЕНИ РАСПРАВНОГ НАЧЕЛА И ПРАВИЛА О ТЕРЕТУ<br>ДОКАЗИВАЊА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ .....                   | 158 |

## **ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА .....175**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА ..... | 177 |
|-----------------------------------|-----|

## **ГРАЂАНСКО ПРАВО СУДСКА ПРАКСА .....181**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ПРОЦЕСНО ПРАВО .....    | 183 |
| ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО ..... | 191 |
| СТВАРНО ПРАВО .....     | 201 |
| РАДНО ПРАВО .....       | 205 |

## **КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ**

### **МОДЕЛ ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА – СУДИЈА**

#### **I ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ**

##### **АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ**

- Обезбеђује ефикасан тимски рад у пријатној радној атмосфери.
- Ефикасно управља предметима: делотворно утврђује приоритете, избегава непотребна одлагања у поступку
- Ангажује се на професионалном развоју и усавршавању других : активно учествује у развијању компетенција сарадника, помоћника и особља
- Конструктивно сарађује са другима, нарочито са припадницима других професија, подстичући сарадњу и заједнички рад

##### **ЛИЧНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ**

- Сагледава разноликост друштвеног окружења у којем суд функционише
- Поступа са другима са поштовањем и обзиром, правично и без предрасуда и дискриминације по било ком основу
- Поступа у складу са Етичким кодексом
- Поступа у складу са начелима независности и интегритета
- Показује смиреност и ауторитет у захтевним и непријатним ситуацијама
- Саопштава материјално-правне и процесне информације на одговарајући начин, једноставно и лако разумљивим језиком

## ПРАВНОТЕХНИЧКЕ

- Суди ефикасно и делотворно
- Управља поступком на непристрасан и објективан начин
- Предузима неопходне припремне радње у поступку и сагледава различита процесна решења
- У стању је да ради брзо и под притиском
- У стању је да брзо и делотворно усвоји и анализира велики број информација, чињеница и правних аргумената
- Доноси јасно образложене одлуке

## II ЗНАЊЕ

### ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА

- Поседује висок ниво познавања материјалног и процесног права и начелима на којима оно почива
- Стално тежи да ажурира, унапреди и прошири своје знање, у контексту друштвених и економских промена
- Редовно прати развој у судској пракси релевантних судова, као што су Врховни касациони суд, Уставни суд, Европски суд за људска права, Европски суд правде и слично

### ПОЗНАВАЊЕ ВАНПРАВНИХ ОБЛАСТИ

- Поседује способност да делотворно користи различите изворе информација, укључујући и електронске базе података
- Користи информационе и комуникационе технологије у свакодневном раду
- Активно тежи стицању, развијању и унапређењу знања из ванправних области као што су медицина, економија, форензика, информационо-комуникационе технологије и слично







## РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. Закона о уређењу судова и члана 46-48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује Распоред послова судија Апелационог суда у Нишу за 2018. годину.

### СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи **Драган Јоцић**, председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије: **Снежана Милошевић** и **Соња Симоновић Стојановић**.

За руководиоца службе председника суда одређује се **Јелена Јанчетовић**, секретар суда.

### СУДСКА ОДЕЉЕЊА И УРЕДНИК БИЛТЕНА

За председнике судских одељења одређују се:

1. У **Одељењу судске праксе**: председник суда Драган Јоцић, а заменик судија Зоран Поповић.
2. У **Кривичном одељењу**: председник, судија Зоран Поповић, а заменик Слободан Стојилковић.
3. У **Грађанском одељењу**: председник, судија Данијела Николић, а заменик Добрила Здравковић.
4. У **Одељењу радних спорова** : председник, судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић.

Главни и одговорни уредник билтена судске праксе је председник суда Драган Јоцић, а заменик главног и одговорног уредника судија Зоран Поповић

## **КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ**

### ***I – ВЕЋЕ***

1. Љиљана Миљковић, председник већа
2. Весна Стевановић, члан

### ***II – ВЕЋЕ***

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Стојилковић, члан
3. Дијана Јанковић, члан

### ***III – ВЕЋЕ***

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Ранко Банковић, члан
3. Јасмина Јововић, члан

### ***IV – ВЕЋЕ***

1. Гордана Павловић, председник већа
2. Горана Митић, члан
3. Иван Булатовић, члан

### ***V – ВЕЋЕ***

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
2. Драгана Живадиновић, члан
3. Саша Бошковић, члан

**Већа која поступају по жалбама против одлука Апелационог суда  
(Кж-3 предметима)**

### ***I – ВЕЋЕ***

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Горана Митић, члан
3. Мирјана Ђорђевић, члан

## ***II – ВЕЋЕ***

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Драгана Живадиновић, члан
3. Гордана Павловић, члан

### **Веће за поступање по старим предметима**

1. Драган Јоцић, председник већа
  2. Снежана Милошевић, члан
  3. Слободан Стојилковић, члан
  4. Данијела Николић, члан
  5. Ивана Рађеновић, члан
- Члана овог већа чини и судија који реферише старе предмете.

## **ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ**

### ***I – ВЕЋЕ***

1. Марина Ђукић, председник већа
2. Невена Благојевић, члан
3. Драган Крстић, члан

### ***II – ВЕЋЕ***

1. Данијела Николић, председник већа
2. Снежана Лазић, члан
3. Милица Златковић, члан

### ***III – ВЕЋЕ***

1. Марина Милановић, председник већа
2. Стојанка Вујошевић, члан
3. Никола Пржић, члан

***IV – ВЕЋЕ***

1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
2. Зорица Стошић, члан
3. Јадранка Митровски, члан
4. Оливера Јовановић, члан

***V – ВЕЋЕ***

1. Добрила Здравковић, председник већа
2. Снежана Тодоровић, члан
3. Зоран Стаменковић, члан

**ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА**

***I – ВЕЋЕ***

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Ружица Јовановић, члан
3. Зорица Цветковић, члан
4. Ђорђе Гојгић, члан

***II – ВЕЋЕ***

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Љубиша Милојевић, члан
3. Данијела Божовић, члан
4. Ксенија Џомбић, члан

***III – ВЕЋЕ***

1. Тања Ристић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Лидија Стошић, члан

### **ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ**

1. Драган Јоцић, председник суда, руководилац судске праксе суда
2. Зоран Поповић, његов заменик
3. Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Снежана Милошевић
4. Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Зорица Стошић
5. Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић
6. Судијски помоћник Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судијски помоћник Миљана Радовановић
7. Судијски помоћници Златица Петровић, Миљана Поповић Ђурић и Ивана Ђурђић Митровић у Грађанском одељењу и Одељењу радних спорова. Судијски помоћници Слађана Љубеновић и Слађанка Тасић, услед одсутности или спречености судијског помоћника распоређеног у судској пракси или због повећаног обима посла радиће у судској пракси.

### **ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ**

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

#### ***У предметима из области Грађанског права***

1. Марина Милановић, председник већа
2. Стојанка Вујошевић, члан
3. Никола Пржић, члан

***У предметима из области Радних спорова***

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Ружица Јовановић, члан
3. Зорица Цветковић, члан

***У предметима из области Кривичне материје***

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Стојилковић, члан
3. Дијана Јанковић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списка предмета у којем је ово право повређено.

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ  
ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА**

***I – ВЕЋЕ***

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Ксенија Џомбић, члан

***II – ВЕЋЕ***

1. Тања Ристић, председник већа
2. Данијела Николић, члан
3. Добрила Здравковић, члан



## **РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. и члана 53. став 2. Закона о уређењу судова и члана 48. став 1. Судског пословника, утврђује Распоред послова судијских помоћника Апелационог суда у Нишу за 2017. годину.

### **Судска управа**

- Јелена Јанчетовић - секретар суда

### **Одељење судске праксе**

- Златица Петровић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за грађанску материју
- Ивана Ђурђић Митровић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за грађанску материју
- Миљана Поповић Ђурић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за грађанску материју
- Слађанка Тасић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за радну материју
- Слађана Љубеновић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за грађанску материју
- Милан Ђорђевић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за кривичну материју
- Миљана Радовановић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за кривичну материју

### **Кривично одељење**

### ***И ВЕЋЕ***

- Ивана Лазовић
- Никола Насковић

## ***II ВЕЋЕ***

- Марија Петровић
- Милан Жикић

## ***III ВЕЋЕ***

- Иван Калезић
- Миљана радовановић

## ***IV ВЕЋЕ***

- Милица Алексић
- Миодраг Перуновић
- Марија Димитријевић

## ***V ВЕЋЕ***

- Зоран Ђурђевић
- Јелена Додић

## **Грађанско одељење**

### ***I ВЕЋЕ***

- Милена Миловановић
- Јасмина Кузмановић
- Марија Фехир

### ***II ВЕЋЕ***

- Бети Лазаревић
- Сања Антић Милановић
- Јелена Голубовић
- Иван Васиљковић

### ***III ВЕЋЕ***

- Сандра Стефановић
- Слађана Љубеновић
- Тијана Митровић

### ***IV ВЕЋЕ***

- Мирјана Милутиновић
- Оливера Алексић Цветковић
- Ивана Стевановић

### **Одељење радних спорова**

#### ***I ВЕЋЕ***

- Слађанка Тасић
- Наташа Митковић
- Горан Драгомански

#### ***II ВЕЋЕ***

- Ивана Д. Младеновић
- Дамјан Мирчић
- Александар Коцић

#### ***III ВЕЋЕ***

- Весна Јовановић Јанковић
- Драгана Вељковић
- Ивана Г. Младеновић



**Деветомесечни извештај 2018.године**  
**Упоредни приказ података за апелационе судове**

**ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ1”**

| АПЕЛАЦИОНИ<br>СУД | БРСУДИЈА У<br>ОДЕЉЕЊУ | НЕРЕШЕНО<br>НА ПОЧЕТКУ | ПРИМЉЕНО | УКУПНО<br>У РАДУ | РЕШЕНО | ПРОСЕЧНО<br>МЕСЕЧНО<br>РЕШЕНО ПО<br>СУДИЈИ | ОСТАЛО<br>НЕРЕШЕНО | СТАРИХ<br>ПРЕМА<br>ДАТУМУ<br>ПРИЈЕМА |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>НИШ</b>        | 14                    | 167                    | 761      | 928              | 734    | 8.74                                       | 194                | 23                                   |
| <b>НОВИ САД</b>   | 13                    | 160                    | 731      | 891              | 742    | 9.51                                       | 149                | 6                                    |
| <b>КРАГУЈЕВАЦ</b> | 15                    | 95                     | 850      | 945              | 797    | 8.86                                       | 148                | 5                                    |
| <b>БЕОГРАД</b>    | 27                    | 198                    | 771      | 969              | 726    | 4.48                                       | 243                | 20                                   |

**ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ2”**

| АПЕЛАЦИОНИ<br>СУД | БРСУДИЈА У<br>ОДЕЉЕЊУ | НЕРЕШЕНО<br>НА ПОЧЕТКУ | ПРИМЉЕНО | УКУПНО<br>У РАДУ | РЕШЕНО | ПРОСЕЧНО<br>МЕСЕЧНО<br>РЕШЕНО ПО<br>СУДИЈИ | ОСТАЛО<br>НЕРЕШЕНО | СТАРИХ<br>ПРЕМА<br>ДАТУМУ<br>ПРИЈЕМА |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>НИШ</b>        | 14                    | 3                      | 351      | 354              | 342    | 4.07                                       | 12                 | 0                                    |
| <b>НОВИ САД</b>   | 13                    | 17                     | 735      | 752              | 727    | 9.32                                       | 25                 | 0                                    |
| <b>КРАГУЈЕВАЦ</b> | 15                    |                        | 410      | 410              | 404    | 4.49                                       | 6                  | 0                                    |
| <b>БЕОГРАД</b>    | 27                    | 23                     | 979      | 1.002            | 974    | 6.01                                       | 28                 | 0                                    |

# ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

| АПЕЛАЦИОНИ СУД | БРСУДИНА У ОДЕЉЕЊУ | НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ | ПРИМЉЕНО | УКУПНО У РАДУ | РЕШЕНО | ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ | ОСТАЛО НЕРЕШЕНО | СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЕМА |
|----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| НИШ            | 11                 | 638                 | 3.495    | 4.133         | 2.945  | 44.62                             | 1.188           | 1                          |
| НОВИ САД       | 24                 | 1.018               | 2.190    | 3.208         | 2.390  | 16.6                              | 818             | 18                         |
| КРАГУЈЕВАЦ     | 16                 | 1.904               | 2.472    | 4.376         | 2.354  | 24.52                             | 2.022           | 193                        |
| БЕОГРАД        | 38                 | 3.971               | 3.965    | 7.936         | 4.339  | 19.03                             | 3.597           | 885                        |

# ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

| АПЕЛАЦИОНИ СУД | БРСУДИНА У ОДЕЉЕЊУ | НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ | ПРИМЉЕНО | УКУПНО У РАДУ | РЕШЕНО | ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ | ОСТАЛО НЕРЕШЕНО | СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЕМА |
|----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| НИШ            | 7                  | 874                 | 2.597    | 3.471         | 1.939  | 46.17                             | 1.532           | 131                        |
| НОВИ САД       | 10                 | 390                 | 1.720    | 2.110         | 1.795  | 29.92                             | 315             | 1                          |
| КРАГУЈЕВАЦ     | 12                 | 1.546               | 2.127    | 3.673         | 2.038  | 28.31                             | 1.635           | 47                         |
| БЕОГРАД        | 16                 | 2.766               | 2.765    | 5.531         | 2.496  | 26.00                             | 3.035           | 826                        |

# ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ2”

| АПЕЛАЦИОНИ СУД | БРСУДИНА У ОДЕЉЕЊУ | НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ | ПРИМЉЕНО | УКУПНО У РАДУ | РЕШЕНО | ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ | ОСТАЛО НЕРЕШЕНО | СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЕМА |
|----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| НИШ            | 11                 | 18                  | 291      | 309           | 261    | 3.95                              | 48              | 0                          |
| НОВИ САД       | 13                 | 41                  | 338      | 379           | 342    | 4.38                              | 37              | 0                          |
| КРАГУЈЕВАЦ     | 16                 | 22                  | 340      | 362           | 318    | 3.31                              | 44              | 0                          |
| БЕОГРАД        | 38                 | 77                  | 432      | 509           | 428    | 1.88                              | 81              | 0                          |

# ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

| АПЕЛАЦИОНИ СУД | БРОЈ СУДИЈА У СУДУ | НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ | ПРИМЉЕНО | УКУПНО У РАДУ | РЕШЕНО |
|----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------|--------|
| НИШ            | 32                 | 1.713               | 8.367    | 10.070        | 7.013  |
| НОВИ САД       | 47                 | 1.691               | 6.381    | 8.072         | 6.310  |
| КРАГУЈЕВАЦ     | 44                 | 3.674               | 6.881    | 10.555        | 6.547  |
| БЕОГРАД        | 82                 | 7.649               | 10.385   | 18.034        | 10.598 |

| АПЕЛАЦИОНИ СУД | БРОЈ СУДИЈА У СУДУ | ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ | ОСТАЛО НЕРЕШЕНО | СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА | старих према датуму пријема у суду просечно по судији |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| НИШ            | 32                 | 36.53                             | 3.057           | 156                         | 4.87                                                  |
| НОВИ САД       | 47                 | 23.68                             | 1.395           | 25                          | 0.53                                                  |
| КРАГУЈЕВАЦ     | 44                 | 24.8                              | 4.008           | 247                         | 5.61                                                  |
| БЕОГРАД        | 82                 | 21.54                             | 7.438           | 1.770                       | 21.58                                                 |

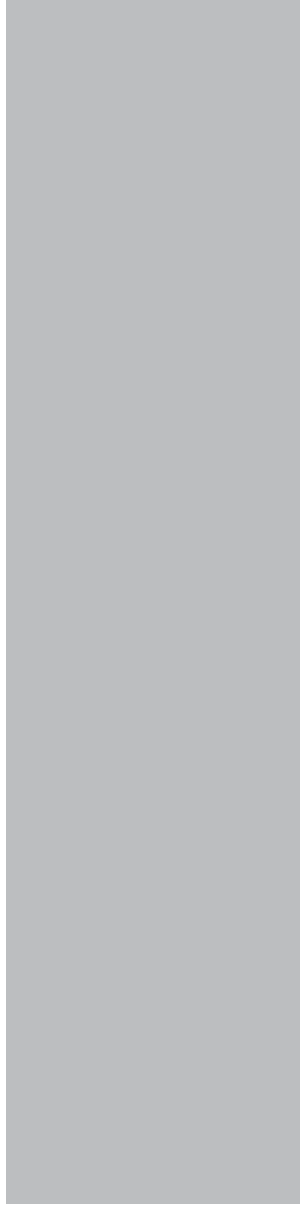
| АПЕЛАЦИОНИ СУД | процент решених предмета у суду | савладавање прилива | АЖУРНОСТ | УКУПАН КВАЛИТЕТ | старих према датуму пријема у суду просечно по судији |
|----------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| НИШ            | 69.64                           | 83.81738            | 2.19     | 99.62           | 4.87                                                  |
| НОВИ САД       | 82.72                           | 98.88732            | 1.31     | 99.16           | 0.53                                                  |
| КРАГУЈЕВАЦ     | 62.03                           | 95.14605            | 3.49     | 99.24           | 5.61                                                  |
| БЕОГРАД        | 58.76                           | 102.051             | 4.30     | 98.88           | 21.58                                                 |





# КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА





**Драган Јоцић**

Председник Апелационог суда у Нишу, судија Врховног касационог суда

**Др Дијана Јанковић,**

судија Апелационог суда у Нишу

## АПЕЛАЦИОНИ СУД И ЗАКОНИТОСТ РЕШЕЊА КРИВИЧНЕ СТВАРИ<sup>1</sup>

**Апстракт:** Пинцип законитости у кривичном праву је део и израз општег става о законитости као кривичноправном принципу. У раду се првенствено бавимо питањем контроле законитости судских одлука као индивидуланих правних аката. У жалбеном поступку ту контролу, а тиме и заштиту права странака, врши Апелациони суд, док одлуке Апелационих судова такође подлежу контроли законитости у поступку по ванредном правном леку захтеву за заштиту законитости. Како је захтев за заштиту законитости најзначајнији ванредни правни лек, на основу кога се испитује законитост свих судских одлука и првостепених и другостепених, то ће предмет разматрања бити судска пракса Апелационих судова и испитивање законитости њихових одлука применом захтева за заштиту законитости пред пред Врховним касационим судом Републике Србије. Такође ће бити извршен осврт и на поједине одлуке Уставаног суда којима су поништене како одлуке првостепених тако и Апелационих судова, у поступку по уставној жалби приликом испитивања њихове уставности и законитости.

**Кључне речи:** принцип законитости, захтев за заштиту законитости, кривични поступак, повреда закона.

---

<sup>1</sup> Рад је изложен на Конференцији Златибору у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу, Министарства правде и Правосудне академије, која је одржана септембра месеца 2018. године и публикован у ширем обиму у Зборнику радова изложених на Конференцији.

## 1. Увод

Принцип законитости као правни принцип, има огроман значај за остваривање људских права и слобода. Овај принцип стално је потврђивао и данас потврђује своју вредност као концепт чији је основни циљ искључење самовоље, арбитрерности и субјективности у решавању односа у друштву и заштита човека, његове личности, његових слобода и права, његовог равноправног положаја у друштву. Принцип законитости и његово остваривање, увек је повезано са садржином закона. Основно значење овог принципа је обавеза поступања свих и сваког по закону, али какво ће бити то поступање увек зависи од садржине закона, његових идејних основа, интереса које закон заштићује.

Принцип законитости у кривичном праву, а посебно у судској пракси Апелационих судова, где се прожимају и уливају ставови првостепених судова (који се разматрају у жалбеном поступку), Врховног касационог суда (који разматра законитост свих судских одлука кроз ванредни правни лек захтев за заштиту законитости) и Уставног суда (који је кроз инситут уставне жалбе овлашћен да поништи одлуке и првостепених и Апелационих судова и Врховног касационог суда ), има своје специфичности и свој посебан значај.

У кривичном праву овај принцип, исто као и у другим гранама законодавства, полази од владавине права, али непосредни и конкретни циљ овог принципа је спречавање злоупотребе власти и овлашћења у примени принуде према човеку путем кривичних санкција.<sup>2</sup> У судској пракси принцип законитости се остварује кроз законито решавање кривичних ствари и обухвата обавезу поштовања и спровођења у живот нормативних аката донетих на основу Устава и закона.

У практичној примени у кривичном праву, принцип законитости се реализује кроз одредбе кривичног матерјалног права, као и кроз одредбе кривичнопроценог права.

У кривичном матерјалном праву основна садржина принципа законитости своди се на три елемента: а) кривично дело може бити одређено само законом; б) само закон прописује казну за кривично дело и ц) услов је за изрицање сваке кривичне санкције да кривично дело буде законом одређено пре него што је учињено.

---

2 Ф. Бачић *et al*, *Коментар кривичног закона СФРЈ*, “Савремена администрација”, 1988, 11.

Суштина законитог решења кривичне ствари је одредити кривично дело и утврдити његова обележја и његове елементе и то првенствено радњу (чињење или пропуштање), најчешће и последицу, а некад и начин, време, место извршења дела и друге објективне (нпр. висина штете) или субјективне (нпр. намера) околности. Са гледишта остваривања принципа законитости од највећег је значаја да у самом закону обележја кривичног дела буду тако описана да не постоји сумња о томе која је конкретно друштвено опасна радња забрањена. С друге стране, са гледишта судске праксе је од суштинског значаја да у изреци пресуде законом прописана радња буде тако описана да не ствара сумњу у односу на битна обележја кривичног дела које је у питању и за које се конкретно дело једно лице оглашава кривим и изриче му се кривична снакција.

Судови и други органи (јавна тужилаштва, полиција и др.) који примењују кривично право у обавези су да пазе на остваривање принципа законитости тј. да примењују само оне одредбе које су утврђене законом, да одбију примену закона нпр. на случајеве кад је дело учињено пре ступања на снагу закона који то дело предвиђа као кривично, као и на друге случајеве који нису у складу са основним начелима кривичног права и принципом законитости.

Посматрајући кроз одредбе кривичнопроцесног права, принцип законитости се реализује тако што правила Законика о кривичном поступку треба да обезбеде законито спровођење кривичног поступка према лицима за која постоји законом прописан степен сумње да су извршила кривично дело. Наведено подразумева да свако ограничење права и слобода буде у складу са законом и у исто време да нико не буде осуђен пре него што се на законом прописан начин утврди да је крив, не само у смислу обезбеђења невиног од неоправданог гоњења и осуде, већ и у смислу гарантовања извршиоцу кривичног дела да неће подносити ништа теже од онога што по закону треба да поднесе.<sup>3</sup>

Одредба чл.1 Законика о кривичном поступку<sup>4</sup>, садржи принцип законитости у изрицању кривичних санкција, који је прописан и чл. 34

3 Т. Васиљевић, М. Грубач, *Коментар законика о кривичном поступку*, „Савремена администрација“, 1987, 3.

4 Законик о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014)- у даљем тексту ЗКП. Члан 1, "Овај законик утврђује правила чији је циљ да нико невин не буде осуђен, а да се учиниоцу кривичног дела изрекне кривична санкција под условима које прописује кривични закон, на основу законито и правично спроведеног поступка."

Устава Републике Србије. Кривичнопроцесне одредбе које се односе на принцип законитости имају двоструко значење: 1) санкција за кривична дела мора бити изречена од стране надлежног суда и у поступку спроведеном по Законику о кривичном поступку, 2) одредбе Закона о кривичном поступку се примењују само на кривична дела прописана Кривичним законом<sup>5</sup>. Тиме је и одређен предмет кривичнопроцесног права, и истакнута неспојивост осталих облика противправног поступања (привредних преступа, прекршаја и др.) у јединствени поступак са кривичним делима. На некривичне, а њима блиске поступке, одредбе Закона о кривичном поступку се примењују, само ако постоји посебна законска одредба у том смислу.

Питањем контроле законитости судских одлука као индивидуланих правних аката, бави се Апелациони суд на тај начин што као жалбени суд одлучује о повредама процесног и материјалног права учињених од стране нижих судова.<sup>6</sup> Одлуке Апелационих судова такође подлежу контроли законитости у поступку по ванредном правном леку захтеву за заштиту законитости.

У раду ће бити разматрана судска пракса Апелационих судова и испитивање законитости њихових одлука пре свега кроз примену ванредног правног лека захтева за заштиту законитости пред Врховним касационим судом Републике Србије, јер се наведеним ванредним правним леком пред највишом судском инстанцом утврђује да ли је вероватно дошло до повреде законитости материјалног или процесног закона у свим фазама спроведног поступка. Такође ће бити извршен осврт и на поједине одлуке Уставног суда којима су поништене како одлуке првостепених тако и Апелационих судова, у поступку по уставној жалби приликом испитивања њихове уставности и законитости.

## **2. Општи поглед на захтев за заштиту законитости и његово место у кривичном поступку**

Познавање особености захтева за заштиту законитости као ванредног правног лека и повреда закона које су најчешће уочаване у пракси судова, су значајне за рад и поступање и првостепених и другостепених судова, како би се првенствено избегле грешке у поступку и примени кривичног

---

5 Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) - у даљем тексту КЗ.

6 Н. Висковић, *Теорија државе и права*, II изм. и доп. изд., Биротехника, ЦДО, Загреб, 2006, 182.-183.

права. Захтев за заштиту законитости (чл. 482 – 494 ЗКП) је ванредни правни лек којим се правноснажна одлука или поступак који је претходио њеном доношењу напада због неправилне примене права (*error in iure*), која се може манифестовати као:

- (1) повреда закона (тј. као погрешна примена процесног или материјалног закона или закона за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима), односно као (2) повреда или ускраћивање људског права и слободе окривљеног или другог учесника у поступку које је зајемчено Уставом или Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и додатним протоколима, а која је утврђена од стране Уставног суда или Европског суда за људска права.

Разлог за постојање овог ванредног правног лека је у томе што постоје одлуке суда против којих се редовни правни лекови не могу користити (све наредбе, многа решења, другостепене одлуке, одлуке Врховног касационог суда), затим што се редовним правним леком, и када је допуштен, не може побијати одлука због свих повреда процесног закона већ само због битних повреда (чл. 438. ЗКП) и, најзад, зато што је Апелациони суд при одлучивању о жалби везан жалбеним разлозима (сем изузетака из чл. 451 ст. 2 и 3 и чл. 453-454) и што не може исправљати сваку повреду закона коју запази.<sup>7</sup>

Гледано са аспекта ранијих процесних закона, захтев за заштиту законитости на начин како је прописан важећим законским одредбама, представља обједињивање два ванредна правна лека у један и то (према ЗКП/2001) захтева за заштиту законитости, чији је овлашћени подносилац био Републички јавни тужилац и захтева за испитивање законитости правноснажне пресуде, чији је овлашћени подносилац био окривљени.<sup>8</sup> Имајући у виду да је Изменама и допунама Законика о кривичном поступку из 2009. године<sup>9</sup> укинут захтев за испитивање законитости правноснажне

7 М. Грубач, Т. Васиљевић, *Коментар Законика о кривичном поступку*: према Законика из 2011., Београд, 2014, 884.

8 Н. Важић, „Захтев за заштиту законитости према ЗКП Србије (основне карактеристике, могућности подношења, искуства у примени и мере унапређења“, Збо. Правни лекови у кривичном поступку - регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2016, 344-358, 345

9 Измене и допуне Законика о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72 од 03.09.2009. године).

пресуде као ванредни правни лек окривљеног, то важећим законским одредбама (ЗКП/2011), „враћање“ окривљеном права на ванредно правно средство и то не само против правноснажне пресуде, већ и других правноснажних одлука јавног тужиоца или суда због одређених повреда закона и поступка који је претходно доношењу тих правноснажних одлука (као и због повреде заштићених људских права и слобода у другим одлукама из члана 485. ЗКП), свакако представља значајан корак у правцу заштите права окривљеног на законит поступак.

Обзиром на наведено, у теорији се истиче и да је захтев за заштиту законитости ванредни правни лек који представља својеврсни инструмент који обезбеђује владавину права предвиђену самим Уставом Републике Србије (чл. 3 ст. 2 Устава).<sup>10</sup> У том смислу, он представља заштитни механизам за доследно спровођење чл. 145 Устава који прописује да се судске одлуке заснивају на Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и пропису донетом на основу закона, а свако поступање супротно наведеном представља *error in iure*.

### **3. Овлашћени титулари**

Страначка природа кривичног поступка огледа се и у овом правно леку, како у погледу лица овлашћених за подношење захтева, тако и у погледу одлука против којих је дозвољено подношење захтева. Законитост општих правних аката контролишу и испитују пре свега уставни судови, док се законитост индивидуланих правних аката штити путем правних лекова који се у судским поступцима подносе Апелационим судовима и захтева за заштиту законитости који се подносе Врховном касационом суду.

Као овлашћени титулари захтева за заштиту законитости нормирани су Републички јавни тужилац, и као што је поменуто, окривљени и његов бранилац (чл. 483 ст.1 ЗКП).

Увођење одбране у круг овлашћених подносилаца овог ванредног правног лека је утемељено како на схватању да се основна сврха захтева за заштиту законитости састоји у заштити општег интереса<sup>11</sup>, тако и на начелу

---

<sup>10</sup> М. Шкулић, Т. Бугарски, *Кривично процесно право*, Нови Сад, 2015, 526.

<sup>11</sup> Г. П. Илић, „О захтеву за заштиту законитости у кривичном поступку“, *Казнена реакција у Србији - Део 2*, (ур. Ђ. Игњатовић), Београд, 2012, 158.



правичног вођења кривичног поступка које, између осталог, предвиђа и правило о једнакости „оружја“ странака у поступку. До неправилне примене права може доћи како у самој правноснажној одлуци (коју може донети суд или јавни тужилац) тако и у поступку који је претходио њеном доношењу.

Стога је, у оквиру општих одредби које нормирају овај ванредни правни лек, у делу о дозвољености подношења захтева, у чл. 482 ст. 1 ЗКП прописано да се захтев за заштиту законитости може поднети против правноснажне одлуке јавног тужиоца или суда или због повреде одредаба поступака који је претходио њеном доношењу. Наведно је посебно значајно и са аспекта законитог поступања првостепених и Апелационих судова, који су дужни да пазе на законитост примене процесних правила и закониту примену материјалног права у свакој фази кривичног поступка. При томе „повреде одредаба поступака“ треба тумачити као повреде процесних прописа које су претходиле доношењу правноснажне одлуке, без обзира на то да ли је истовремено и правноснажном одлуком повређен закон.

До њих може доћи и различитим процесним радњама које нису довеле до одлуке засноване на тим незаконитим радњама или нису довеле до одлуке уопште (нпр. испитивање сведока у присуству других неиспитаних сведока).

У складу са наведеним, нпр. кад се захтев за заштиту законитости подноси против пресуде којом је одлучено о „спајању казни“, поступком који је претходио доношењу ове пресуде не сматра се поступак који се односи на доношење правноснажних пресуда којима су изречене казне које су ушле у јединствену казну.<sup>12</sup>

Захтевом за заштиту законитости по правилу се могу побијати одлуке и поступак сваког суда (па и Врховног). У том погледу постоји само један изузетак. Конкретно у односу на одлуке против којих се може уложити захтев за заштиту законитости у чл. 482 ст. 2., ЗКП предвиђа и једно ограничење: Подношење захтева за заштиту законитости није дозвољено против одлуке Врховног касационог суда о захтеву за заштиту законитости или због поступка који је пред Врховним касационим судом претходио њиховом доношењу. Међутим, наведено не искључује побијање других одлука Врховног касационог суда овим ванредним правним леком. Реч је, заправо, о законском нормирању

---

12 Врховни касациони суд, Кзз. ОК 8/2012 од 18.09.2012. године.

начелног становишта XIII Заједничке седнице Савезног суда и Врховних судова република и покрајина и Врховног војног суда од 25. и 26.10.1979. године, а које је мотивисано жељом да се спречи неограничено понављање подношења захтева, јер би се иначе захтев могао неограничено понављати.

***- бранилац по службеној дужности у поступку по ванредном правном леку***

Већ на самом почетку примене ЗКП/2011 поставило се питање може ли захтев за заштиту законитости поднети бранилац по службеној дужности као и да ли постоји потреба за постављењем браниоца по службеној дужности окривљеном ради подношења овог правног лека. С тим у вези, Врховни касациони суд је својим одлукама заузео став да бранилац по службеној дужности може поднети захтев за заштиту законитости само док у складу са ЗКП има то својство, тј. до правноснажног окончања кривичног поступка (чл. 74. ЗКП). Према ставу Врховног касационог суда у решењу 1088/2015<sup>13</sup>, како је кривични поступак против окривљеног у предмету Првог основног суда у Београду, правноснажно окончан доношењем пресуде Апелационог суда у Београду, а захтев за заштиту законитости поднела је адв. С.Б. (преко свог пуномоћника адв. С.М.) која је у том поступку окривљеном била постављена за браниоца по службеној дужности, дакле само до правноснажног окончања поступка и која следствено напред цитираним законским одредбама и изнетим разлозима, не спада у круг лица која могу поднети захтев за заштиту законитости, то следи да је према важећим законским одредбама предметни захтев поднет од неовлашћеног лица и стога недозвољен.

Ово је посебно од значаја у ситуацијама када бранилац по службеној дужности одређен на основу чл.74. тач.2. ЗКП (због висине запрећене казне) поднесе захтев за заштиту законитости против правноснажне пресуде иако му је својство браниоца по службеној дужности престало, по сили закона, правноснажним окончањем кривичног поступка, у ком случају се такав захтев одбацује као недозвољен. Када је у питању потреба постављања браниоца по службеној дужности ради подношења захтева за заштиту законитости, та обавеза је постојала, према одредби чл.71. ст.4. ЗКП/2001, у случају када је окривљени осуђен на казну затвора у трајању од 40 година (важећи ЗКП/2011 такву одредбу не садржи. Сматрамо да би било оправдано законом омогућити окривљеном да има браниоца по службеној дужности и у овој фази поступка,

---

<sup>13</sup> Врховни касациони суд, Кзз 1088/2015 од 17.12.2015.

посебно имајући у виду раније законске одредбе, будући да достигнути ниво људских права не треба смањивати. Посебно зато што чл. 483. ст.2. ЗКП прописује да се захтев за заштиту законитости подноси искључиво преко браниоца, те уколико окривљени није у могућности да ангажује браниоца, а закон не дозвољава браниоца по службеној дужности након правноснажности пресуде, то га лишава могућности за подношење овог ванредног правног лека.

***- подношење захтева за заштиту законитости против одлука јавног тужиоца***

За разлику од ЗКП/2001, важећи ЗКП/2011 изричито наглашава да се захтев може поднети и против одлуке јавног тужиоца што до сада није био случај. Обзиром да законска редакција говори о „одлуци“, може се закључити да се захтев за заштиту законитости може поднети против сваке правноснажне пресуде или решења, али и против наредбе.

Када је реч о подношењу захтева за заштиту законитости против решења о одбацивању кривичне пријаве, поставило се питање дозвољености захтева као и како би у том случају гласио предлог који подносилац захтева по овом ванредном правном леку истиче? С обзиром на то да се захтевом не може изменити одлука на штету окривљеног, предлог у захтеву који се подноси против решења о одбацивању кривичне пријаве могао би да буде искључиво да се утврди да је повређено право у корист осумњиченог (чл.493. ЗКП).

С друге стране поставља се и питање правне природе решења о одбачају кривичне пријаве, с обзиром да решење о одбацивању кривичне пријаве може постати само формално правноснажно, јер је то одлука организационог типа без процесног и спољашњег дејства којом се у суштини одређује начин поступања са кривичном пријавом.<sup>14</sup> Став да одлуке које немају материјалну правноснажност не могу да буду предмет захтева за заштиту законитости, заснива се на традиционалном правном гледишту изнетом у једној одлуци Врховног суда Србије у којој је наведено да се не може поднети захтев за заштиту законитости против одлука којима се не окончава кривични поступак и да се самим тим захтев може поднети само када је кривични поступак мериторно правноснажно довршен,<sup>15</sup> односно само против мериторних одлука.

---

<sup>14</sup> Г. Илић, „Јавни тужилац у Србији као једини субјект права на подношење захтева за заштиту законитости - да или не?“, Збо. Правни лекови у кривичном поступку - регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2016, 363-371, 368.

<sup>15</sup> Врховни суд Србије, Кзз 35/1972 од 19.09.1972. године.

**- дозвољеност захтева за заштиту законитости против наредбе суда**

У теорији кривичног процесног права постављало се питање да ли је захтев за заштиту законитости дозвољен против наредбе суда обзиром да та одлука не стиче правноснажност која се претпоставља за ванредне правне лекове.

Према већинском ставу правне доктрине (а који је прихваћен и у судској пракси) могуће је уложити захтев за заштиту законитости против наредбе, јер иако узмемо да се наредба не може обухватити појмом „правноснажне судске одлуке“, ван дискусије је да она улази у појам „судског поступка који је претходио правноснажној одлуци“, јер је наредба процесна радња одлучивања, а поступак је скуп процесних радњи.<sup>16</sup>

Суштински, захтев за заштиту законитости поднет против наребе суда је дозвољен јер представља захтев због повреде поступка који је претходио доношењу правноснажне одлуке, будући да доношење наредбе представља процесну радњу одлучивања у кривичном поступку која је регулисана процесним правилима и свако поступање супротно наведним правилима представља повреду поступка који је преходи доношењу правноснажне одлуке.

#### **4. Повреде закона на које се указује захтевом за заштиту законитости**

Законитост решавања кривичноправне ствари је главни задатак судова. Највећи значај одлука по захтеву за заштиту законитости и њихов утицај на одлуке нижестепених судова је у томе што се заснивају на аргументима законитости. Доносећи одлуке и решавајући о наведним повредама материјалноправних и процесноправних одредаба виши судови у својим одлукама дају аргументе. У овом случају судови аргументују на основу начела законитости, односно дају аргументе о законитости одређеног појединачаног судског акта<sup>17</sup> (пресуде, решења). Зато се, по нашем мишљењу аргумент законитости може посматрати и као један од аргумената општих правних начела и као самостални аргумент путем кога судије виших судова

---

16 Т. Васиљевић, М. Грубач, *Коментар Законика о кривичном поступку*, Београд, 2010, 919-920

17 G. Tarello, “Аргументација тумачења и шеме образлагања у придавању значења нормативним текстовима”, *Зборник за теорију права ИВ*, Београд, 1990., 239-279. (превод Н. Висковић и С. Шућин, 8. поглавља, 341.-396., т. 56-75, књиге Tarello, G., *L’interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè).

аргументују, образлажу своје ставове, када решавају о повредама закона учињеним од стране нижестепених судова.

Законитост општих правних аката контролишу и испитују пре свега уставни судови, док се законитост индивидуалних правних аката штити путем правних лекова који се у судским поступцима подносе Апелационим судовима и захтева за заштиту законитости који се подносе Врховном касационом суду.

Захтев за заштиту законитости се, сходно чл. 485 ст.1. ЗКП, може поднети ако је правноснажном одлуком или одлуком у поступку који је претходно њеном доношењу:

- (1) повређен закон;
- (2) примењен закон за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима;
- (2) повређено или ускраћено људско право и слобода окривљеног или другог учесника у поступку које је зајемчено Уставом или Европском другостепеног суда донетог супротно законској одредби која искључује могућност да се по други пут укине другостепена пресуда.

С друге стране, није дозвољен захтев за заштиту законитости против одлуке Републичког јавног тужиоца, достављене осуђеном у форми обавештења, обзиром да је таква одлука дискреционо право тужиоца и не представља правноснажну одлуку у смислу чл. 482 ст. 1 ЗКП/2011.<sup>18</sup>

Такође, није дозвољено уложити захтев против решења другостепеног суда којим се укида првостепена пресуда због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања и предмет враћа на поновно суђење јер се ради о формалном правноснажном решењу којим се у конкретном случају одређује начин поступања пред судом, а и сам поступак је још увек у току па се повреда још увек може исправити редовним правним леком.<sup>19</sup>

---

18 Врховни касациони суд, Кзз. 457/2014 од 22.05.2014. године и УС, Уж-315/09 од 04.06.2009. године (Наведено према: Г. П. Илић et al., Коментар Законика о кривичном поступку, 8. издање, Београд, 2015, 1100-1101.)

19 М. Грубач, Т. Васиљевић, 888.

Подношење захтева за заштиту законитости као ванредног правог лека је у вези са претходним коришћењем редовног правног лека пред Апелационим судовима. Тако, чл. 485 ст. 4 ЗКП/2011 прописује да захтев за заштиту законитости због повреда ЗКП у из чл. 74, чл. 438 ст. 1 тач. 1 и 4 и тач. 7 до 10 и ст. 2 тач. 1, чл. 439 тач. 1 до 3 и чл. 441 ст. 3 и 4, учињених у првостепеном и поступку пред Апелационим судом, окривљени може поднети у року од 30 дана од дана када му је достављена правноснажна одлука, под условом да је против те одлуке користио редовни правни лек. Иако би се из наведене одредбе, строго формално гледано, могло закључити да је повреда закона на коју се указује захтевом за заштиту законитости морала бити обухваћена и у ранијој жалби, судска пракса је заузела мало шири став и у том смислу прихватила да је овај „додатни услов“ испуњен и у ситуацији када је окривљени изјавио жалбу (користио редовни правни лек) из свих законом предвиђених разлога, а у жалби није прецизно определио повреду из ст. 4, коју сада захтевом за заштиту законитости указује.<sup>20</sup>

## **5. Повреда закона**

Повреда закона као основ за подношење захтева за заштиту законитости дефинисана је одредбом чл. 485 ст. 2, којим је прецизирано да повреда закона постоји ако је правноснажном одлуком или у поступку који је претходио њеном доношењу повређена одредба кривичног поступка или ако је на чињенично стање утврђено у правноснажној одлуци погрешно примењен материјални кривични закон.

За разумевање наведеног основа неопходно је претходно прецизно дефинисати појмове који се у оквиру истог јављају.

Под изразом „закон“ треба разумети сваки правни пропис на коме суд заснива своју одлуку или поступак. Може се при томе радити не само о одредбама законског карактера већ и о другим прописима чија је примена са становишта материјалног или процесног права у конкретном случају била неопходна.

Постојање „повреде одредаба кривичног поступка“ треба тумачити као повреду процесних прописа која је претходила доношењу правноснажне

---

<sup>20</sup> Б. Цветковић, „Ванредни правни лекови и нови ЗКП“, Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена, Златибор-Београд, 2013, 197.

одлуке, без обзира на то да ли је истовремено правноснажном одлуком повређен закон.

За повреду процесног закона не тражи се да су утицале на пресуду и да су битне: долазе у обзир и апсолутне, и релативне, и „небитне повреде поступка“, под условом да су од значаја за правилну и уједначену примену права.

Под „погрешном применом материјалног закона“ требало би разумети примену закона који није требало применити или непримењивање закона који је на утврђено чињенично стање требало применити. Иначе, подвођење чињеничног под плашт правног питања у теорији је образлагано ставом да се захтев за заштиту законитости може поднети када је до неправилне примене закона дошло због неправилно утврђеног чињеничног стања због којег није допуштено понављање кривичног поступка.

Захтев за заштиту законитости на основу чл. 485 ст.1 тач.1 Републички јавни тужилац може заснивати на било којој повреди процесног или материјалног закона.

С друге стране, право окривљеног на подношење захтева за заштиту законитости због повредe закона је ограничено чл. 485 ст. 4 који прописује да због повреда овог законика (чл. 74, чл. 438. ст. 1. тач. 1 и 4 и тач. 7 до 10 и ст. 2 тач. 1, чл. 439 тач. 1 до 3 и чл. 441 ст. 3 и 4) учињених у првостепеном и поступку пред Апелационим судом, окривљени може поднети захтев за заштиту законитости само ако су кумулативно испуњена два услова: (1) да је захтев поднет у року од 30 дана од дана достављања правноснажне одлуке и (2) под условом да је против те одлуке користио редовни правни лек.

Везано за други услов, с правом је примећено да је спорно да ли је окривљени претходно увек морао да користи редован правни лек, јер када се ради о одлукама јавног тужиоца некада није ни прописана могућност жалбе, као и када се ради о наредби за спровођење истраге.

## **6. Судска пракса у области повреда процесног закона**

У таксативно наведене повреде законика у погледу којих морају кумулативно бити испуњени услови који се тичу рока за подношење захтева за заштиту законитости и претходно коришћење редовног правног лека спадају повреде процесног закона које могу обухватати више различитих повреда.

### **(1) Повреда процесног закона о обавезној одбрани (чл. 74 ЗКП)**

Одредбом члана 74. ЗКП описано је девет процесних ситуација у којима окривљени мора имати браниоца, те тако и браниоца по службеној дужности, као и до када.

Посматрајући досадашњу судску праксу може се указати на неке одлуке у којима је Врховни касациони суд нашао да није дошло до повреде закона о обавезној одбрани од стране првостепених судова:

- ако доказној радњи препознавања (у предистражном поступку) није присуствовао бранилац окривљеног који му је постављен по службеној дужности;
- ако је окривљеном за браниоца по службеној дужности постављен адвокат који је у другом, парничном поступку, заступао оштећену у овом поступку;
- у ситуацији да је окривљеног у току поступка најпре бранио изабрани бранилац који није имао формално својство адвоката па му је потом за браниоца по службеној дужности постављен други бранилац из реда адвоката у чијем присуству је главни претрес поново отворен и окривљени саслушан у његовом присуству;
- ако суд у поступку извршења заменом изречене новчане казне казном затвора, окривљеном не постави браниоца по службеној дужности (јер се не ради о суђењу у одсуству) него тек када и уколико не може да му се решење о замени новчане казне затвором уручи на адресу у списима предмета;<sup>21</sup>

С друге стране, у предмету Кзз 590/2014, Врховни касациони суд је усвојио захтев за заштиту законитости закључивши да постоји повреда законских одредби о обавезној одбрани из чл. 74 ЗКП/2011 ако окривљени за кривично дело за које је прописана казна затвора од једне до осам година у редовном поступку није ангажовао браниоца, а суд му није поставио браниоца по службеној дужности. Такав закључак суд је темељио на одредби чл. 74 ст. 1 тач. 2 ЗКП/2011 која прописује да, ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна, окривљени мора имати браниоца од првог саслушања па до правноснажног окончања кривичног поступка.<sup>22</sup>

---

21 В. Крстајић, „Судска пракса у поступку по захтеву за заштиту законитости“, Билтен Врховног касационог суда 2/2017, 9-50, 11.

22 Врховни касациони суд, Кзз 590/2014 од 08.07.2014. године.



## (2) Битне повреде одредаба кривичног поступка које се односе на постојање околности које трајно искључују кривично гоњење

Одредбом чл. 438 ст. 1 тач. 1 ЗКП предвиђена је (апсолутно) битна повреда кривичног поступка која постоји ако је наступила застарелост кривичног гоњења, или је гоњење искључено услед амнестије или помиловања, или је ствар већ правноснажно пресуђена, или постоје друге околности које трајно искључују кривично гоњење. Као најчешћи разлог постојања ове повреде истицано је да је ствар „правноснажно пресуђена“.

### - *ne bis in idem*

У домаћем законодавству *ne bis in idem* начело је шире конципирано него у већини других правних система, као и у односу на међународна кривичнопроцесна документа. Наиме, већински приступ ( укључујући и Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода - чл. 4. ст.1. Протокола 7, Савета Европе из 1984. године) подразумева уже схватање начела *ne bis in idem*, када се забрана поновног покретања поступка везује за правноснажну мериторну пресуду (ослобађајућу или осуђујућу), док наше законодавство предвиђа дејство овог начела и у односу на одбијајућу пресуду, као и на решење о обустави кривичног поступка.<sup>23</sup>

У предмету Кзз 536/2014, Врховни касациони суд је закључио да се очигледно ради о правноснажно пресуђеној ствари (повреда закона из чл.438 ст.1 тач.1 ЗКП) када су окривљени у прекршајном поступку правноснажно оглашени одговорним, а у кривичном поступку (вођеном након правноснажности прекршајног решења) правноснажно оглашени кривим, на основу битно истих чињеница (чињенични опис прекршаја се односи на исте окривљене, на исти животни догађај који се десио у исто време, на истом месту истоветним радњама окривљених), те је усвојио захтев за заштиту законитости и одбио оптужбу за учињено кривично дело.<sup>24</sup>

23 Према члану 34. ст. 4. Устава Републике Србије и одредби чл.4. Законика о кривичном поступку, забрана поновног суђења наступа не само после правноснажности мериторне пресуде, већ и после правноснажности

одлуке (решења или формалне пресуде) којом се кривични поступак обуставља или оптужба одбија.

24 Врховни касациони суд, Кзз 536/2014 од 02.07.2014. године

Питање које се највише поставља у домаћој судској пракси односи се на утврђивање идентитета дела (*idem*) и у вези са тим применом постављених стандарда Европског суда за људска права.

Европски суд за људска права је испитујући да ли постоји идентитет казних дела у предмету *Золотухин против Русије*, за разлику од ранијег приступа заснованог на идентитету правних квалификација дела или идентитету заштићених добара, применио критеријум „материјалног идентитета дела“.<sup>25</sup> Његова суштина се своди на то да се члан 4. Протокола број 7. уз Европску конвенцију мора тумачити на начин да забрањује казни прогон или суђење за друго дело у мери у којој оно произлази из истоветних чињеница или чињеница које су у суштини битно исте као и прво кажњиво дело за које је већ донета правноснажна осуђујућа или ослобађајућа пресуда.<sup>26</sup> Наведене стандарде је поставио и у пресуди *Марести против Хрватске*<sup>27</sup> као и три мерила установљена у предмету *Енгел и други против Холандије*<sup>28</sup>.

Наведени стандарди су постали обавезујући за домаће судове. Оно што можемо приметити да су домаћи судови, покушавали да тако строгу примену критеријума „материјалног идентитета дела“, вежу за заштићено правно добро и за законом прописан супстрат кривичног дела, а при чињеници да су прекршајни судови непотребно проширили чињенични опис прекршаја, обухватајући у изреци прекршајне пресуде и опис кривичног дела. Међутим, Европски суд за људска права није прихватио такве ставове домаћих судова и у предмету *Миленковић против Србије* је утврдио повреду принципа *ne bis in idem*.

У случају *Миленковић против Србије*<sup>29</sup>, Европски суд за људска права је упоредио инкриминације за прекршај и кривично дело па је закључио да је у прекршајном поступку подносилац кажњен зато што је ударио оштећеног неколико пута у пределу главе и повредио га, док је у кривичном поступку кажњен због ударања истог оштећеног по глави, којом приликом му је нанео

---

25 L. Wildhaber, „The European Convention on Human Rights and International Law”, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 56, 2007, 217–219.

26 Д. Поповић, *Постанак европског права људских права* (превели В. и М. Јовановић), Службени гласник, Београд 2013, 147.

27 *Maresti v. Croatia*, 25. September 2009, no. 55759/07.

28 *Engel and Others v. the Netherlands*, 8 June 1976, no. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72.

29 *Milenkovic v. Serbia*, 1 March 2016, no. 50124/13.

тешку телесну повреду, при чему су место и време извршених кажњивих радњи истоветни у оба поступка. Код таквих околности, по оцени Европског суда за људска права, без значаја је то што законска дефиниција прекршаја не садржи тешку телесну повреду, што је тврдила тужена држава (Србија), па је извео закључак о истоветности кажњивих дела у предметном случају. У наведеном предмету је Европски суд за људска права приликом утврђивања „идентитета дела“ стриктно применио критеријум „материјалног идентитета дела“ из пресуде *Золотухин против Русије*, од 10. фебруара 2009. године.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 143/2017<sup>30</sup>, која је донета након одржаног претреса пред другостепеним судом, је једна од новијих одлука тог суда у којој се оцењивало да ли се ради о пресуђеној ствари, а у питању је најтежа последица која може бити произведена неком противправном радњом - смртна последица. Апелациони суд у Нишу је у својој одлуци, позивајући се на праксу Европског суда за људска права и тумачење одредбе чл. 4 Протокола 7, које је Европски суд дао у наведеним пресудама, утврдио да се ради о пресуђеној ствари.

У пресуди Врховног касационог суда Кзз 121/2017<sup>31</sup>, која иако се односи на други случај, је практично заузет исти став као у наведеној пресуди Апелационог суда у Нишу.

Резимирајући, наведене примере судских одлука и заузете ставове, можемо рећи, да су домаћи кривични судови приликом одлучивања о примени принципа *ne bis in idem*, у судској пракси, посебно у предметима у којима се ради о последици која резултира тешким нарушењем здравља или смрћу, увек „на танкој линији“ успостављања равнотеже између принципа правне сигурности применом принципа *ne bis in idem* и заштите права на живот које такође представља основно људско право заштићено чл.2. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, зајамчено је Уставом и ужива кривичноправну заштиту.

Оно што представља проблем, у оваквим случајевима, је непостојање јасног разграничења између кривичних дела и прекршаја у домаћем законодавству, тако да долази до ситуације у судској пракси да пресуђена

30 Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 143/2017 од 15.06.2017. године.

31 Пресуда Врховног касационог суда Кзз 121/2017 од 1.02.2017. године.

ствар у прекршајном поступку представља сметњу за осуду учинилаца кривичних дела.<sup>32</sup>

Са друге стране, постоји опасност да оваква специфичност домаћег казненог законодавства (прекршајног и кривичног), доведе до тога да се угрозе претежније конвенцијске обавезе сваке државе чланице, а то је пре свих, заштита права жртве на живот из члана 2. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, које представља највредније људско право, те права на неповредивост телесног и душевног интегритета из члана 3. ове Конвенције.<sup>33</sup>

Можемо поменути и то да је Уставни суд Републике Србије у одлуци Уж - 1285/2012<sup>34</sup>, указао на наведену правну дилему и изнео став: „да је у циљу заштите претежнијег интереса, поред утврђеног критеријума чињеничног идентитета дела, потребно у сваком конкретном случају размотрити и додатне, тзв. корективне критеријуме: а) идентитет заштићеног добра и тежине последица дела и б) идентитет санкције, како би се одговорило на питање да ли су дела, због којих се подносилац уставне жалбе гони или је осуђен у различитим поступцима, иста (*idem*).“ Такође је у пресуди Великог већа од 15.11.2016. године *А. и Б. против Норвешке*, број представке 24130/11, (*Case of A and B v. Norway*) Велико веће Европског суда за људска права утврдило да нема повреде правила *ne bis in idem* због паралелног вођења кривичног и прекршајног поступка за исто дело.

Враћајући се на праксу, домаћих судова, можемо рећи да оно што би свакако било корисно и значајно у домаћој судској пракси је ускладити поступање судских и прекршајних органа и развити механизам којим би се избегло да дође до преплитања чињеничних описа прекршаја и кривичних дела.

### **- застарелост кривичног гоњења**

Као други најчешћи разлог који се истиче у судској пракси за постојање битне повреде одредаба кривичног поступка која се односи на постојање околности које трајно искључују кривично гоњење, је застарелост кривичног гоњења.

---

32 E. Lambert Abdelgawad, A. Weber, „The Reception Process in France and Germany”, *A Europe of Rights – The Impact of the ECHR on National Legal Systems* (eds. H. Keller, A. Stone Sweet), 126.

33 Више о наведеном: Д. Јанковић, „Прилог стручној расправи-примена начела *ne bis in idem* у судској пракси”, Билтен Врховног касационог суда, бр. 2/2017, 236-257, 252.

34 Пресуда Уставног суда Уж - 1285/2012 од 26.03.2014. године.

Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 14/2017<sup>35</sup> усвајањем захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног преиначио правноснажне пресуде Вишег суда у Шапцу и Апелационог суда у Новом Саду, тако што је према окривљеном одбио оптужбу јер је утврдио да је доношењем другостепене пресуде повређен закон из члана 438. став 1. тачка 1. ЗКП, на штету окривљеног, јер је пре правноснажног окончања поступка наступила застарелост кривичног гоњења у смислу одредаба члана 103. тачка 6. у вези члана 104. став 6. Кривичног законика.

У наведеном предмету се поставило питање граница испитивања првостепене пресуде по службеној дужности (*ex officio*) у смислу чл.451. ст.1. ЗКП уколико је наступила застарелост кривичног гоњења, а наведено није истакнуто у изјављеној жалби као битна повреда одредаба кривичног поступка.

Поводом наведеног питања Врховни касациони суд, је заузео став да при испитивању кривичне санкције по службеној дужности, у смислу члана 451. став 2. ЗКП, другостепени суд треба да има у виду да се казне и мере упозорења могу изрећи само учиниоцу који је крив за учињено кривично дело, према начелној одредби члана 2. Кривичног законика. Другим речима, ако је пре правноснажног окончања кривичног поступка настала околност која трајно искључује кривично гоњење, а то је апсолутна застарелост и то након изјављене жалбе тада учинилац дела не може бити правноснажно оглашен кривим, па му суд не може изрећи ни кривичну санкцију, што значи да је у конкретном случају другостепени суд био овлашћен да испита питање застарелости кривичног гоњења по службеној дужности, те да преиначи на основу члана 459. став 1. ЗКП, првостепену пресуду и на основу члана 422. став 1. тачка 3. ЗКП, одбије оптужбу против окривљеног.

### **(3) Кршење правила о обавезном изузећу судије**

Наведена повреда постоји ако је на главном претресу учествовао судија или судија-поротник који се морао изузети (чл.438 ст.1 тач. 4 ЗКП), те је очигледно реч о испитивању услова за обавезно изузеће из чл.37. ст.1 ЗКП.

Тако, у одлуци Кзз 1461/2016 , Врховни касациони суд је усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног и укинуо пресуду Апелационог суда у Новом Саду. Врховни касациони суд је нашао да је у доношењу одлуке суда трећег степена по жалби на пресуду другостепеног суда учествовао судија који се, у смислу одредбе члана 37. став 1. ЗКП морао изузети јер је претходно учествовао

---

35 Врховни касациони суд, Кзз 14/2017, 19.01.2017. године.

у доношењу раније другостепене одлуке којом је у односу на овог окривљеног и у односу на ово кривично дело првостепена пресуда укинута и предмет враћен на поновни поступак, док је у односу на друго кривично дело овог окривљеног та ранија првостепена пресуда потврђена. Врховни касациони суд је изразио став да је у конкретном случају кривични поступак јединствен и до правноснажног окончања вођен по једном оптужном акту „па се учешће судије у раду на предмету има посматрати као једна целина у односу на окривљеног Љ.Л.“.

Повреду ове одредбе а у вези чл. 37. ст.1 тач.4. ЗКП, Врховни касациони суд је нашао и у предмету Кзз 342/2017. Наиме, разлог за обавезно изузеће судије од одлучивања у поступку по жалби на решење којим је одбачен предлог за понављање поступка, Врховни касациони суд налази у чињеници што је исти судија учествовао и у доношење мериторне одлуке у односу на коју се тражи понављање поступка, односно учествовао је као члан већа другостепеног суда који је донео мериторну одлуку о жалби на пресуду.

#### **(4) Постојање оптужбе овлашћеног тужиоца, односно одобрења надлежног органа**

Повреда може постојати „ако уопште није било оптужбе или уколико овлашћени тужилац у току поступка одустане од оптужбе, а суд упркос томе настави кривични поступак“<sup>36</sup> (чл.438 ст.1 тач.7 ЗКП).

У предмету Кзз 8/2017 (а и у више других сличних) Врховни касациони суд је нашао да је у датој ситуацији оштећени као тужилац овлашћен на измену правне квалификације (и кривично гоњење окривљеног по истој) имајући у виду да је одредбом чл.58. ст.2. ЗКП одређено да поред права из става 1. овог члана, оштећени као тужилац има права која припадају јавном тужиоцу, осим оних која јавни тужилац има као државни орган, а одредбом чл.409. ст.1. ЗКП одређено је да овлашћени тужилац може да у току главног претреса измени оптужницу.

#### **(5) Непотпуно решен предмет оптужбе**

Битна повреда из чл.438. ст.1. тач.8. ЗКП постоји уколико пресудом није потпуно решен предмет оптужбе, при чему се о непотпуно решеном предмету оптужбе може говорити само у ситуацији када суд није уопште донео одлуку о

---

36 Врховни касациони суд, Кзз 368/2016 од 06.04.2016 године.

некој тачки оптужбе. Ова повреда не постоји уколико суд нађе да је неко лице уместо више удараца оштећеном задао само један ударац, имајући у виду да је суд овлашћен да мења опис дела из оптужнице, односно оптужног предлога, уколико остаје у границама оних чињеница и околности на којима се оптужба заснива, а из којих произилазе законска обележја одређеног кривичног дела.<sup>37</sup>

Такође је суд у потпуности решио предмет оптужбе, у ситуацији када је окривљеном оптужним предлогом надлежног јавног тужиоца било стављено на терет да је на штету два лица извршио једно кривично дело преваре из члана 208. став 1. КЗ, те је првостепени суд налазећи да у радњама окривљеног које се односе на оштећеног Н.В. нема законских обележја кривичног дела превара из члана 208. став 1. КЗ, већ да је у питању грађанскоправни однос, из изреке пресуде, изоставио ову радњу извршења која је улазила у састав јединственог кривичног дела. Ово стога јер суд не може у изреци пресуде за поједине делове чињеничног описа истог кривичног дела да донесе ослобађајућу, а за други осуђујућу пресуду.<sup>38</sup>

## **(6) Прекорачење оптужбе**

Питање идентитета оптужбе и пресуде а у вези са тим и битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 9. ЗКП је увек актуелно и било је предмет усаглашавања ставова апелационих судова.

Суд је овлашћен да мења опис дела из оптужног акта уколико учињеном изменом не излази из оквира чињеница и околности које су основ оптужбе, а из којих произилазе законска обележја одређеног кривичног дела. Сходно наведеном прихваћено је у судској пракси да измена вредности одузете, утајене, присвојене и др. ствари, која је наведена пресуди у износу нижем од оног наведеног у оптужном акту, сагласно чињеничном стању утврђеном вештачењем, не представља прекорачење оптужбе на штету окривљеног и битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 9) ЗКП.<sup>39</sup>

Врховни касациони суд је у свом Закључку са заједничке седнице одржане са представницима кривичних одељења Апелационих судова дана 25.03.2016.

---

37 Врховни касациони суд, Кзз 960/2016 од 21.09.2016. године.

38 Апелациони суд у Београду Кж1 6561/13 од 04.02.2014. године и Врховни касациони суд Кзз **1186/2014 од 18.12.2014 године.**

39 Виши суда у Нишу, Кж1 246/2016 од 17.05.2016. године и Врховни касациони суд Кзз 1261/2016 од 02.03.2017. године

године, заузео став да је: Суд овлашћен да окривљеног огласи кривим и за теже кривично дело у односу на правну оцену дела од стране тужиоца, уколико су његови битни законски елементи садржани у чињеничном опису дела из оптужбе.<sup>40</sup>

Такође не постоји повреда из чл. 438 ст. 1 тач. 9 (прекорачење оптужбе) када је суд у изреку пресуде унео чињенице које у оптужници не стоје и то у вези брзине кретања окривљеног, тако што је окривљени оглашен кривим јер је управљао возилом „недозвољеном брзином од 88 км/х“, иако му је оптужницом стављено на терет да је управљао „неприлагођеном брзином“. Тиме што је суд у изреци пресуде уопштене наводе из диспозитива оптужнице јавног тужиоца конкретизовао уносећи чињенице и околности које је утврдио извођењем доказа на главном претресу, а нарочито чињеница и околности које су утврђене изведеним саобраћајно-техничким вештачењем Центра за вештачење ДОО Нови Сад, оптужба није прекорачена.<sup>41</sup>

### **(7) Забрана *reformatio in peius***

Забрана *reformatio in peius* (чл. 453. ЗКП), је институт кривичног права који онемогућава да се правни лек изјављен у корист окривљеног искористи против њега. Тиме се штите права окривљеног у кривичном поступку и пружа правна сигурност да својим правним леком неће погоршати свој процесни положај. То је у складу са начелом правичности и правне сигурности који налажу тзв. „апсолутно дејство“ ове забране, тако да ни суд правног лека, ни првостепени суд у поновљеном поступку, не смеју донети одлуку која би на било који начин ишла на штету окривљеног.

Тако је Врховни касациони суд нашао, да је Апелациони суд у Нишу повредио члан 453. ЗКП, преиначујући одлуку о кривичној санкцији тако што окривљеног осудио на казну (новчану), уместо изречене мере упозорења (условна осуда), која мера му је била изречена од стане првостепеног суда и

---

40 Закључак са Заједничке седнице представника кривичних одељења апелационих судова и Врховног касационог суда Републике Србије ради усаглашавања судске праксе, одржане у Петроварадину дана 25.03.2016. године.

41 Апелациони суд у Новом Саду Кж1 4592/13 од 04.04.2014. године и Врховни касациони суд Кз3 614/2014 од 03.07.2014. године.



пре и након укидања првостепене пресуде а није било жалбе јавног тужиоца на првостепену пресуду, пре првог укидања, у том делу.<sup>42</sup>

У вези са наведеним се у судској пракси поставило питање, домета и дејства наведеног начела, које је било предмет разматрања кривичних одељења Апелационих судова и Врховног касационог суда. Постављено је питање: да ли примена одредбе чл.453 ЗКП обухвата само правну квалификацију кривичног дела и кривичну санкцију, како је у ЗКП наведено или се забрана односи и на неповољније чињенично стање по оптуженог без обзира да ли се ради о истој правној квалификацији кривичног дела? Став је Апелационих судова да забрана *reformatio in peius* важи и за чињенично стање. У поновном поступку, а након укидања првостепене по жалби одбране, утврђивање новог чињеничног стања може ићи само дотле док не буде неповољније за окривљеног од оног које је било утврђено у претходној преуди, јер иста представља доњу границу промене положаја окривљеног. То значи да првостпени суд у поновљеном поступку може утврђивати чињенично стање до граница одређених претходном пресудом, а што се тиче чињеница које иду у корист окривљеног неограничено.<sup>43</sup>

## (8) Недозвољени докази

Незаконити докази у кривичном поступку су сложен и диференциран кривичнопроцесни појам чији је садржај у сталном развоју, и то у мањој мери због више или мање честих законских интервенција, а примарно због његове практичне вредности и каузалне природе. Није довољно да предложени докази буду само релевантни за конкретан случај, већ је неопходно и да буду и прихватљиви - законити.<sup>44</sup> Да би се један доказ сматрао „незаконитим“ неопходно је утврдити, да је он „посредно или непосредно сам по себи или према начину прибављања у супротности са Уставом, Законом о кривичном поступку, другим законом или општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима“ (члан 16. став 1. ЗКП).<sup>45</sup> Када је у питању домаћи кривични поступак, у неким анализама се

42 Врховни касациони суд, Кзз 85/2012 од 24.10.2012. године.

43 Седница кривичног одељења Апелационог суда у Београду одржана дана 19.09.2016. године.

44 M.D. Forkosch, "The Nature of Legal Evidence", *California Law Review*, vol. 59, 1971, p.1378.

45 С. Бркић, „Употреба незаконитих доказа у кривичном поступку Србије“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 1/2011, 184.

прави разлика између повреде поступка приликом прибављања и приликом извођења доказа.<sup>46</sup>

Постоји веома бројна и разноврсна судска пракса у овој области. Често се постављало питање доказне снаге писаних доказа достављених у фотокопији, листинга телефонских комуникација, шта се сматра симулованим послом и др. У предмету Кзз 673/2014, Врховни касациони суд је закључио да неовверена фотокопија извештаја лекара специјалисте не представља недозвољен доказ на коме се пресуда не може заснивати, имајући у виду: (1) да се о повредама оштећене у првостепеном поступку изјашњавао и вештак медицинске струке, као и да у списима предмета постоји записник о увиђају у коме су констатоване повреде које је оштећена задобила критичном приликом, те је с обзиром на друге изведене доказе, очигледно да би и без тог доказа била донета иста пресуда и (2) одредба чл.139 ст.1 ЗКП не обавезује изричито суд да као доказ користи искључиво оригиналне исправе, с обзиром да је наведеном одредбом прописано да се исправа прибавља, по правилу, у оригиналу<sup>47</sup>

Такође, поступање полицијских службеника (прибављање новца из наменских средстава Полицијске управе и предаја претходно обележених новчаница оштећеном ради предаје истих окривљеном, чекање испред канцеларије окривљеног да би ушли на знак оштећеног), нема карактер посебне доказне радње из чл.174. ЗКП (симуловани посао), већ представља уобичајену техничку радњу обезбеђења доказа из чл.286 ЗКП коју су припадници органа унутрашњих послова овлашћени да самостално предузимају, без претходног одобрења јавног тужиоца или суда. Стога, ни полицијски службеници, ни оштећени насупрот наводима захтева, нису поступали у својству извршилаца посебне доказне радње симулованог посла.<sup>48</sup>

## **7. Судска пракса у области повреда материјалног кривичног закона**

Велику новину у ЗКП/2011 представља одредба чл. 486 ст. 2 која прописује да о захтеву за заштиту законитости који је поднет због повреде закона (чл.485 ст.1 тач.1, Врховни касациони суд не одлучује увек, већ само ако сматра да је реч о питању од значаја за правилну или уједначену

---

<sup>46</sup> Д. Суботић, „Недозвољени докази у кривичном поступку“, Судска пракса 3-4/2007, 69.

<sup>47</sup> Врховни касациони суд, Кзз 673/2014 од 10.07.2014. године.

<sup>48</sup> Врховни касациони суд, Кзз 152/2016 од 03.03.2016. године.

примену права. Према ставу теорије, правилна примена права претпоставља да је чињенично стање, које је и какво је утврђено у правноснажној одлуци, правилно подведено под одговарајућу правну норму, док уједначена примена права има велики значај за стварање устаљене судске праксе.<sup>49</sup>

Наведено правило из чл.486. ст.2. ЗКП би у пракси значило да је: (1) у ранијем поступку по захтеву за заштиту законитости Врховни касациони суд заузео став о одређеној повреди закона на којој је овлашћени титулар темељио свој захтев (својеврсни прецедент одн. правилна примена права); (2) да ће сваки следећи захтев за заштиту законитости који је подет због идентичне повреде закона бити одбачен без спровођења мериторног одлучивања, обзиром на опште правило да на идентичне ситуације треба применити идентична решења (уједначена примена права); (3) изузетно, ако суд сматра да постоје разлози за одступање од дотадашње праксе, узеће у мериторно разматрање овакав захтев и решити га у складу са начелом правичности (правилна примена права). Сматрамо да се на наведени начин ојачава улога судске праксе као формалног извора права (што може представљати квалитативни помак уз услов њене доступности ширем кругу лица), а истовремено се суд ослобађа сувишног мериторног одлучивања у истим односно сличним ситуацијама.

Навешћемо неке примере из судске праксе у вези са питањима повреде кривичног закона:

### **(1) Да ли је дело које је предмет оптужбе кривично дело**

Повреда одредбе чл.439. тач.1. ЗКП постоји уколико је суд повредио кривични закон, односно материјалноправне одредбе, по питању да ли је дело за које је окривљени оптужен кривично дело или не.

Врховни касациони суд је уважио захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца и утврдио да је пресудама Основног и Апелационог суда у Новом Саду повређен кривични закон у корист окривљеног, када је само на основу тога што одузета биљна материја рода *cannabis* садржи 0,018 % ТХЦ, дакле испод 0,3%, изведен правни закључак да иста не представља опојну дрогу због чега ни радња окривљеног не

---

<sup>49</sup> М. Шкулић, Г. Илић, *Нови законик о кривичном поступку Србије: како је пропала реформа : шта да се ради?*, Београд, 2012. 146-147.

садржи обележја кривичног дела из чл. 246а ст.1. Кривичног законика које му је оптужним актом стављено на терет. Ово стога, јер је за такав правни закључак, поред тога да биљна материја рода *cannabis* садржи испод 0,3% ТХЦ-а неопходно и да иста потиче од врсте и варијетета *cannabisa* који ни у ком случају не може садржавати више од 0,3% ТХЦ-а.<sup>50</sup>

**(2) Да ли је у погледу кривичног дела које је предмет оптужбе примењен закон који се није могао применити**

Повреда одредбе чл.439. тач.2. ЗКП постоји уколико је суд повредио кривични закон по питању да ли је у погледу кривичног дела које је предмет оптужбе примењен закон који се не може применити. Погрешна примена кривичног закона односи се, према пракси Врховног касационог суда, само на одредбе материјалног а не и процесног закона.<sup>51</sup>

Надаље, повреда ове одредбе, по правилу се односи на погрешну правну квалификацију (суд је дело правно квалификовао као једно а требало је као друго – оба из истог кривичног закона, или је дело квалификовао по једном а требало је по другом –блажем кривичном закону и слично), иако се не ограничава само на то.

У судској пракси је прихваћено да не може постојати стицај кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст.1 КЗ и истог кривичног дела из чл. 246 ст. 6 КЗ и учинилац неће бити оглашен кривим за оба кривична дела, већ само за једно кривично дело из чл. 246 ст.1 КЗ у ситуацији када је својим радњама остварио сва обележја кривичног дела из чл. 246 ст.1 КЗ, а поред тога поседује и супстанцу која је намењена за производњу сасвим друге опојне дроге од оне која је предмет кривичног дела из чл. 246 ст.1 КЗ.<sup>52</sup>

Како, радње из чл.246. ст.6 КЗ представљају радње усмерене на неовлашћену производњу опојне дроге, односно на припремање производње опојне дроге, а неовлашћена производња опојне дроге (као једна од алтернативно прописаних радњи) је инкриминисана чл.246. ст.1. КЗ, то

---

50 Врховни касациони суд, Кзз 63/2013 од 26.06.2013. године.

51 В. Крстајић, 36.

52 Правно схватање усвојено на заједничком састанку усаглашавања судске праксе представника кривичног одељења Врховног касационог суда и Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, одржаном у Крагујевцу дана 12.12.2017. године.

наведено указује да се у случају да су у остварена обележја овог дела из ст.1 и ст.6. од стране истог учиниоца, ради о привидном идеалном стицају, и да се неће применити одредбе о стицају из чл.60 КЗ.

### **(3) Да ли је одлуком о кривичној санкцији, о одузимању имовинске користи или о опозивању условног отпуста повређен закон**

Основ испитивања законитости правноснажне пресуде у погледу одлуке о кривичној санкцији, поводом захтева за заштиту законитости (чл. 485. ст.4. ЗКП) је само повреда закона у смислу чл.439. тач.3 ЗКП, која подразумева пре свега прекорачење овлашћења која суд има по закону доносећи ову одлуку, а не оцена суда о постојању и значају околности које су у смислу чл.54. ст.1. КЗ (олакшавајуће и отежавајуће околности) од утицаја на одлуку о врсти и висини кривичне санкције.<sup>53</sup>

Прекорачење овлашћења би постојало када би суд окривљеном за одређено кривично дело изрекао санкцију која није прописана за то кривично дело или кад санкцију одмери у висини која прелази границу прописаног максимума кривичне санкције за то кривично дело.<sup>54</sup>

Врховни касациони суд је утврдио повреду закона не дирајући у правноснажност пресуде у случају када је Апелациони суд изрекао окривљеном условну осуду за кривично дело насиље у породице (за које је предвиђена казна затвора у трајању од две до десет година), обзиром да је чл. 66 ст. 2 КЗ прописано да се за кривична дела за која се може изрећи казна затвора у трајању од 10 година или тежа казна не може изрећи условна осуда<sup>55</sup>

## **8. Повреда или ускраћивање људског права и слободе окривљеног или другог учесника у поступку**

Одредбом чл.485 ст.1 тач.3 Законика је прописано да се захтев за заштиту законитости може поднети ако је у правноснажној одлуци или одлуци у поступку који је претходио њеном доношењу повређено или ускраћено људско право ослобода окривљеног или другог учесника у поступку које је зајемчено Уставом или Европском конвенцијом о заштити људских права

---

<sup>53</sup> Врховни касациони суд, Кзз 1505/2016 од 31.01.2017. године.

<sup>54</sup> Врховни касациони суд, Кзз 566/2014 од 03.07.2014. године.

<sup>55</sup> Врховни касациони суд, Кзз. 1220/2014 од 18.12.2014. године.

и основних слобода и додатним протоколима, а то је утврђено одлуком Уставног суда или Европског суда за људска права.

До повреде или ускраћивања људског права и слободе зајемченог Уставом или Европском конвенцијом о људским правима може доћи у предистражном или кривичном поступку.

Пасивни субјект права и слободе јесте окривљени или други учесник у поступку (сведок, вештак, стручни саветник, тумач итд.), при чему је повреда или ускраћивање његовог права последица било које процесне радње органа поступка (реч је, дакле, о радњама доказивања, процесне принуде, одлучивања и руковођења поступком).<sup>56</sup>

Конечно, *conditio sine qua non* за подношење захтева за заштиту законитости по овом основ јесте одлука Уставног суда по уставној жалби односно одлука Европског суда за људска права по представи.

У поступку поводом уставне жалбе Уставни суд, осим што може донети одлуку којом утврђује да је оспореним појединачним актом или радњом повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом (а која је основ за улагање захтева за заштиту законитости на основу чл. 485 ст. 1 тач. 3 ЗКП-а), има и овлашћење да поништи појединачни акт (укључујући и судску одлуку), забрани даље вршење радње или одреди предузимање друге мере или радње којом се отклањају штетне последице утврђене повреде (нпр. да нареди понављање кривичног поступка) односно да одреди начин правичног задовољења подносиоца (чл. 89 ст. 2 Закона о Уставном суду).

У том смислу, у судској пракси су забележени случајеви да је Уставни суд, у одлуци по уставној жалби, осим што је утврдио повреду права окривљеног у кривичном поступку, истовремено и укинуо судску одлуку и наложио понављање жалбеног поступка у року од 60 дана од дана достављања одлуке.<sup>57</sup>

Уставни суд је, заправо, установио двојни механизам за отклањање штетних последица насталих утврђеном повредом људских права и слобода у кривичном поступку: (1) први, који се темељи на чл. 89 ст. 2 Закона о Уставном суду и који подразумева да сам Уставни суд, у поступку по уставној жалби, након што утврди повреду или ускраћивање људског права или слободе

---

<sup>56</sup> Г. П. Илић et al., Коментар Законика о кривичном поступку, 4. издање, Београд, 2013, 1035.

<sup>57</sup> УС - Уж. 94/09 од 05.07.2012. године. Слично томе и УС - Уж. 1285/2012 од 26.03.2014. године.

зајемчене Уставом, укине правноснажну судску одлуку и наложи понављање кривичног поступка и (2) други, који се темељи на чл. 485 ст. 1 тач. 3

Законика о кривичном поступку, а који подразумева да Уставни суд, у поступку по уставној жалби, само утврди повреду или ускраћивање људског права или слободе зајемчене Уставом, без задирања у правну снагу судске одлуке, а да отклањање штетних последица у истој остави на вољу заинтересованих лица којима је ЗКП-ом признато право на улагање захтева за заштиту законитости као ванредног правног лека у кривичном поступку.

У предмету Кзз 982/2014 Врховног касационог суда, бранилац окривљеног је поднео захтев за заштиту законитости из чл. 485 ст. 1 тач. 3 против правноснажне првостепене и апелационе пресуде и уз њега приложио одлуку Уставног суда којом је усвојена уставна жалба окривљеног и којом је: (а) утврђено да је правноснажном првостепеном и апелационом пресудом повређено право подносиоца уставне жалбе на правну сигурност у казненом праву зајемчено одредбом чл. 34 ст. 4 Устава Републике Србије, (б) поништена пресуда апелационог суда и (в) одређено да тај суд донесе нову одлуку о жалбама окривљеног и његовог браниоца на првостепену пресуду.

Код таквог стања ствари Врховни касациони суд је закључио: (1) да је наведеном уставном жалбом Уставни суд, на основу овлашћења из чл. 89 ст. 2 Закона о Уставном суду, ради отклањања штетних последица утврђене повреде права окривљеног, одредио меру са правним дејством уклањања из правног поретка правноснажне другостепене пресуде којом је та повреда учињена, те поменута пресуда дакле више не постоји; (2) да не постоје законски услови, у смислу чл. 482 ст. 1. ЗКП/2011, за подношење захтева за заштиту законитости против, у време подношења захтева, неправноснажне првостепене пресуде и непостојеће другостепене пресуде; (3) да такав захтев за заштиту законитости треба одбацити као недозвољен.<sup>58</sup>

## **9. Закључак**

Посматрајући постојећи правни оквир за испитивање законитости одлука Апелационих судова, можемо рећи да постоји сасвим коректна законска основа за отклањање евентуалних незаконитости у поступању и првостепених

---

58 Врховни касациони суд, Кзз 982/2014 од 09.10.2014. године.

и другостпених судова, применом ванредног правног лека захтева за заштиту законитости. Може се уочити да је законитост решавања кривичне ствари пред Апелационим судовима у уској вези са поступањем свих судских инстанци и да се у Апелационе судове практично „сливају“ одлуке свих судова. Због тога су законитост одлука и законитост поступања Апелационих судова од примарног значаја за примену принципа законитости и његову практичну реализацију у конкретним судским пресудама, при чему и одлуке Апелационих судова могу бити предмет преиспитивања од од стране Врховног касационог суда и Уставног суда. Можемо у целини гледано рећи да постојећа законска решења а и судска пракса иду у правцу заштите права окривљеног.

Међутим, неспорне су и бројне новине које је донео важећи Законик о кривичном поступку, посебно у законском одређењу захтева за заштиту законитости а у вези и са другим деловима кривичног поступка, које измене у одређеним деловима представљају и законски дисконтинуитет у односу на претходне прописе који су уређивали кривични судски поступак. Овом приликом поред указивања на судску праксу и законски оквир испитивања законитости судских одлика указано је и на неке недостатке у законским решењима и потребу „попуњавања одређених правних празнина“, како би се у још већој мери и квалитетније остварила реализација принципа законитости кроз судске одлуке и заштиту права свих учесника у кривичном поступку.

## Литература

1. Бачић Ф., *et al*, Коментар кривичног закона СФРЈ, “Савремена администрација”, 1988.
2. Васиљевић, Т., Грубач М., Коментар Законика о кривичном поступку, Београд, 2010, 919-920.
3. Бркић С., „Употреба незаконитих доказа у кривичном поступку Србије“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 1/2011.
4. Васиљевић Т., Грубач М., Коментар законика о кривичном поступку, „Савремена администрација“, 1987.
5. Висковић Н., Теорија државе и права, II. изм. и доп. изд., Биротехника, ЦДО, Загреб, 2006.
6. Грубач М., „Критика „Новог“ Законика о кривичном поступку“, *Ревизија криминологију и кривично право*, Vol. 44, бр. 2, Београд, 2006.
7. Важић Н., „Захтев за заштиту законитости према ЗКП Србије (основне карактеристике, могућности подношења, искуства у примени и мере унапређења“, Збо. Правни лекови у кривичном поступку - регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2016.
8. Илић Г., „Јавни тужилац у Србији као једини субјект права на подношење захтева за заштиту законитости - да или не?“, Збо. Правни лекови у кривичном поступку - регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2016.
9. Илић П.Г., „О захтеву за заштиту законитости у кривичном поступку“, *Казнена реакција у Србији - Део 2*, (ур. Ђ. Игњатовић), Београд, 2012.
10. Јанковић Д., „Прилог стручној расправи-примена начела *ne bis in idem* у судској пракси“, Билтен Врховног касационог суда, бр. 2/2017.
11. Крстајић В., „Судска пракса у поступку по захтеву за заштиту законитости“, Билтен Врховног касационог суда 2/2017.



12. Суботић, Д., „Недозвољени докази у кривичном поступку“, *Судска пракса* 3-4/2007.
13. Поповић Д., *Постанак европског права људских права* (превели В. и М. Јовановић), Службени гласник, Београд 2013.
14. Roxin C., Arzt G., Tiedemann K., *Strafrecht und Strafprozessrecht*, Heidelberg, 2013.
15. Симић-Јекић З., „Појам и функција правних лекова и њихово место у систему кривичног процесног права“, *Анали Правног факултета у Београду*, бр. 1-4/1983, Београд, 1983.
16. Tarello G., „Argumentacija tumačenja i sheme obrazlaganja u pridavanju značenja normativnim tekstovima“, *Zbornik za teoriju prava* IV, Beograd, 1990.
17. Цветковић Б., „Ванредни правни лекови и нови ЗКП“, *Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена*, Златибор-Београд, 2013.
18. Forkosch M.D. “The Nature of Legal Evidence”, *California Law Review*; vol. 59, 1971.
19. Шкулић М., Бугарски, Т., *Кривично процесно право*, Нови Сад, 2015.
20. Шкулић М., Илић Г., *Нови законик о кривичном поступку Србије: како је пропала реформа : шта да се ради?*, Београд, 2012.
21. Wildhaber L., „The European Convention on Human Rights and International Law“, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 56, 2007.

**Dragan Jocić**, President of the Appellate Court in Nis,  
judge at the Supreme Court of Cassation

**Dijana Janković**, PhD, judge of the Appellate Court in Nis

## COURT OF APPEAL AND LEGALITY OF THE SOLUTIONS TO CRIMINAL MATTERS

**Abstract:** The principle of legality in criminal law is a part and a general expression of legality as a criminal law principle. This paper, primarily discusses the issue of controlling the legality of judicial decisions as individual legal acts. In the appeal procedure, this control, and therefore the protection of the rights of the parties, is carried out by the Court of Appeal, while the decisions of the Appellate Courts are also subject to the control of legality in the procedure for extraordinary remedy at the request for protection of legality. As the request for the protection of legality is the most important extraordinary remedy, based on which the legality of all court decisions (both first instance and second instance decisions) is examined, the subject to discussion will be the case law of the Appellate Courts and the examination of the legality of their decisions by application of the request for protection of legality before the Supreme Court of Cassation of the Republic of Serbia. There is also the review of certain decisions of the Constitutional Court which annul not only the decisions of the first instance judges but also the decisions of Appellate Courts in the procedure for constitutional appeal when their constitutionality and legality is examined.

**Key words:** principle of legality, request for protection of legality, criminal proceedings, violation of the law.

Др Дијана Јанковић,

судија Апелационог суда у Нишу

### **Пракса судова, искуства у примени и коришћењу ДНК вештачења у кривичном поступку**

**Резиме:** У излагању је дат преглед примене ДНК вештачења у домаћој судској пракси и указано на неке проблеме у вези оцене овог доказа и интерпретације ДНК налаза и мишљења од стране вештака пред судом. Такође је извршен осврт на домаћу кривичноправну регулативу, питање ДНК базе податка као и нека решења у упоредном праву. У овом раду смо покушали да дамо одређене одговоре у погледу значаја, примене и перспективе ове врсте вештачења имајући у виду Законик о кривичном поступку и постављене међународне стандарде.

**Кључне речи:** ДНК вештачење, биолошки материјал, кривични поступак.

### **Увод**

Примена ДНК анализе у оквирима савремених система кривичног правосуђа има све значајнију примену у судској пракси. Форензика је примењена наука која анализира материјалне трагове пронађене на месту извршења кривичног дела са циљем да утврди везу између нађеног трага и кривичног дела, као и да открије порекло конкретног материјалног трага.<sup>59</sup> У најширем смислу, форензика подразумева примену знања и технологија из различитих наука у решавању правних питања. Форензичка биологија врши серолошке и ДНК анализе физиолошких течности и ткива, с циљем идентификације и индивидуализације јединки, животиња или микроорганизама.

Анализа ДНК у кривичним поступцима користи се када постоји вероватноћа да ће се анализом ДНК прибавити докази важни за вођење кривичног поступка. Управо је анализа ДНК у кривичноправном систему довела до унапређења технологије вештачења биолошких трагова, а све у

---

59 Врховни касациони суд, Кзз 566/2014 од 03.07.2014. године.

циљу откривања учинилаца кривичних дела односно ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања.<sup>60</sup>

Када је у питању форензички аспект, ДНК анализа зависи од чињенице да ли је на лицу места остао неки биолошки траг. У том смислу, биолошки траг представља биолошку материју, видљиву или невидљиву, пронађену на месту извршења кривичног дела; тј. сваки траг хуманог, анималног или биљног поријекла који се пронађе на месту догађаја<sup>61</sup>.

Међутим, улога форензичара није само да сакупи и анализира доказе, већ и да их представи и протумачи на суду. Тада се област науке стапа са областима рада полиције, правосуђа, и ширим политичким друштвеним и економским оквиром у коме се сви они налазе.

Један од изазова који се тиче форензичке анализе ДНК у сврхе решавања кривичних дела јесте објашњавање лабораторијских резултата на суду, тј. пред лицима која форензику и њене методе и технике, посматрају са аспекта доказног средства и начина за утврђивање одређених правнорелевантних чињеница у конкретном судском предмету. Форензичари се као експертски сведоци сусрећу с потешкоћама на суду, када покушају да „објасне” судијама и поротама везу међу доказима које пружа невидљива молекуларна технологија.

Правосуђе захтева сигурност а форензика може да пружи само вероватноћу. Да би се обезбедили чвршћи ДНК докази за потребе кривичних случајева морамо се позабавити како научним тако и правним питањима.

Да би се могућности ДНК анализе максимално искористиле у правосуђу, потребно је ово питање адекватно правно регулисати и створити све предуслове за формулисање националне ДНК базе података. Такође, примена ДНК анализе у правосуђу у великој мери зависи од сарадње између свих субјеката који је примењују од истраге до правноснажнм окончања поступка. Њихова сарадња не обухвата само рад на месту извршења кривичног дела, у вези са конкретним предметом и обављеним вештачењем, већ и сарадњу у оквиру процеса доношења одговарајућих законских прописа (нпр. Закон о примени ДНК анализе, Закон о ДНК базама података или проширени Закон о кривичном поступку који би обухватао и подручје ове методе).

---

60 Врховни касациони суд, Кзз 566/2014 од 03.07.2014. године.

61 Врховни касациони суд, Кзз 566/2014 од 03.07.2014. године.

У даљем току излагања биће више речи о проблемима који се отварају у судској пракси у вези интерпретације пред судом од стране вештака резултата обављених ДНК анализа и коришћења тих резултата у доказне сврхе. Такође ће бити извршен осврт на примере из судске праксе у којима је ДНК вештачење дало значајан допринос расветељењу и решењу кривичне ствари, као и на законска решења у Законику о кривичном поступку Републике Србије и нека искуства из упоредног права о примени ДНК вештачења у кривичном поступку.

### **Примена ДНК вештачења у судској пракси**

Анализа ДНК у кривичним случајевима обично се користи за идентификацију окривљених или оштећених у кривичном поступку, упоређивањем њихове ДНК са материјалним доказима са места извршења кривичног дела (уколико таквих трагова има у конкретном предмету). У домаћој судској пракси ДНК анализа вршена је успешно код појединих тежих случајева разбојништва и разбојничке крађе, неовлашћеног стављања у промет опојних дрога, као и кривичних дела убиства.

Идентификацији окривљених путем ДНК анализе, врши се тако што се узорци крви, корена косе, пљувачке, слузи, коже, сперме или вагиналних течности (или узорак било које ћелије са једром) узимају са места извршења дела или места које се може довести у везу са окривљеним или жртвом кривичног дела (место пребивалишта или боравишта окривљеног или оштећеног, возило које су ова лица користила, гардероба, предмети са којима су одређена лица имала контакт и др.). ДНК се потом екстрахује из тих узорака и упоређује са узорцима узетим од осумњичених. У државама у којима постоје базе ДНК, упоређују се спорни узорци са неспорним узорцима у тим базама.

Тако је у пресуди Апелационог суда у Нишу Кж1 337/2014 од 28.07.2014. године, потврђен став првостепеног суда да се на основу налаза Универзитета у Београду, Биолошки факултет утврђује, да је поређењем ДНК профила Ј.Г., мајке окривљеног Ј.П. са ДНК профилима испитиваних трагова, да „ДНК профил означен као мушка особа НН1, испуњава услове за ДНК профил сродника првог степена. На основу статистичке обраде добија се вредност (Кумулативни индекс вероватноће), од 25.899 који би питање потенцијалног

мајчинства резултовао вероватноћом од 99,996 % на основу чега се може са јасном извесношћу говорити о сину Ј.Г. као НН1 особи.“

Поред тога, у наведеном предмету међународна сарадња је била од великог значаја. Конкретно у поменутом случају су на лицу места пронађени предмети са којих је узоркован биолошки материјал. Исти је путем МУП-а РС Управа криминалистичке полиције – Одељење за међународну полицијску сарадњу, Национални централни биро ИНТЕРПОЛ-а Београд послат француској Амбасади ради провере ДНК материјала, због сумње да припадају једном од осумњичених лица. Амбасада Француске у Београду је доставила обавештење да је ДНК профил који је достављен и који је био предмет замолнице упућен од стране наших правосудних органа, правосудним органима Републике Француске, идентичан ДНК профилу осумњиченог лица Ј.П. У ДНК бази Републике Француске је био сачуван ДНК материјал осумњиченог јер је исти због насилничког понашања према службеном лицу у Француској осуђен на удаљење из Француске и забрану боравка на француској територији у периоду од 5 година.

Након тога је даљим анализама и истом предмету утврђено, да се на предметима са којих је биолошки материјал узоркован на лицу места утврђује да постоји јединствени допринос истог окривљеног Ј.П. Према налазу и мишљењу вештака окривљени се уочава се као „већински доприносилац трагова“. Што се тиче узорка који представљају мешане ДНК профиле за које је наведено да се варијанте ДНК профила окривљеног уочавају, вештак је нашао да ако би се процењивала вероватноћа доприноса она би за посматрани узорак била „на осам генских локуса већа од 9.132 уз три доприносиоца“. Суд је прихватио наведени степен вероватноће, у погледу утврђивања идентитета окривљеног, јер је исти цењен и у односу на остале узорке у којима је констатован ДНК профил окривљеног, као и у вези са осталим изведеним доказима.

Када је реч о одлукама, тј. пресудама у случајевима у којима је ДНК доказ од значаја за утврђивање кривице окривљеног, пре свега кроз утврђивање његовог идентитета као извршиоца, може се уочити да не постоји уређен оквир за одређивање довољне количине биолошког материјала у којима се користи статистичка вероватноћа поклапања између оптужениковог ДНК профила и узорка са места злочина. Има мишљења, да би судови требало да примене одређени квантитативни праг према коме шансе да је оптужени

извор нађене ДНК би требало да прелазе вероватноћу од 1 у 1000.<sup>62</sup> Сматрамо да ДНК докази морају бити искоришћени у спрези са другим доказима, и не могу бити примарни доказ нечије кривице. Поклапање ДНК може само потврдити да је особа била на месту извршења кривичног дела или да је била у контакту са жртвом, а не може само по себи бити доказ нечије кривице.

Често се тврди да је лакше искључити некога као осумњиченог него га осудити на основу ДНК доказа.

Када је у питању трансфер биолошког материјала, поставља се питање често у судској пракси да ли је могуће пренети биолошки материјал и на који начин? Према наводима вештака у обављеном вештачењу у предмету Апелационог суда у Нишу Кж1 432/2018 од 22.08.2018. године, “трансфер биолошког материјала је могућ примарним контактом донора биолошког материјала и површине на коју депонује материјал, секундарним трансфером путем једног посредника, или терцијарним трансфером путем два посредника”.

У предмету Апелационог суда у Нишу Кж1 3420/2010 од 17.12.2010. године, потврђена је првостепена пресуда због кривичног дела тешко убиство из чл.114 тач.1 и тач.5. Кривичног законика. У конкретном случају окривљени је оглашен кривим да је, на подмукао начин и из користољубља, лишио живота своју маћеху, на тај начин што је, када су дошли до винограда, узео дрвени колац дужине око једног метра и дебљине људске руке и са леђа два пута ударио оштећену у пределу потиљачног дела главе, од чега је она пала не дајући знакове живота, а затим је запалио...” На лицу места су пронађени трагови у виду кости са траговима крви. За суд је у конкретном случају било значајно пре свега да утврди да ли трагови пронађених костију припадају покојној оштећеној. Обављено је ДНК вештачење. Суд је наредбом поставио задатак вештацима да се утврде као неспорни узорци ДНК профил окривљеног, затим рођене сестре и рођеног брата покојне оштећене и да се исти упореде са ДНК профилима из достављених трагова, узоркованих на лицу места као и остацима костију пронађених на месту извршења дела. Анализом кости - две кости налик на људске виличне кости, пронађене на месту извршења дела утврђено је да је - добијен је ДНК профил НН особе женског пола. Статистичком обрадом добијених резултата а на основу учесталости одређених алела ана-

---

62 Врховни касациони суд, Кзз 566/2014 од 03.07.2014. године.

лизираних генских фокуса налазом је констатовано да кости које су пронађене и достављене на анализу могу припадати са високом сигурношћу рођеној сестри лица чији је ДНК профил испитан (брат и сестра покојне оштећене).

Вештак молекуларни биолог, УКП Национално криминалистичко техничког центра у Београду, изјавила је: “да ДНК профил са кости одговара идентитету сестре неспорних узорака њених рођених брата и сестре, као и да је анализом трагова костију утврђено присуство крви људског порекла”. Што се тиче биостатистичке вероватноће вештак је навела, да се за лице ДНК профила утврђеног на основу достављених узорака костију, може рећи да је 28 милиона пута вероватније да је особа са оваквим профилем рођена сестра испитиваних лица, него да није њихова сестра”.

Посебно је значајно питање за судску праксу питање контаминације (деградације) биолошких трагова. Контаминација биолошких трагова је могућа у свим фазама увиђаја и касније истраге, тј. приликом претраживања места догађаја, приликом обављања увиђаја, проналаска, узимања, паковања биолошких трагова. Трагове је могуће контаминирати страним биолошким материјалом (односно, материјалом пореклом од особа које узимају узорке), међусобним контактом спорних трагова те међусобним трагом спорних трагова и неспорних узорака.

У предмету Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж1 По1 7/2012 од 29.06.202. године, суд се бавио између осталог и питањем могућности деградације (контаминације) ДНК трагова услед изложености високим температурама и питањем који спољашњи услови могу утицати на разградњу ДНК материјала. ДНК вештачење је било обављено од стране Национално-криминалистичко техничког центра у Београду те је вештак навела да је биолошки материјал постојан и да је могуће добити ДНК и са “изгореле ручице”, те из исказа вештака произилази да се ДНК трагови могу сачувати на високим температурама у зависности од количине материјала, дужине изложености топлоти, да је за анализу ДНК материјала довољан и један нанограм, те да спољни утицаји могу деградирати биолошки траг, али је могуће да и поред пожара, воде и кише остане материјал за анализу.

Најчешћи предмети ДНК вештачења, у судској пракси су крв и телесне излучевине, длаке и коса. На основу чињенице да ли је познато коме припада биолошки траг, он се означава као неспоран или споран. Спорни узорци су узорци пореклом од особе чији нам идентитет није познат, а пронађени су



на месту догађаја, на предметима или лицима која су повезана са местом догађаја или учињеним кривичним делом. Анализом спорних узорака утврђују се форензички ДНК профил, а за потврђивање од кога потичу потребно је имати неспорне (референтне) узорке за упоређивање. Неспоран узорак је биолошки материјал особе чији нам је идентитет познат; ради се о осумњиченима, оштећенима и свим осталим лицима која су могла доћи у контакт с траговима или предметима на месту догађаја.<sup>63</sup>

Такође, материјал вештачења који се најчешће узима за анализу ДНК приликом утврђивања постојања кривичног дела и идентитета окривљеног су пре свега средства извршења дела, разни употребљени предмети које је учинилац оставио на месту догађаја. Ако нису пронађени видљиви биолошки трагови у сврху анализе ДНК се често узимају рубови и хrapаве површине средства извршења кривичног дела (нпр., штап, провалнички алат и сл.), као и површине за које се претпоставља да су у контакту с телом (нпр. капа, кацига, одбачена одећа и сл.) или употребљени предмети учиниоца остављени на мјесту догађаја (нпр. Мобилни телефон, наочаре, кључеви и сл.).

### Проблеми у интерпретација ДНК вештачења у кривичном поступку од стране вештака

„Традиционални циљ науке јесте долазак до *истине*, док је циљ правосуђа достизање *правде*“.<sup>64</sup> Овај цитат добро сумира проблеме у судској пракси који се тичу интерпретације ДНК доказа.

Можемо поменути нека од питања која се постављају пред судом у кривичним предметима и у којима значајну улогу има обављено ДНК вештачење.

Да ли постоје материјални трагови на основу којих се може закључити да се одређено лице, најчешће окривљени (иако се то питање може односити и на оштећеног, сведока или другог учесника кривичног поступка) налазило на месту извршења дела? Да ли је могућ трансфер биолошког материјала?

63 Wonder A.Y. /2015/: Bloodstain Patterns: Identification, Interpretation and Application, 1st Edition. Cambridge: Academic Press, pp 33-55

64 Thornton J. I and Peterson J. L /1997/: The General Assumptions and Rationale of Forensic Identification, in Modern Scientific Evidence: The Law and Science of Expert Testimony, p.4

Да ли је лице чији се биолошки трагови испитују имало контакт са одређеним лицима (нпр. да ли је на телу или гардероби окривљеног или оштећеног било њихових ДНК трагова и да ли то указује на то да је остварен контакт између окривљеног и оштећеног или других лица) или са одређеним предметима (нпр. на пакетићима са опојном дрогом, предметима у којима су биле одређене инкриминисане супстанце или су спорни предмети преношени)?

Да ли чињеница да нпр. на телу или гардероби оштећеног или сведока нису констатовани ДНК трагови окривљеног и обрнуто, указује да међу тим лицима није било никаквог контакта?

Који степен вероватноће је релевантан за суд, да је дошло до наведених контаката, када вештаци у ДНК вештачењу констатују да постоји одређен степен доприноса биолошког материјала или да се тај “допринос не може искључити”? Шта значи да се “допринос биолошког материјала не може искључити” да ли га је било или га није било. Као и термини “релативно већински доприносилац”, “релативно јасно издваја” и сл.

Даље, једно од питања би било да ли би суд могао у наредби за вештачење наредити одређену технику ДНК вештачења и од каквог би то утицаја било на крајњи резултат, у погледу веће вероватноће и поузданије идентификације предмета вештачења?

За суд су наведене чињенице значајне ради доношења закључка о томе да ли откривени трагови указују на то да постоји веза између окривљеног са местом или предметима извршења дела или такви трагови не постоје. Погрешно је мишљење које се може срести, да суд до закључка о кривици окривљеног долази само на основу налаза и мишљења ДНК вештачења, као и да је за суд важно да мишљење вештака подржи оптужбу, јер суд наведени доказ (ДНК вештачење) цени у склопу и у вези са осталим изведеним доказима, при чему све доказе цени подједнако и непристрасно и у односу на оптужбу и одбрану. Међутим, за суд је значајно да добије што конкретније одговоре од вештака, ради оцене веродостојности и доказне снаге ДНК вештачења.

У супротном ако ДНК вештачење остане само у домену недефинисане вероватноће и вештак не буде дао суду адекватну анализу добијених резултата, ДНК вештачење губи доказну снагу и као доказ и као доказно средство које ће бити коришћено у кривичним поступцима.

Не ретко ће се срести у току кривичног поступка, да вештак биолог при објашњавању свог налаза и мишљења ДНК вештачења, на конкретна питања суда која су оквиру правног домена, поново објашњава сам поступак и технику обављања ДНК вештачења и улази у домен научне експертизе, који је већ објашњен у основном налазу и мишљењу. При чему, на конкретна питања суда, нпр. да ли су трагови крви на одећи окривљених (који су били предмет ДНК вештачења) људског или животињског порекла, која је старост трагова, да ли је урађена анализа крви и да ли се може утврдити порекло, крвна група тј. да ли се трагови крви који су нађени на гардероби окривљених могу довести у везу са окривљеним или оштећеним, вештак биолог остаје у домену налаза без да на крају да и стручно мишљење у вези са конкретним питањем. На тај начин суд се доводи у ситуацију да анализира научну експертизу и изјашњење вештака и да сам долази до стручног мишљења које је вештак дужан да изнесе на крају свог налаза.

Наведено указивање, је усмерено у правцу остварења боље сарадње и разумевања између суда и вештака биолога и указивања на неке проблеме са којима се судови сусрећу, а ради њиховог отклањања и што веће ефикасности и квалитета судског поступка.

ДНК вештачења су за домаће судове углавном ново доказно средство, које је потребно приближити судовима и кроз едукацију судија у том правцу, али и кроз приближавање вештака судском поступку у погледу интерпретације ових доказа.

Употреба научних доказа, као што су ДНК вештачења, доводи до сарадње две научне области (природних и правних наука) и две институције (суда и универзитетских или стручних установа), које ван тога имају значајно различите циљеве и нормативне обавезе. То наравно не значи да немају додирних тачака, при чему у судском поступку, ни наука ни суд нити задржавају нити у потпуности одустају од своје аутономије. Међутим, наука која је у “служби” закона и судског поступка није у у истом положају и не презентује се на исти начин као наука која има за циљ да унапреди или изложи неко ново научно достигнуће. Са друге стране, када суд тражи “помоћ” науке ради бољег утврђивања неке чињенице, никада не излази из своје обавезе да утврди тачност појединих чињеница.<sup>65</sup>

65 Jasanof S. /2006/: Just Evidence: The Limits of Science in the Legal Process, Journal of Law, Medicine and Ethics, pp. 328-341.

Полазна тачка за успостављање равнотеже између очекивања науке и права, је да наука и вештаци прихвате да у судницу улазе не у облику голих чињеница или тврдњи, већ као доказ.

То значи да вештачења, пре свега ДНК вештачања, морају бити заснована на одређеним врстама предлога, презентацијама или материјалним чињеницама, који су за суд и закон прихватљиви за утврђивање што поузданијих чињеница.

У савременој анализи ДНК при раду на кривичним случајевима статистички се одређује вероватноћа да две особе деле исти профил тако што се утврђује колико је учестао генотип или скуп генотипа у оквиру популације. Међутим, ма који да је тренутни ниво сигурности код потврђивања идентитета особе на основу генетичке идентификације, судије и поротнике, вештаци би требало адекватно да упуте у вези са степеном вероватноће која се односи на идентификацију одређеног лица.

Што се тиче интерпретације мешаних ДНК профила у раду на кривичним случајевима, иако је сасвим стандардизован приступ непожељан, неке смернице и боље дефинисање јесу потребни како би се обезбедила валидна и поуздана интерпретација.

### **Кривичноправни аспект примене ДНК анализе**

Генетска наука, посебно путем технике идентификације засноване на ДНК профилима, добила је значајну улогу вођењу истрага и решавању бројних кривичних случајева. За нешто више од двадесет пет година, биолошка вештачења прешла су из статуса нове и спорне доказне методе у статус једне од најважнијих и најпримењиванијих доказних радњи у судским поступцима. Иако се допуштеност ДНК доказа у кривичном поступку више не доводи у сумњу, њихова употреба наставља да покреће нова питања о веродостојности доказа у погледу идентитета лица утврђеног путем ДНК вештачења и њиховој доказној снази, и, у ширем смислу, о ослањању закона на науку ради утврђивања истине.

За разлику од форензичког аспекта примене ДНК анализе, који се односи на њену конкретну примену у пракси, кривичноправни аспект примене ДНК анализе се односи на законску регулативу којом је регулисана њена примена. Она подразумева што јасније и прецизније законско уређење начина примене

ДНК анализе у правосудју, јер је позната чињеница да без адекватног закона и успостављања националне ДНК базе података није могуће искористити све могућности ДНК анализе у форензичком смислу. Најбитније је да се у свим државама правни основ сакупљања ДНК узорака законски регулише, како би ова врста доказа добила на чврстину.

У Србији је донет предлог Закона о националном ДНК регистру, којим се уређује успостављање и садржина националног ДНК регистра резултата форензичко-генетичке анализе ДНК за потребе кривичног поступка, утврђивања идентитета несталих или непознатих лица и др.

Законик о кривичном поступку Републике Србије,<sup>66</sup> прописује у чл.141 “Узимање узорака биолошког порекла” и у чл.142 “Узимање узорака за форензичко-генетичку анализу”. Тако је одредбом чл.142 ст.1 Законика о кривичном поступку прописано да ако је потребно ради откривања учиниоца кривичног дела или утврђивања других чињеница у поступку, јавни тужилац или суд може наредити узимање узорка за форензичко-генетичку анализу: 1) са места кривичног дела и другог места на коме се налазе трагови кривичног дела; 2) од окривљеног и оштећеног, а под условима предвиђеним у члану 141. став 2. овог законика; 3) од других лица ако постоји једна или више карактеристика која их доводи у везу са кривичним делом.

Посебну новину домаћем кривичнопроцесном законодавству представља и одредба чл. 142. ст.2. Законика о кривичном поступку којом је прописано да у одлуци о изрицању кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, првостепени суд може по службеној дужности одредити да се узорак за форензичко-генетичку анализу узме од: 1) окривљеног коме је за кривично дело учињено са умишљајем изречена казна затвора преко једне године; 2) окривљеног који је оглашен кривим за умишљајно кривично дело против полне слободе; 3) лица коме је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења.

Употреба ДНК доказа при решавању кривичних случајева почела је крајем 1980- тих, у кривичном поступку у коме је окривљени из Портланда у Орегону (САД) оптужен за силовање своје малолетне ћерке која је након тога затруднела. У том поступку је урђено вештачење и утврђено да се ДНК са узорака ткива фетуса се поклапао са ДНК оптуженог.

---

<sup>66</sup> Законик о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014).

У Великој Британији ДНК анализа је први пут употребљена у случају у коме је окривљени ослобођен од оптужбе за силовање и убиство две малолетне девојке, након што се његова крв није поклапала са узорцима сперме нађеним на местима злочина. Том приликом, тестирано је више од 4.000 мушкараца и на крају је, уз помоћ ДНК анализе, пронађен извршилац дела, који је за исто дело је осуђен 1988. године, и то је први британски случај у коме је пресуда донесена на основу ДНК доказа. Временом су усавршене нове технике биолошког вештачења, а 1995. године је основана Државна база ДНК Британије (UK National DNA Database),<sup>67</sup> прва државна база ДНК у свету. Америчка база ЦОДИС је основана 1994. али није спроведена у свим државама до 1998. године.

Средином и крајем деведесетих година двадесетог века почеле су се у појединим државама формирати компјутерске базе података ДНК профила учиниоца кривичних дела са циљем да се још више повећа ефикасност нове методе. Све базе података ДНК профила састоје се из два основна дела: 1) од неидентификованих ДНК профила тј. базе података ДНК профила добијених из биолошких материјала (трагова) фиксираних са лица места кривичних дела и 2) базе података познатих донатора тј. лица чији се ДНК профили компарирају са неидентификованим траговима.

Други део ДНК базе тј. база познатих донатора се у различитим државама на различитим начинима одређује. У неким њу могу да сачињавају ДНК профили осумњичених лица, у другима само ДНК профили само осуђених лица. У појединим државама се у овај део базе уносе подаци лица која су осуђена само за одређена кривична дела, или пак на одређене казне затвора. С обзиром на осетљивост материје, постоји тенденција да се узимање узорака за ДНК вештачење и унос података у компјутерске базе детаљно регулише законом (најчешће законима о кривичном поступку, или у полицијским законима).

Као што је поменуто у Европи је прва база података ДНК профила учинилаца кривичних дела установљена у Великој Британији. Национална база ДНК Велике Британије се данас сматра највећом базом података ове врсте у свету. У њој се налазе генетски профили од око 600 000 учинилаца кривичних дела и недељно се изврши око 600 идентификација. Коришћењем базе података разрешено је 40% случајева у којима су ДНК узорци прибављени

---

<sup>67</sup> Gill P., Jeffreys A. J and Werrett D. J. /1985/: Forensic Application of DNA "Fingerprints", Nature, Vol. 318, p. 577.

са места извршења кривичног дела. У Британији се унос у државној ДНК бази података не може уклонити када је једном начињен.

Колико је овај сегмент форензичке науке битан, сведоче и многобројне препоруке које долазе од међународних тела из Европске уније, затим Интерпола, ENFSI, ISFG и сл. У највећем броју, ови међународни субјекти објављују препоруке и смернице које усмеравају примену ДНК анализе у правосуђу, те упућују на који начин је најбоље правно/законски регулисати. Другим речима, то представља „добру праксу“ земаља које су развиле напредан механизам примене ДНК анализе у правосуђу која се покушава пренети на друге државе које то нису учиниле.

Препоруке Савета Европе из 1992. године указују на могућности и начине примене ДНК анализе у правосуђу, и може се рећи да представљају иницијалан, али веома користан сет инструкција. Један од важнијих докумената јесте и Резолуција о размени ДНК података међу државама коју је издао Савет Европске уније (2009. године). Надаље, Европска мрежа форензичких института (ENFSI) једном годишње издаје нове препоруке везане за целокупан менаџмент националних ДНК база података. Поред тога, и Међународно удружење форензичких генетичара (ISFG) даје препоруке о многим детаљима који се односе на форензичку ДНК анализу. Такође, и регионални ДНК експерти велику пажњу посвећују питању примене ДНК анализе у правосудним системима држава у региону.

### **Закључак**

Неспорно је да форензичка наука наставља да свакодневно открива нове начине “потврђивања јединствености” биолошког материјала, међутим, са аспекта доказног поступка, посебно кривичног поступка, сматрамо да би тренутни стандарди и норме прихватљивости ДНК доказа морали бити јасније правно дефинисани како би они важили као чврст доказ на суду.

Да би ДНК докази били поуздани у сваком појединачном случају мора се постићи уједначеност по питању техничких стандарда везаних са генетичке системе и статистичке методе процене, које ће бити изнете пред суд. Осим тога, било би важно да постоје и процедурални стандарди везани за акредитацију лабораторија, лиценцирање вештака и њихово тестирање знања.

Потешкоће са којима се судови и форензичари сусрећу настају услед различитих принципа који важе у правосуђу и науци уопште, као и у форензичкој анализи ДНК. Правосуђе захтева сигурност, док са друге стране наука допушта вероватноћу и сумњу. Међутим, будући да се ДНК посматра као доказ који директно доказује биолошку индивидуалност, а савремене технике анализе ДНК могу да понуде само процене вероватноће по питању индивидуализације, мора се наставити рад на развијању технологија које ће повећати извесност при личној идентификацији.

Са друге стране треба развијати и кривичноправни аспект ДНК анализе и законску регулативу. Стандарди прихватљивости на суду, као и техничке и процедуралне норме, требају се у што већој мери правно одредити.

Такође, сматрамо да би било значајно домаће стандарде ускладити са стандардима на међународном нивоу, јер се приликом пружања међународне помоћи у кривичним стварима у неким предметима захтевају подаци из ДНК база држава у којима се ти подаци воде и њихово коришћење у домаћим кривичним поступцима, тако да би било корисно постићи регулисање употребе анализе ДНК у форензичке сврхе међу различитим државама.

Поред тога, од несумњивог значаја је обезбедити стручност службених лица која прва долазе у контакт са биолошким материјалом који ће бити предмет ДНК вештачења. Ово стога, што првобитна испитивања места извршења кривичног дела и узорковање биолошког материјала, са спорних површина и предмета, врше полицијски истражитељи и техничари, а у каснијим етапама истраге употребом физичких доказа управља тужилаштво или одбрана, зависно од тога ко предлаже одређене доказе. Докази се могу погрешно тумачити ако њима не рукују за то обучена лица, што онда може довести до даљих грешака у процени њиховог значаја или узорковања, а затим и грешака у одлучивању судова. При томе је значајно сачувати доказе од контаминације и омогућити суду да на правилан начин оцени њихову доказну снагу.

На крају поменули бисмо и то да постоје многа етичка питања која се тичу осуда донесених на основу метода ДНК анализе које, у овоме тренутку, могу да понуде само одређене степене вероватноће. Постоји и проблем приватности појединаца, нарочито када је реч о окривљенима који су ослобођени од оптужбе, лицима која су учествовала у истрази само као сведоци, или којима је узет узорак ДНК у сврхе елиминације.

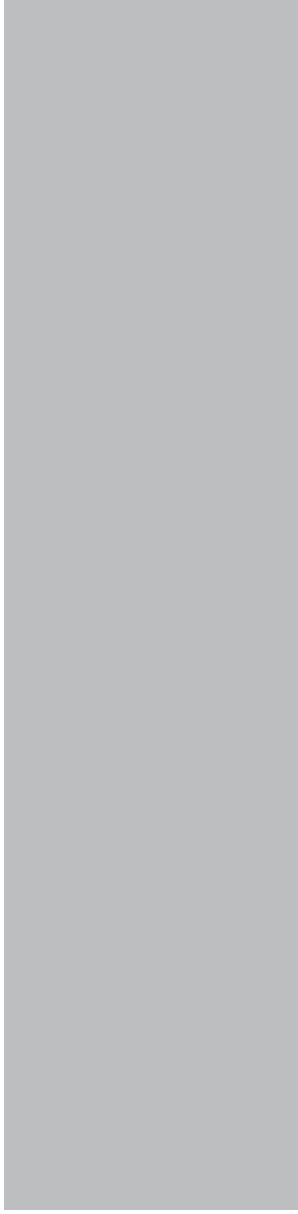


### Литература:

1. Balding D. /2005/: Weight of Evidence for Forensic DNA Profiles, Chichester, West Sussex.
2. Butler, J. M. /2010/: Fundamentals of Forensic DNA Typing. San Diego:Elsevier Academic Press.
3. Carracedo A., Rodriguez-Calvo M. S, Pestoni C., Lareu M. V, Bellas S., Salas A., and Barros F./1997/: Forensic DNA Analysis in Europe: Current Situation and Standardization Efforts, Forensic Science International, No. 86, pp. 87-102.
4. Cole S. A. /2009/: Forensics without Uniqueness, Conclusions without Individualization: The New Epistemology of Forensic Identification, Law, Probability and Risk, Vol. 8, Issue 3, pp.233-255.
5. ENFSI DNA Working Group /2012/: DNA Database Management – Reviews and Recommendations.
6. Gill P., Jeffreys A. J and Werrett D. J. /1985/: Forensic Application of DNA “Fingerprints”, Nature, Vol. 318.
7. Jasanof S. /2006/: Just Evidence: The Limits of Science in the Legal Process, Journal of Law, Medicine and Ethics, pp. 328-341.
8. Kaye D. H. /2009/: Probability, Individualization, and Uniqueness in Forensic Science Evidence:Listening to the academics, Brooklyn Law Review, Vol. 75, No. 4, pp. 1163-1185.
9. Koehler J. and Saks M. J /2010/: Individualization Claims in Forensic Science: Still Unwarranted, Northwestern University School of Law: Public Law and Legal Theory ResearchPaper Series, No. 11-18.
10. Марјановић,Д., Добрача, И. и Дробнич К. /2005/: Прикупљање, презервација и транспорт узорка за ДНК анализу, Сарајево INGEB.
11. Приморац Д., Приморац Д, Буторац С-С, Адамовић М./ 2009/: Анализа ДНА у судској медицине, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, 6(1), стр. 3-26.
12. Roth A. L. /2010/: Safety in Numbers? Deciding When DNA Alone is Enough to Convict, Berkley Law Scholarship Repository, pp. 1135-1158.
13. Сретенов Ј. /2014/: У којој мери ДНК може пружити чврст доказ? Crimen (V), 2/2014, стр. 231–239.
14. Thornton J. I and Peterson J. L./1997/: The General Assumptions and Rationale of Forensic Identification, in Modern Scientific Evidence: The Law and Science of Expert Testimony.
15. Wonder AY. /2015/: Bloodstain Paterns: Identfcaton, Interpretaton and Applicaton, 1st Editon. Cambridge: Academic Press, pp 33-55



# **ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА**





## **ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА**

представника кривичних одељења Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, у присуству представника Кривичног одељења Врховног касационог суда, на заједничким седницама одржаним у току 2017. године, око спорних питања од значаја за функционисање судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе (члан 24.став 3. Закона о уређењу судова- “Службени гласник РС” бр.116/08.....101/13).

### **ЗАКЉУЧЦИ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИКА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА И ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, ОДРЖАНЕ У НОВОМ САДУ, ДАНА 30.03.2018. ГОДИНЕ**

#### **I**

**Одговори Врховног касационог суда на питања око којих апелациони судови нису постигли сагласност на претходној заједничкој седници:**

#### **1. Питање:**

Да ли смрт фетуса од бремените жене који је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, а које је наступило услед извршења кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251 КЗ, представља смртну последицу у смислу кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259 став 2 и става 4 КЗ?

#### **Одговор:**

Смрт фетуса од бремените жене који је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, а које је наступило услед извршења кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл.250 КЗ, не представља последицу у вези наступања смрти једног или више лица као обележја кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл.259.став 2 и став 4 КЗ.

### **2. Питање:**

Да ли након доношења решења којим је од стране другостепеног суда на основу одредбе чл.458 ст.4 ЗКП, продужен притвор према окривљеном до даље одлуке првостепеног суда, првостепени суд је у обавези да одмах по пријему списка предмета од другостепеног суда поново испитује да ли још постоје разлози за притвор и да донесе ново решење о продужењу притвора или пак о укидању притвора или ће првостепени суд у складу са одредбом чл. 462 ст. 5 ЗКП, по истеку 60 дана од дана доношења решења другостепеног суда испитати да ли још постоје разлози за притвор?

### **Одговор:**

Након доношења решења којим од стране другостепеног суда на основу одредбе чл. 458 ст.4 ЗКП продужен притвор према окривљеном до даље одлуке првостепеног суда, првостепени суд није у обавези да одмах по пријему списка предмета од другостепеног суда поново испитује да ли још постоје разлози за притвор и донесе ново решење о продужењу или укидању притвора, већ да ће у складу са одредбом чл. 462 ст. 5 ЗКП у вези чл. 216 ст. 3 ЗКП по истеку 60 дана од дана доношења решења другостепеног суда испитати да ли још постоје разлози за притвор.

### **3. Питање:**

Ко је надлежан да донесе решење о одузимању предмета на основу чл.535 ЗКП у ситуацији када кривични поступак није покренут, веће из чл. 21 ст. 4 ЗКП или судија за претходни поступак?

### **Одговор:**

За доношење решења о одузимању предмета на основу чл. 535 ЗКП и у другим случајевима, у ситуацији када кривични поступак није покренут, надлежан је судија за претходни поступак надлежног суда.

### **4. Питање:**

У ситуацији када по жалби на ослобађајућу пресуду другостепени суд на претресу по предлогу странке одреди извођење доказа који није одређен од стране првостепеног суда, те након извођења тог доказа и упознавања са садржином

доказа изведених на главном претресу, донесе осуђујућу пресуду, та пресуда поводом жалбе браниоца оптуженог буде укинута од стране већа апелационог суда (КжЗ), да ли је у поновљеном поступку пред истим већем или у измењеном саставу то веће везано одлуком претходног већа, те мора извести све оне доказе које је извело претходно веће или је имајући у виду да се укидањем осуђујуће пресуде све враћа у фазу жалбеног поступка на првостепену ослобађајућу пресуду, другостепено веће самостално у погледу даље одлуке да ли ће уопште отворити претрес или не, па самим тим и у погледу доказа које ће извести уколико донесе решење о отварању претреса?

### Одговор:

Ради се о фактичком питању и немогуће је дати изричит одговор како ће суд поступити у датој процесној ситуацији, уз указивање да према одредби чл. 446 ЗКП, стоји могућност другостепеном већу да према околностима савког конкретнег случаја одлучи да ли ће поново одржати претрес пред другостепеним судом или не.

### 5. Питање:

Да ли се ради о покушају или неподобном покушају када извршилац кривичног дела фалсификовање и злоупотреба платних картица из чл. 225 ст. 4 КЗ, на противправан начин дође до платне картице крађом, утајом или на неки други сличан начин и покушава на банкомату или на шалтеру банке да је употреби ради подизања новца, али у томе не успе зато што је власник картице благовремено обавестио банку која је рачун блокирала, или зато што извршилац нема ПИН број картице?

### Одговор:

То је фактичко питање и суд ће у сваком конкретном случају проценити о ком делу се ради.

### 6. Питање:

Да ли приватни тужилац може писаним поднеском да одустане од приватне тужбе и од кривичног гоњења против окривљеног након изјављене жалбе против првостепене пресуде, ако се након изјављене жалбе измирио са

окривљеним и са истим постигао писани споразум о трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву који је приложио уз поднесак о одустанку од кривичног гоњења и да ли приватни тужилац може да одустане од приватне тужбе и од кривичног гоњења на седници већа пред другостепеним судом ако приватни тужилац и окривљени на седници већа сагласно изјаве да су се у међувремену измирили и да су постигли споразум о трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву?

### Одговор:

У датој процесној ситуацији описаној у питању имајући у виду одредбу чл. 450 ст. 5 ЗКП, постоји могућност да се једино отвори претрес пред другостепеним судом на којем би се приватном тужиоцу омогућило да у складу са цитираном одредбом одустане од приватне тужбе у вези што је и захтевано иначе у поднеску, с обзиром да је једино тада могуће да овлашћени тужилац, ако су окривљени сагласни с тим, у целини или делимично одустане од оптужбе.

### 7.Питање:

Уколико је суд наредбом којом одређује вештачење поверио вештачење вештаку појединцу са списка сталних судских вештака, а тај вештак потом суду испостави фактуру своје агенције коју је основао за послове вештачења, да ли суд треба да прихвати такву фактуру, с обзиром да је наредбом вештак ангажован као физичко лице, а вештачење није поверено агенцији?

### Одговор:

То није правно питање него је питање техничког карактера везано за начин исплате и да су због тога одлучили да не одговоре односно да не заузимају став у вези тог питања јер се ради просто о једном техничком питању на који начин ће се извршити исплате награде вештака.



## **II**

**Врховни касациони суд је прихватио усаглашене ставове апелациони судови са претходне заједничке седнице у вези са питањима:**

### **1.Питање:**

Да ли је јавни тужилац овлашћен да измени оптужни акт на претресу пред другостепеним судом, код кривичних дела са бланкетном диспозицијом тако што би сходно резултату доказног поступка са претреса пред другостепеним судом изменио у чињеничном опису кривичног дела одредбу закона, односно другог прописа која је прекршена и тиме учињено предметно дело, те уколико је јавни тужилац учинио такву измену оптужног акта, да ли другостепени суд може да донесе осуђујућу пресуду (преиначењем првостепене ослобађајуће пресуде доношењем осуђујуће пресуде или пак остављањем осуђујуће пресуде али сада са измењеним ињеничним описом дела), те да ли је другостепени суд овлашћен да самостално (по службеној дужности), без измене оптужног акта од стране јавног тужиоца преиначи у наведеном смислу првостепену пресуду, а при чему би била задржана правна квалификација из оптуженог акта (најчешћи случајеви у пракси су код кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја, кривичних дела против привреде и др.).

### **Усаглашен став:**

Јавни тужилац није овлашћен да на претресу пред другостепеним судом да измени оптужни акт код кривичних дела са бланкетном диспозицијом, тако што би уместо одредби закона које су према оптуженом акту повређене (бланкет) унео друге одредбе истог или другог прописа мењајући у смислу тих одредби чињенични опис кривичног дела, јер таква измена оптуженог акта није у корист окривљеног, у смислу одредбе чл. 450.ст.5.ЗКП,нити такву измену може по службеној дужности да учини другостепени суд, без обзира на резултат доказног поступка на претресу пред другостепеним судом.

### **2.Питање:**

Да ли треба издвојити као незаконит доказ записник о испитивању сведока сачињени од стране надлежног тужиоца у предистражном поступку, при чему је испитивање сведока извршено пре доношења наредбе о спровођењу

истраге, због чега нису могли бити обавештени осумњичени и бранилац, а не постоји ни одобрење судије за претходни поступак да се испитивање сведока изврши у њиховом одсуству, у смислу одредаба чл.300 ЗКП. Све ово у ситуацији када се испитани сведоци не могу поново испитати, нити у истрази нити на главном претресу због недоступности?

### **Усаглашен став::**

Треба издвојити као незаконит доказ записник о испитивању сведока сачињен од стране јавног тужиоца у предистражном поступку пре доношења наредбе о спровођењу истраге, јер у тој фази поступка осумњиченом и његовом браниоцу није могао бити упућен позив ради присуствовања испитивању сведока у смислу одредбе чл.300 ст.1.ЗКП па ни прибављено одобрење судије за претходни поступак у смислу одредбе чл.300 ст.6 ЗКП, нити јавни тужилац има овлашћење да у тој фази поступка грађане испитује у својству сведока, сходно одредби чл.282 ст.1 тач.2 у вези одредбе чл. 288 ст.2.ЗКП.

### **3.Питање:**

Да ли може постојати стицај кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 ст 1 КЗ и истог кривичног дела из чл.246 ст.6 (да ли ће учинилац бити оглашен кривим за оба кривична дела) у ситуацији када је својим радњама остварио сва обележја кривичног дела из чл.246. ст.1.КЗ, а поред тога поседује супстанцу која је намењена за производњу сасвим друге опојне дроге од оне која је предмет кривичног дела из чл.246 ст.1 КЗ?

### **Усаглашен став:**

Не може постојати стицај кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 ст.1.КЗ и кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.6.КЗ, па учинилац не може бити оглашен кривим за оба ова кривична дела већ само за кривично дело из чл.246 ст.1.КЗ у ситуацији када је својим радњама остварио сва обележја кривичног дела из чл.246 ст.1.КЗ а поред тога је поседовао и супстанцу која је намењена за производњу макар и сасвим друге опојне дроге од оне која је предмет кривичног дела из чл.246 ст.1.КЗ.

### **III**

**Кривична одељења свих апелационих судова уједначила су судску праксу једногласним усвајањем закључка у погледу следећег спорног правног питања:**

1. Дали ће бити изузет по чл. 37 ст. 1 тач. 2 ЗКП, судија члан већа у трећестепеном поступку ако у истом предмету пре доношења другостепене пресуде која је предмет трећестепеног суда раније учествовао као члан другостепеног већа у доношењу одлуке којом је укинута првостепена пресуда?

#### **Закључак:**

Судија у таквој ситуацији неће бити изузет као члан већа.

### **ЗАКЉУЧЦИ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИКА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА И ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, ОДРЖАНЕ У БЕОГРАДУ, ДАНА 28.06.2018. ГОДИНЕ**

### **I**

**Одговори Врховног касационог суда на питања око којих апелациони судови нису постигли сагласност на претходној заједничкој седници:**

#### **1. Питање:**

Да ли адвокату припада награда за састављање поднеска којим се захтева накнада трошкова кривичног поступка ( трошковника) ?

#### **Одговор:**

Браниоцу припада награда за састављање поднеска у ситуацијама када након доношења ослобађајуће или одбијајуће пресуде као и у случају обуставе кривичног поступка у правноснажним одлукама није у потпуности одлучено о трошковима кривичног поступка, својим поднеском без обзира како је он назван

( захтев, трошковник и др. ) тражи поступање суда ради остваривања права на накнаду трошкова кривичног поступка који припадају окривљеном.

### 2. Питање:

Да ли у чињеничном опису за кривично дело превара када је оштећени правно лице мора бити наведено име физичког лица које се доводи у заблуду или одржава у заблуди или је довољан навод да се у заблуду доводи или у заблуди одржава овлашћено лице установе, банке, и томе слично?

### Одговор:

Пожељно би било да у чињеничном опису дела овлашћено лице које се доводи у заблуду или одржава у заблуди буде одређено личним подацима, међутим, уколико то није учињено, онда то лице треба бити што ближе „ одредиво“ према својој функцији или пословима које обавља у оштећеном предузећу, како би на основу тога кроз образложење одлуке могло бити идентификовано.

### 3. Питање:

Да ли је првостепени суд у обавези приликом укидања првостепене пресуде и враћања предмета на поновно суђење члан 458 ЗКП да испита ако се према окривљеном примењује мера забране напуштања стана из члана 208 ЗКП, да ли још постоје разлози за примену мере и да донесе решење о продужењу или укидању мере?

### Одговор:

Другостепени суд је у обавези приликом укидања првостепене пресуде и враћања предмета на поновно суђење, члан 458 ЗКП да испита ако се према окривљеном примењује мера забране напуштања стана из члана 208 ЗКП, да ли још постоје разлози за примену мере и да донесе решење о продужењу или укидању мере.

## **II**

**Врховни касациони суд је прихватио усаглашен став апелациони судови са претходне заједничке седнице у вези са питањем:**

### **Питање:**

Да ли ће бити изузет по члану 37 став1 тачка 4 ЗКП судија члан већа у трећестепеном поступку ако у истом предмету пре доношења другостепене пресуде која је предмет трећестепеног суда суда раније учествовао као члан другостепеног већа у доношењу одлуке којом је укинута првостепена пресуда?

### **Усаглашен став:**

Судија у таквој ситуацији неће бити изузет као члан већа.

## **ЗАКЉУЧЦИ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИКА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА И ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, ОДРЖАНЕ У НИШУ, ДАНА 28.09.2018. ГОДИНЕ**

## **I**

**Одговори Врховног касационог суда на питања око којих апелациони судови нису постигли сагласност на претходној заједничкој седници:**

### **1.Питање:**

„Да ли се против осуђујуће пресуде којом је окривљени оглашен кривим због кривичног дела које се гони по службеној дужности, дозвољена жалба супруге окривљеног у корист окривљеног када супруга у поступка има својство оштећеног?“

### **Одговор:**

„Против осуђујуће пресуде којом је окривљени оглашен кривим због кривичног дела које се гони по службеној дужности, није дозвољена жалба супружника окривљеног у корист окривљеног, када супружник у поступка има својство оштећеног.“

### 2.Питање:

„У процесној ситуацији када у предмету има већи број оптужених и већи број њихових бранилаца, а објављивању пресуде присуствује само један бранилац који тражи продужење рока за жалбу, који суд (председник већа) уважава и продужава рок за жалбу, без навођења да се исти односи само на тог браниоца, да ли одређени рок од стране суда (председника већа) важи само у односу на тог браниоца или важи на све учеснике у поступку?“

### Одговор:

„У процесној ситуацији, када у предмету има већи број оптужених и већи број њихових бранилаца, а објављивању пресуде присуствује само један бранилац који тражи продужење рока за жалбу, који суд (председник већа) уважава и продужава рок за жалбу, без навођења да се исти односи само на тог браниоца, одређени рок од стране суда (председника већа) важи за све учеснике у поступку.“

### 3.Питање:

„Да ли се осуђујућа пресуда у кривичном поступку може заснивати искључиво или у одлучујућој мери на исказу саокривљеног из предистражног поступка, саслушаног у смислу члана 289 став 4 ЗКП, којим он терети окривљеног у погледу радње извршења кривичног дела у ситуацији када:

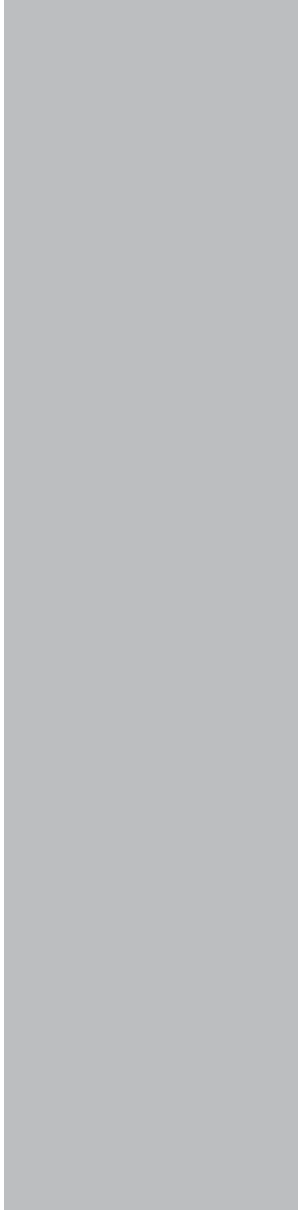
- а) саокривљени у поступку истраге и на главном претресу користи право да не износи одбрану и одбије да одговори на питање суда и одбране окривљеног (брани се ћутањем),
- б) саокривљени у поступку истраге и на главном претресу измени одбрану и не терети окривљеног?“

### Одговор:

„Исказ саокривљеног из предистражног поступка дат у смислу одредбе чл. 289 ст. 4 ЗКП у датим процесним ситуацијама са аспекта законитости није недозвољен доказ сходно одредби чл. 397 ст. 6 ЗКП, с тим да у сваком конкретном случају треба посебно ценити његову доказну вредност у односу на остале изведене доказе, а посебно да на тај начин не би била злоупотребљена наведена процесна решења да би се повредило право окривљеног на одбрану.“

# КРИВИЧНО ПРАВО

## СУДСКА ПРАКСА







## КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

### ПОМАГАЊЕ (чл.35. ст.2. КЗ)

**Радња превозења противправно одузетих ствари, дан касније у односу на дан прекида притежења оштећеног на одузетим стварима, не представља радњу помагања у извршењу кривичног дела тешка крађа.**

#### *Из образложења:*

Помагање другом да изврши кривично дело нужно подразумева радње које претходе или су истовремене са радњама кривичног дела у чијем извршењу се помаже, евентуално и након њих под условом да су унапред уговорене, односно обећане. Насупрот томе, првостепени суд у изреци пресуде наводи радње које је оптужени М. извршио дан касније у односу на кривично дело извршено од стране Ф., па је стога из изреке пресуде потпуно нејасно на који начин је оптужени М. предузимањем радњи након што је кривично дело од стране оптуженог Ф. свршено, односно након прекида притежања оштећеног на одузетим стварима, могао да помогне оптуженом Ф., при чему из изреке не произилази да је оваква радња оптуженог М. била унапред уговорена, односно обећана.

*Решење Апелационог суда у Нишу Кж1 192/2018 од 20.03.2018. године, пресуда Основног суда у Лебану К.бр.211/2013 од 29.11.2017. године, исправљена решењем тог суда од 31.01.2018.године.*

*Сентенцу приредила судија Весна Стевановић*

### ТЕШКА КРАЂА чл.204. ст.1. КЗ

**Околност да су оптужени бацили неке од ствари које су биле у затвореној торбици коју су противправно одузели, а да је вредност осталих одузетих ствари мања од 5000 динара, код чињенице да нису знали шта се у торбици налази, не утиче на правилност правне оцене дела , да су извршили кривично дело тешка крађа из чл.204.ст.1.тач.1. КЗ, собзиром на њихову очигледну намеру да за себе прибаве противправну имовинску корист веће вредности.**

***Из образложења:***

Када је у питању намера оптужених, односно чињеница да ли је иста била усмерена на то да оптужени одузимањем ствари из истог прибаве противправну имовинску корист мале вредности, у ком случају би се радило о кривичном делу ситне крађе на чије постојање жалбе и указују или веће вредности када би постојало кривично дело тешке крађе, правилно је првостепени суд анализирајући утврђено чињенично стање, првенствено чињеницу да су оптужени након обијања возила оштећеног осим ИД плејера и МПЗ плејера одузели и торбицу, нашао да су ишли за тим да прибаве имовинску корист веће вредности. Ово са разлога што оптужени у време извршења кривичног дела свакако нису могли да знају садржај торбице која се у ауту оштећеног налазила, што јасно значи да би присвојили и вредније ствари да су се исте у торбици нашле, а чињеница на којој жалбе исништирају да су се у торбици налазили бонови за топли оброк АД „Ниш-Експрес“ и путне карте „Ниш-Експреса“ које оптужени нису искористили већ су торбицу са овим стварима бацили, како у својим одбранама наводе је без утицаја на правилност чињенице да су оптужени поступали у намери прибављања противправне имовинске користи веће вредности коју је правилно првостепени суд ценио у време извршења кривичног дела који је од кривично-правног значаја за њено утврђење.

*Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1342/17 од 09.01.2018. године, пресуда Основног суда у Нишу К.бр.164/15 од 13.04.2017. године.*

*Сентенцу приредила судија Весна Стевановић*

**ПОМАГАЊЕ**  
**(чл.35. ст.2. КЗ)**

**Радња помагања у извршењу кривичног дела мора бити описана и конкретизована у изреци пресуде. У супротном, изрека је неразумљива.**

***Из образложења:***

Изрека побијане пресуде је потпуно неразумљива будући да првостепени суд наводи да је оптужени М. ставио оптуженом Ф. на располагање средстава за извршење кривичног дела која радња, у смислу чл.35 ст.2 КЗ јесте један од алтернативно прописаних начина помагања другом у извршењу кривичног дела, али приликом конкретизације радњи овог оптуженог не наводи која је то средства ставио на располагање нити на који начин је наведено учинио, већ описује радње

које нису ни у каквој вези са наведеном радњом помагања (преношење, одвожење, сечење, паковање и продаја одузетих ствари).

*Решење Апелационог суда у Нишу Кж1 192/2018 од 20.03.2018. године, пресуда Основног суда у Лебану К.бр.211/2013 од 29.11.2017. године, исправљена решењем тог суда од 31.01.2018.године.*

*Сентенцу приредиле судија Весна Стевановић и судијски помоћник Ивана Лазовић*

## КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛ. 246.СТ.1. КЗ

Код кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл 246.ст.1.КЗ радње извршења су алтернативно одређене па је за потпун опис дела довољно да се опише једна од алтернативно прописаних радњи извршења. Такође није од утицаја на постојање предметног дела да ли је опојна дрога произведена ради сопствене употребе или ради стављања у промет.

### *Из образложења:*

Првостепени суд је оптуженог огласио кривим за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246.ст.1. КЗ.

У својој жалби бранилац оптуженог пресуду побија искључиво због повреде кривичног закона у питању да ли је дело за које се оптужени гони, кривично дело, са ставом да се у конкретном случају не ради о предметном кривичном делу јер није испуњен други кумулативно прописан услов за постојање кривичног дела а то је стављање у промет опојне дроге. Заправо се жалбом указује да је за постојање предметног кривичног дела потребно да буду испуњена два кумулативна услова и то производња опојне дроге и њено стављање у промет.

Апелациони суд у Нишу налази да су изнети жалбени наводи браниоца у погледу повреде кривичног закона неосновани јер се темеље на погрешном тумачењу одредбе чл. 246. ст. 1. КЗ и погрешном закључку да су радње извршења предметног кривичног дела кумулативно предвиђене.

Наиме, чланом 246. ст. 1. КЗ су алтернативно прописане радње извршења предметног кривичног дела (а не кумулативно како се у жалби наводи). На овакав закључак јасно упућује одвајање зарезом или везником „или“ приликом

набрајања радњи извршења. У конкретном случају оптуженом се на терет ставља неовлашћена производња опојне дроге као једна од алтернативно одређених радњи извршења предметног кривичног дела за које је оптужени и оглашен кривим.

Такође жалбени навод којим се указује да је производња опојне дроге вршена ради сопствене употребе није од утицаја на постојање кривице оптуженог јер приликом утврђења да је вршена производња опојне дроге, за постојање кривичног дела није од утицаја да ли је производња вршена ради сопствене употребе или ради даље продаје.

*Пресуда Вишег суда у Пироту К.бр. 20/17 од 20.02.2018.године и пресуда Апелационог суда у Нишу, 12Кж1.бр. 477/18 од 30.05.2018. године.*

*Припремио судија Зоран Поповић*

## **КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО**

### **СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ**

**(чл. 35 ЗКП и чл. 30 Закона о организацији надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције )**

У ситуацији када на дан ступања на снагу Закона о организацији надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције поступак за кривично дело из чл. 359.ст.1. КЗ још увек није покренут, надлежан за поступање је Виши суд, посебно одељење за сузбијање корупције, без обзира што је након ступања на снагу наведеног закона судија Основног суда донео наредбу о одређивању главног претреса.

#### ***Из образложења:***

Из списка предмета Основног суда у Лесковцу произилази да је оптужни предлог против окр. Ц.М. због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359. ст. 1. КЗ, за које је прописан скраћени поступак, поднет 21.02.2018. године, што значи пре ступања на снагу Закона о организацији надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

(„Службени гласник“ бр. 94/2016, у даљем тексту Закон). Наведеним законом, чланом 30. истог, прописано је да кривични поступци покренути због кривичних дела из чл. 2. тог закона, окончаће се пред јавним тужилаштвом и пред стварно и месно надлежним судом, односно одељењем суда које је било функционално надлежно пре дана почетка примене закона. Одредбом чл. 7. ЗКП прописано је да је кривични поступак покренут одређивањем главног претреса или рочишта за изрицања кривичне санкције у скраћеном поступку.

Примењујући одредбе чл. 30. Закона, у моменту ступања на снагу истог, Основни суд је требао да списе предмета достави Вишем суду у Нишу – Посебном одељењу за сузбијање корупције јер кривични поступак против Ц.М. није покренут обзиром да није одређен главни претрес.

То што је Основни суд у Лесковцу, односно поступајући судија појединац учинио пропуст па уместо да се након ступања на снагу Закона, огласи ненадлежним и предмет достави Вишем суду у Нишу – Посебном одељењу за сузбијање корупције, он одређује главни претрес својом наредбом од 21.03.2018. године (када је већ ступио на снагу Закон и када Основни суд више није био стварно надлежан за поступање) није од утицаја на надлежност, јер се надлежност суда одређује законом а не (погрешним) актом судије.

*Решење Апелационог суда у Нишу 12Кжр Ас.бр.6/18 од 06.06.2018.године.*

*Припремио судија Зоран Поповић*

## ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ПРИМЕНЕ НАЧЕЛА NE BIS IN IDEM

Није дошло до повреде начела *Ne bis in idem* у ситуацији паралелног вођења два поступка, управно-прекршајног и кривичног, односно настављање другог поступка након што је одлука у првом поступку постала правноснажна, уколико оба поступка представљају једну целину која подразумева да су поступци уско суштински и хронолошки повезани, а то постоји онда када се сваким од поступака остварују различите сврхе, да је избегнуто дуплирање доказног поступка, да је последица недозвољеног понашања предвидива и да укупна санкција не представља наметање прекомерног терета појединцу.

### *Из образложења:*

Уважавајући праксу и критеријуме Европског суда за људска права, Апелациони суд је, у оцени приговора пресуђене ствари, ценио: прво, да ли су оба поступка која су вођена против оптуженог вођена за дело које по својој

природи представља кажњиво дело односно да ли је прва казна по својој природи била казненоправна; друго, да ли су дела због којих се оптужени казнено гони иста (*idem*); треће, да ли је постојала двострукоост поступка (*bis*).

У односу на прво питање, у утврђеној судској пракси Европског суда за људска права постављена су три критеријума, која су општепозната као „мерила Engel“, а то су: 1) правна квалификација дела према домаћем законодавству, 2) природа дела која подразумева два кумулативна подкритеријума, и то обим прекршајне норме и сврху казне и 3) природа и степен тежине казне.

У конкретном случају прекршајни поступак који је вођен против оптуженог као одговорног лица није вођен за дело које по својој природи и тежини и сврси запрећене санкције представља кажњиво дело.

Друго спорно питање је утврђивање идентитета дела, с обзиром на то да се једним друштвено неприхватљивим понашањем могу истовремено угрозити различита заштићена добра, те остварити обележја два или више кажњивих дела која могу бити у надлежности истог или различитих органа гоњења исте државе. Последице прешироког тумачења начела *ne bis in idem* би биле штетне у заштити темељних друштвених вредности и сврси која се остварује у сваком појединачном казненом поступку.

Испитујући да ли у конкретном случају постоји идентитет казних дела због којих је оптужени оглашен одговорним у прекршајном и кривим у кривичном поступку, овај суд је пошао од утврђених критеријума Европског суда за људска права којима се забрањује казнени прогон или суђење за друго дело у мери у којој оно произилази из истоветних чињеница које су у суштини битно исте као и прво кажњиво дело за које је већ донета правноснажна одлука.

У конкретном случају оптужени Д.Ц. је у прекршајном поступку оглашен одговорним што није обрачунао порез на промет у законском року по побројаним рачунима и што није обрачунао порез на промет на мањак робе утврђен пописом залиха робе, а у износу од 20.826.818,00 динара, док је у кривичном поступку оглашен кривим што као власник и директор предузећа, у намери да делимично избегне плаћање пореза, није пријавио чињенице од утицаја за утврђивање пореза у вези истог пословања, а износ порезе чије је плаћање избегао износи 20.459.700,20 динара, дакле преко 7.500.000,00 динара што је квалификаторна околност код овог кривичног дела. Из законског описа прекршаја не произилази да је намера избегавања плаћања пореских

обавеза битан елемент прекршаја, као код кривичног дела пореска утаја, а прекршајни суд својом изреком није проширио чињенични опис прекршаја, нити је обухватио нужан субјективни елемент наведеног кривичног дела за које је оптужени у овом поступку оглашен кривим, иако се оба поступка односе на исте противправне радње оптуженог.

Иститујући трећи критеријум - двострукост поступка (*bis*), овај суд је примењујући критеријуме и стандарде из пресуде Великог већа Европског суда за људска права из предмета А. и Б. против Норвешке од 15.11.2016. године (број представке 24130/11 и 29758/11) на конкретан предмет, нашао да нема повреде начела *ne bis in idem*. У предмету *Sergey Zolotukhin protiv Rusije*, на коју и жалбе указују, питање да ли и када паралелно вођење два поступка, управно-прекршајног и кривичног, односно настављање другог поступка након што је одлука у првом поступку постала правноснажна, представља дуплирање поступка и повреду зајемченог права, није дат одговор за ситуације када је поступак био комбинован како би чинио повезану целину. Суд је прихватио да је изрицање различитих санкција од стране различитих тела, које се односе на исто понашање, у одређеној мери допуштено, јер државе имају право да изаберу начин на који ће организовати свој правни систем, па је констатовано да је раширена пракса да се казне за повреде прописа о опореживању, заштити околине и јавног саобраћаја одређују у оквиру два поступка и то прекршајног (управног) и кривичног поступка. Према мишљењу Суда за људска права државе могу легитимно изабрати комплементарне правне одговоре на исто друштвено неприхватљиво понашање путем различитих поступака који чине повезану целину, под условом да укупност правних одговора не представља прекомеран терет за појединца на којег се односе. Тумачење наведеног правила у смислу аутоматске забране наставка вођења другог поступка у тренутку када је одлука у првом постала правноснажна могла би омогућити заинтересованом лицу да искористи наведено начело као средство манипулације, што би могло довести до правне несигурности.

То даље значи да сваки од тих поступака мора представљати предвидив и сразмеран одговор државе на поједини аспект друштвено неприхватљивог понашања, а оба поступка заједно чине једну повезану целину, тако да лице против кога се поступци воде није изложено неправди. У поменутој пресуди А. и Б. против Норвешке од 15.11.2016. године Европски суд за људска права је утврдио услове које је потребно испунити како би се двоструки казни и управни-прекршајни поступци сматрали довољно повезаним по својој при-

роди и времену и тиме у складу са критеријумом *bis*, а то су: а) да се сваким од поступака остварују различите сврхе које су комплементарне тако да се међусобно допуњују, те се вођењем различитих поступака утиче на различите аспекте истог друштвено неприхватљивог понашања, б) да је двострукост дотичних поступака на основу закона и праксе предвидива последица истог недозвољеног понашања, в) да су меродавни поступци вођени на начин да се у највећој могућој мери избегне дуплирање у прикупљању и оцени доказа, и изнад свега г) да је казна изречена у поступку који је први постао правноснажан узета у обзир у поступку који је касније правноснажно окончан, тј. да је укупна санкција пропорционална делу, јер се тиме спречава наметање прекомерног терета појединцу.

Комбиновани поступак ће задовољити критеријуме комплементарности и усклађености, прво, ако су санкције које се морају изрећи у поступку, и које нису „казнене“ у конвенцијском смислу, специфичне за предметно понашање и тиме се разликују од казни у казненом праву и друго, да тај поступак нема никакав значајан степен кажњавања, те се комбинацијом поступака неће наметнути несразмеран терет оптуженом.

- а) Применом напред наведених критеријума на конкретан предмет, овај суд налази да су прекршајни поступак који је вођен против оптуженог Д. Ц. и кривични поступак у овом предмету довољно блиско суштински и хронолошки повезани тако да представљају целовит одговор државе на исто противправно понашање. Сvakим од поступака се остварује различита сврха: код прекршаја је то фискална дисциплина у привредном пословању, а пореске казне служе као опште средство одвраћања од непоступања или нетачног поступања у вези пореских обавеза, док је код кривичних дела сврха заштита привредног система и његовог функционисања прописивањем и кажњавањем ради сузбијања дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством. Наведене сврхе су комплементарне тако да се међусобно допуњују, а вођењем различитих поступака се утиче на различите аспекте истог друштвено неприхватљивог понашања.
- б) Двострукост поступака вођених на основу закона је за оптуженог била предвидива последица истог недозвољеног понашања имајући у виду напред наведену законску регулативу и прописивање два поступка са различитим санкцијама, од стране државе, у конкретној области.



У правном систему Републике Србије су, у време инкриминисаног догађаја, за повреду прописа о опорезивању, Законом о порезу на промет биле прописане казнене одредбе за прекршај, а Законом о пореском поступку и пореској администрацији кривичноправне одредбе за пореска кривична дела, које су након тога инкорпориране у Кривични законик.

- в) Поступци према оптуженом су делом вођени паралелно, али доказни поступак није вођен два пута него су чињенице утврђене у једном поступку користиле и у другом, те је у највећој могућој мери избегнуто дуплирање прикупљања и оцене доказа.
- г) Поводом жалби одбране и преиначењем првостепене пресуде по службеној дужности у делу одлуке о кривичној санкцији, у складу са овлашћењем из чл.451. ст.2. тач.1. ЗКП, овај суд је оценио да је укупна санкција изречена оптуженом Д. Ц. овом пресудом сразмерна учињеном делу, с обзиром да је кривични суд узео у обзир санкцију из пореског поступка, тако да укупна санкција не представља наметање прекомерног терета оптуженом за исто противправно понашање. За оцену овог критеријума Апелациони суд је имао у виду чињеницу да је у прекршајном поступку оптужени кажњен новчаном казном у износу од 1.000,00 динара и да је, у кривичном поступку, осуда на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и на новчану казну у одређеном износу од 100.000,00 (сто хиљада) динара, коју је дужан да плати у року од три месеца, у коју казну му се, у складу са одредбом чл.63. ст.3. Кривичног законика, урачунава новчана казна коју је оптужени платио за прекршај, права мера казне којом ће се остварити сврха кажњавања прописана чл.42. Кривичног законика у оквиру опште сврхе изрицања кривичних санкција из чл.4. Кривичног законика. При том, прописана прекршајна казна се битно разликује од казне у кривичном праву, а прекршајни поступак и изречена новчана казна немају никакав значајан степен кажњавања у конкретном случају.

Имајући у виду све наведене критеријуме у вези питања двоструког поступка и кажњавања, Апелациони суд налази да у овој кривичној ствари осудом оптуженог у кривичном поступку није дошло до повреде начела *ne bis in idem*, те се неосновано изјављеним жалбама оптуженог и његовог браниоца тврди другачије, због чега су ти жалбени наводи неосновани.

*Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 623/2017 од 20.09.2017. године, којом је преиначена пресуда Основног суда у Нишу 2К 964/2016 од 27.10.2016. године.*

***Приредила судија Снежана Милошевић***

## САДРЖАЈ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА (Члан 314. став 1. тачка 3. Законика о кривичном поступку)

Када је кривични поступак окончан пресудом о прихватању споразума о признању кривичног дела, а у споразуму није унета одлука о мери безбедности одузимање предмета - путничког возила сходно чл. 314 ст. 1 тач. 3 Законика о кривичном поступку, иако је одузимање возила било обавезно сходно чл. 350 ст. 5 Кривичног законика, то не може бити разлог да се накнадно одузме возило.

### *Из образложења:*

„Апелациони суд налази да када се одлучује о предлогу јавног тужиоца о одузимању предмета, не могу се применити одредбе чл. 535 и чл. 536 ЗКП, које се примењују једино када се ради о одузимању предмета чије је одузимање неопходно у циљу заштите интереса опште безбедности и морала, а што овде није случај. У конкретном случају предмет је окончан пресудом о прихватању споразума о признању кривичног дела, па то што у споразуму није унета и мера безбедности што је било обавезно према одредби чл.314. ст.1. тач.3. ЗКП, представља пропуст овлашћеног тужиоца приликом сачињавања споразума и то не може бити разлог да се накнадно врши одузимање возила по чл.350 ст.5 ЗКП. Осим тога, јавни тужилац се није жалио на пресуду, којом такође није одлучено да се одузме предмето путничко возило, које је употребљено за извршење кривичног дела, што је законски основ за жалбу из чл.441 ст.2 ЗКП, већ се определио да по правноснажности пресуде тражи од првостепеног суда доношење посебног решења, на основу чл. 350 ст.5 КЗ иако одредбама чл. 535. ЗКП и чл. 536. ЗКП, таква могућност није предвиђена.“

*(Решење Апелационог суда у Нишу Кжр-АС бр.8/17 од 01.11.2017.године).*

*Приредила: Јелена Додић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу*

## ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

**Јавни тужилац нема право на изјављивање жалбе против одлуке о досуђеном имовинскоправном захтеву**

### *Из образложења:*

“Оцењени су неоснованим наводи жалбе, који се односе на имовинскоправни захтев оштећене, те да је првостепени суд требао да обавезе оптуженог да оштећеној накнади делимичну штету у утврђеном износу, јер јавни тужилац, сходно чл. 433 ЗКП, не може да изјави жалбу на одлуку о имовинскоправном захтеву ни по општем овлашћењу да као странка изјављује жалбу на пресуду, ни по посебном овлашћењу из ст.3 овог члана да изјављује жалбу у корист оптуженог. Јавни тужилац који у Законику нема овлашћења да тај интерес заступа у току поступка и на главном претресу, не може га заступати ни у жалбеном поступку...”

*Пресуда Основног суда у Зајечару К 78/17 од 05.12.2017. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 324/18 од 11.05.2018. године.*

*Приредио Милан Ђорђевић, судијски саветник Апелационог суда у Нишу*

## БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (чл.438. ст.1. тач.11. ЗКП)

**Када првостепени суд оцени да су испуњени законски услови за изрицање неке од посебних обавеза малолетнику, дужан је да у изреци решења наведе тачну законску одредбу која регулише изрицање посебних обавеза из чл.14. ЗМ, да одреди трајање изречене посебне обавезе, у противном је изрека решења неразумљива.**

### *Из образложења:*

Побијаним решењем мал. С.Н. изречена је на основу чл.14. ЗМ посебна обавеза да се у случају потребе укључи у појединачни или групни третман у здравственој установи и да поступа по програму рада који за њега буде сачињен у тој установи као и да се континуирано јавља на контроле лекару.

По оцени Апелационог суда побијано решење донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.1. тач.11. ЗКП, јер је изрека решења неразумљива. Ово из разлога што се не може утврдити да је њоме одлучено у погледу посебне обавезе, јер се посебне обавезе изричу када су за то испуњени законски услови, а не “у случају потребе”, како наводи првостепени суд, па се из изреке решења не може закључити да ли је посебна обавеза изречена или не, јер тако како је изречена, по закону није могуће. Такође, у изреци решења није наведено која посебна обавеза из чл.14. ЗМ се изриче малолетнику, дакле није наведен став и тачка чл.14. ЗМ, нити је наведено трајање посебне обавезе сходно чл.14. ст.4. ЗМ, што је све неопходно навести у изреци решења, да би исто било разумљиво.

*Решење Апелационог суда у Нишу Кжм.1. бр.24/16 од 20.04.2016. године.*

*Приредила судија Јасмина Јововић*

### **БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ( чл.368.ст.1 тач.10. ЗКП )**

Иако је у записнику о увиђају наведено да ће фототехничка документација бити саставни део тог записника, када криминалистички техничар у службеној белешци сачињеној након увиђаја евидентира трагове који нису констатовани и у записнику о увиђају у коме је и наведено да других трагова није било, па идентификација учиниоца буде утврђена само на основу трагова означених у службеној белешци, пресуда је захваћена битном повредом из чл.368. ст.1. тач.10. ЗКП, јер таква службена белешка представља недозвољени доказ.

#### ***Из образложења:***

Указујући на битну повреду одредаба кривичног поступка бранилац оптуженог у жалби инсистира на томе да је у записницима о увиђају констатовано затечено стање и уочени трагови, да је криминалистички техничар обрађивао лице места и констатовано је да других трагова није било, осим оних који су евидентирани у записницима о увиђају, те да у тим записницима нису евидентирани трагови папиларних линија нити трагови газеће површине обуће, па се с тим у вези потенцира да у записницима о

увиђају није наведено да су пронађени трагови који су наведени у службеним белешкама, због чега су службене белешке у којима је наведено где су уочени и трагови газеће површине обуће недозвољени докази и као такви не могу бити саставни део записника о увиђају и немају доказу снагу.

Изнетим жалбеним наводима основано се указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл.368. ст.1. тач.10. ЗКП.

Првостепени суд је из записника о увиђају утврдио да су обијене куће оштећених З.Ђ. и С.Ђ. тако што је насилно отворен прозор на подруму куће оштећеног З.Ђ. јер су констатована оштећења на футеру и крилу, а констатовано је и обијање врата између подрума и приземног дела куће, затечена је торбица црне боје, те да на спрату куће није било преметачине и да других трагова није било, а да су укућани затечени у кући и да је у потпуности нарушено лице места. Такође, из записника о увиђају у кући тог оштећеног првостепени суд је утврдио да је на подруму куће обијен прозор, да је затечена витрина са отвореним вратима, на њој отворена кутија за накит а на другој витрини две отворене чиније за накит, да је у спаваћој соби на спрату извршена преметачина и да других трагова није било.

Имајући у виду да су у записнику о увиђају констатовани сви трагови који су затечени приликом вршења увиђаја, да је у истом наведено да других трагова није било, уз констатацију да ће криминалистичко – техничка документација бити саставни део записника о увиђају, те да у записницима о увиђају није констатовано да су уочени, пронађени и фиксирани, те да су у то време уопште постојали трагови газеће површине обуће, основано се жалбом браниоца оптуженог указује да службене белешке које је сачинио криминалистички техничар и у којима се наводе и трагови газеће површине обуће који нису евидентирани у записницима о увиђају, представљају недозвољене доказе.

*Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж.1.бр.2222/12 од 13.09.2012. године, пресуда Основног суда у Лесковцу 1К.бр.199/12 од 12.04.2012. године.*

*Сентенцу приредила судија Весна Стевановић*

## ПРЕТРЕС ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОМ (Члан 449 Законика о кривичном поступку)

Преиначење ослобађајуће у осуђујућу пресуду након одржаног претреса резултат је другачије оцене доказа од стране другостепеног суда, а последично и другачије оцене утврђеног чињеничног стања. Битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 438 Законика о кривичном поступку, не могу бити основ преиначења првостепене ослобађајуће у другостепену осуђујућу пресуду, већ само разлог да се побијана пресуда укине, а ако је већ укидана, да се императивно одржи претрес и другостепени суд правноснажном пресудом мериторно одлучи у конкретној кривичној ствари.

### *Из образложења:*

„Суд трећег степена налази да су неприхватљиви разлози другостепеног суда садржани на стр.4 образложења у смислу да је првостепена ослобађајућа пресуда преиначена у осуђујућу, само зато што је захваћена битном повредом поступка из чл. 438 ст.2 тач.2 ЗКП.

Наиме, преиначење ослобађајуће у осуђујућу пресуду након одржаног претреса резултат је другачије оцене доказа од стране другостепеног суда, дакле другачијег утврђеног чињеничног стања. Битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 438 ЗКП не могу бити основ преиначења првостепене ослобађајуће у другостепену осуђујућу пресуду, већ само разлог да се побијана пресуда укине, а ако је већ укидана, да се императивно одржи претрес, а другостепени суд правноснажном пресудом мериторно одлучи у конкретној кривичној ствари.“

*(Пресуда Вишег суда у Пироту Кж. 243/2016 од 09.05.2017 године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.3 29/2017 од 22.08.2017 године).  
Приредила: Јелена Додић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу*

**ПРИТВОР ПРЕМА МАЛОЛЕТНИКУ  
НАКОН ОБУСТАВЕ ПОСТУПКА  
(чл. 78.ст.2. ЗМ и 425а.ст.2. ЗКП)**

**У случају обуставе кривичног поступка према малолетнику сходно чл. 78.ст.2. ЗМ, притвор према малолетнику ће се обавезно укинути.**

***Из образложења:***

Првостепени суд је правилно у побијаном решењу, одлучујући о притвору према малолетном сада пунолетном Л.М, након обуставе кривичног поступка против њега на основу чл. 78. ст. 2. ЗМ, према истом укинуо притвор и наредио да се пусти на слободу, а на основу чл. 425а ст. 2. ЗКП.

Најпре одредба чл. 4. ЗМ предвиђа да се одредбе Законика о кривичном поступку између осталих прописа примењују ако нису у супротности са Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица.

Одредбом чл. 425а ЗКП, на који се првостепени суд у побијаном решењу правилно позива, прописује да ће се притвор увек укинути и наредити да се оптужени пусти на слободу ако је окривљени између осталог ослобођен оптужбе или је оптужба одбијена. Обустава кривичног поступка на основу чл. 78. ст. 2. ЗМ се може поистоветити са ослобађајућом пресудом према пунолетном лицу обзиром да се поступак према малолетницима обуставља и због нецелисходности изрицања казне или васпитне мере малолетнику, а то за последицу има окончање кривичног поступка без осуде односно изрицања било какве кривичне санкције.

Стоји пропуст првостепеног суда што се осим правилног позивања на нумеричко означавање прописа који регулише наведену процесну ситуацију, не дају разлози сагласно чл. 425а ст. 2. ЗКП на који се правилно позвао него се позива на сагласног тужиоца да се притвор укине. Обзиром на доношење решења којим се обуставља поступак према малолетнику, сагласност тужиоца нема никакву важност пошто је у конкретној процесној ситуацији неопходно применити одредбу чл. 425а ст. 2. ЗКП која је императивног карактера. Међутим, наведени пропуст првостепеног суда не доводи у

питање правилност побијаног решења због чега се жалбени наводи ВЈТ којима се указује на условљену сагласност за укидање притвора заменом те мере мером забране напуштања боравка, оцењује као неоснован, а због чега је жалба одбијена као неоснована на основу чл.467. ст. 4. ЗКП.

*Решење Вишег суда у Врању 3Км.бр.34/16 од 10.10.2016. године. И решење Апелационог суда у Нишу 12Кжм2. бр. 15/16 од 17.10.2016.године. Припремио судија Зоран Поповић*



ГРАЂАНСКО ПРАВО  
ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА



**Др Невена Петрушић**

Правни факултет Универзитета у Нишу

## **ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПРЕТХОДНОГ ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА У КОНТЕКСТУ ПРАВА НА ДЕЛОТВОРАН ПРИСТУП ПРАВДИ**

### **1. Право на приступ правди**

Приступ правди је инхерентан аспект владавине права и основни постулат сваког демократског друштва. Право на приступ правди један је од услова за ефективно уживање и заштиту свих грађанских, политичких, културних, економских, социјалних и других права и израз је недељивости, међузависности и међусобне повезаности људских права. Искуство показује да је делотворан приступ правди од суштинског значаја и за искорењивање сиромаштва, социјалне искључености и свекупни људски развој.<sup>68</sup> Стога савремени концепт приступа правди, заснован на људским правима и недискриминацији, захтева да и сам систем бесплатне правне помоћи буде пројектован као својеврсна посебна мера, која фаворизује и правно оснажује све оне маргинализоване и социјално искључене друштвене групе које се налазе у неједнаком положају у односу на остале грађане у циљу остваривања суштинске, а не само формалне једнакости.<sup>69</sup>

Одговорност и обавеза државе да свакоме обезбеди делотворну и ефикасну правну заштиту проистиче и из права на правично (фер) суђење – посебном људском праву заснованом на идејама фундаменталне правде,<sup>70</sup> којим су

---

68 Programming for Justice: Access for All A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice (2005) UNDP, [https://www.un.org/ruleoflaw/files/ Justice\\_Guides\\_ProgrammingForJustice-AccessForAll.pdf](https://www.un.org/ruleoflaw/files/Justice_Guides_ProgrammingForJustice-AccessForAll.pdf) (приступ 8. 10. 2018).

69 Sepúlveda Carmona, M. Donald, K. (2014) Access to justice for persons living in poverty: a human rights approach, In Elements for Discussion Series, Ministry for Foreign Affairs of Finland [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn](http://dx.doi.org/10.2139/ssrn (приступ 10. 10. 2018)) (приступ 10. 10. 2018).

70 Janis, W. M. Kay, S. R. Bradley, W. A. (2000) European Human Rights Law, Oxford University Press.

успостављени стандарди правозаштитне делатности.<sup>71</sup> У самој сржи права на правично суђење налази се право на приступ суду и другим телима и институцијама правосудног система (приступ правди – *access to justice*), које је, само по себи, људско право и услов уживања свих других права.

На глобалном нивоу право на приступ правди и правично суђење, гарантовано је *Опитом декларацијом о правима човека*<sup>72</sup> и *Међународним пактом о грађанским и политичким правима*.<sup>73</sup> У Декларацији УН о владавини права из 2012. године<sup>74</sup> наглашена је важност “једнаког приступа правди за све, укључујући и чланове угрожених група, као и важност подизања свести о законом признатим правима”. Утврђена је, такође, и обавеза држава да “предузму све неопходне кораке како би обезбедиле праведне, транспарентне, ефикасне, недискриминаторне и одговорне правне сервисе које промовишу приступ правди за све, укључујући и правну помоћ”.<sup>75</sup>

Право на приступ правди и правично суђење гарантовано је чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права и слобода.<sup>76</sup> Остваривање овог права било је предмет разматрања многих међународних организација и форума, о чему сведоче бројне студије<sup>77</sup> и водичи.<sup>78</sup> У стандардизацији и олакшавању приступа правној помоћи значајне су активности Савета Европе, који је усвојио

71 О праву на правично суђење, шире: Van Dijk, P. Van Hoof, G. J. H. *Theory and Practice of European Convention on Human Rights*, Deventer: Kluwer, 1998; Janis, M. W. Kay, R.S., Bradley, A.W. *European Human Rights Law*, Oxford University Press, 2000; Gomien, D., Harris, D. and Zwaak, L. *Law and practice of the European Convention on Human Rights*, Strasbourg, 1996; Paunović, M., *Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava*, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 1993; Uzelac, A., *Hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravičnog postupka” iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda*, <http://alanuzelac.from.hr>; Petrušić, N. *Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti prava na rešavanje građanskopravne stvari u razumnom roku*, *Evropski mehanizmi zaštite ljudskih prava*, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2005.

72 Члан 10. Опште декларације о правима човека, Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 217 (III) од 10. децембра 1948. године.

73 Члан 14. ст. 1. Међународног пакта о грађанским и политичким правима („Sl. list SFRJ - Међународни уговори”, 7/719).

74 Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International Levels, <https://www.un.org/ruleoflaw/files/A-RES-67-1.pdf> (приступ 9. 10. 2018).

75 Тачка 14. Декларације.

76 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 1953. (у даљем тексту: ЕКЉП). Закон о ратификацији ЕКЉП (“Сл. лист СЦГ - Међународни уговори”, бр. 9/2003, 5/2005 и “Службеном гласник РС - Међународни уговори”, бр. 12/2010. Закон о ратификацији Протокола бр. 14 уз ЕКЉП (“Сл. лист СЦГ - Међународни уговори”, бр. 5/2005 и 7/2005).

77 Видети, нпр. студију “Towards justice accessible to all: legal aid machinery and certain local initiatives as seen by families affected by severe poverty” [H(92)2], [www.pili.org](http://www.pili.org). (страница приступ 10. 10. 2018).

78 Administering Justice in the 21st century, London, 8 and 9 June 2000. (Resolution No. 1). [http://www.coe.int/t/e/legal\\_affairs/legal\\_co-operation/steeringcommittees/cdcj/Documents/2000/CDCJ\\_\(2000\)\\_19E.pdf](http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/steeringcommittees/cdcj/Documents/2000/CDCJ_(2000)_19E.pdf). (страница приступ 10. 10. 2018).

бројне резолуције и препоруке,<sup>79</sup> укључујући и *Preporuku br R (81) državama članicama o merama koje olakšavaju pristup pravdi*,<sup>80</sup> у којој је наглашено да услов за запошљање поступка не сме да буде, имајући у виду природу случаја, неразумна suma novca, као и да државе треба да обезбеде да судске таксе буду smanjene или ukinute када представљају препреку приступа правди, а да cistem sudskih taksi bude ispitan у смислу те олакшице. Инструкциј државама за олакшавањ приступа правди садржане су и у Резолуцији “Пружање правде у 21. веку,<sup>81</sup> Резолуцији 2054 (2015) о једнакости и недискриминацији у приступу правди<sup>82</sup> и другим документима.

Право на правично суђење је једно од основних уставних права. У чл. 32. Устава РС<sup>83</sup> ово право је изричито прокламовано и гарантовано, док је у чл. 67. по први пут зајемчено право на праву помоћ, с тим што је остављено законодавцу да регулише услове за пружање бесплатне правне помоћи.

За многе грађане долазак у контакт са правосудним системом представља велики изазов. То посебно важи за економски депривирани, маргинализоване и рањиве друштвене групе. На то утичу бројне социјалне и културне баријере, (сиромаштво, социјална искљученост, слаба писменост, низак образовни ниво, непознавање службеног језика, стереотипи и предрасуде и др.), али и баријере институционалне природе, које постоје у самом правосудном систему, укључујући недостатак поверења у правосудни систем.<sup>84</sup> Ова реалност се све више препознаје и на глобалном нивоу, при чему се немогућност приступа правди повезује са сиромаштвом и неједнакошћу и сматра кршењем принципа владавине права и препреком одрживог инклузивног развоја. У *Програму одрживог развоја до*

79 Видети шире: Резолуција (76) 5 о правној помоћи у грађанским, комерцијалним и административним стварима, (<http://www.coe.int>, приступ 18. 11. 2017). Препорука (84)5 Комитета министара државама чланицама о начелима грађанског поступка за унапређивање остваривања правде. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#>, (приступ 8. 10. 2018).

80 Препорука Р (81)7 Комитета министара државама чланицама о мерама које омогућавају приступ правди (<https://hudoc.echr.coe.int/eng#>, (приступ 8. 10. 2018);

81 Resolution No 1 "Delivering justice in the 21st century", усвојена на 23. састанку европских министара правде одржаном 8-9. јуна у Лондону.

82 Resolution 2054 - Equality and non-discrimination in the access to justice . Дебата у Скупштини Савета Европе одржана је 24. априла 2015, када је и текст Резолуције усвојен. Резолуција је доступна на <http://www.refworld.org/docid/55b212584.html> (старници приступ 22. 11. 2017).

83 Устав Републике Србије, ("Сл. гласник РС", 98/2006)

84 Beqiraj, J. McNamara, L. (2014) International Access to Justice: Barriers and Solutions (Bingham Centre for the Rule of Law Report 02/2014), International Bar Association.

2030, усвојеном 2015. године,<sup>85</sup> као један од циљева одрживог развоја утврђена је промоција мирољубивих и инклузивних заједница за одрживи развој, осигурање једнаког приступа правди за све и изградња делотворних, одговорних и инклузивних институција на свим новоима (Циљ 16). Мере у оквиру циља 16, а посебно у оквиру циљева 16.3. и 16 б. усмерене су на примену принципа владавине права, једнаког приступа правди за све и спровођење антидискриминационих прописа и политика.

Искуство показује да су сиромашни грађани и припадници других рањивих друштвених група, баш због свог сиромаштва и рањивости, чешће него други грађани изложени кршењу права и различитим противправним делима. Зато је и њихова потреба за правном заштитом често већа у односу на остале грађане. Немогућност да у таквим ситуацијама користе механизме правне заштите погоршава њихову рањивост и додатно их искључује и маргинализује. Ова реалност се све више препознаје и на глобалном нивоу, при чему се немогућност приступа правди повезује са сиромаштвом и неједнакошћу и сматра кршењем принципа владавине права и препреком одрживог инклузивног развоја. У Програму одрживог развоја до 2030, усвојеном 2015. године,<sup>86</sup> новој глобалној развојној стратегији, као један од циљева одрживог развоја утврђена је промоција мирољубивих и инклузивних заједница за одрживи развој, осигурање једнаког приступа правди за све и изградња делотворних, одговорних и инклузивних институција на свим новоима (Циљ 16). Мере у оквиру циља 16, а посебно у оквиру циљева 16.3. и 16 б. усмерене су на примену принципа владавине права, једнакости у приступу правди и спровођење антидискриминационих прописа и политика.

Делотворан приступ правди превасходно подразумева могућност грађана да од суда траже и добију правну заштиту, али је он много је више од тога. Приступ правди не може се, наиме, сматрати делотворним ако грађани не познају своја права, ако страхују од правосудног система, ако им он није финансијски приступачан, ако се у њему тешко сналазе, због његове комплексности, непознавања језика

---

85 2030 Agenda for Sustainable Development . Доступно на <http://www.un.org/sustainabledevelopment/> (приступ 18.11. 2017). Овај програм се наставља на Миленијумске циљеве развоја, који су били усмерени на земље у развоју. Нови програм је свеобухватан је се односи на све земље и укључује националне политике.

86 2030 Agenda for Sustainable Development. Доступно на <http://www.un.org/sustainabledevelopment/> (приступ 10.10. 2018).

и др.<sup>87</sup> С друге стране, остваривање права на приступ правди зависи од многих фактора, међу којима је од примарне важности постојање адекватног система правне помоћи, који је „тачка“ повезивања грађана са правосудним системом, који им на тај начин постаје приступачан.<sup>88</sup> Међутим, иако је за делотворан приступ правди од примарне важности целовит и функционалан систем бесплатне правне помоћи, који у Србији још увек није успостављен,<sup>89</sup> велики значај има и установа ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка (тзв. сиромашко право), која је основ и за постављање бесплатног заступника.

## 2. Ослобођење од плаћања трошкова поступка

Сврха установе ослобођења о претходног плаћања трошкова поступка јесте да вођење парнице учини доступним странци која према свом опште имовном стању није у могућности да претходно сноси трошкове поступка, независно од тога да ли се јавља у улози тужиоца или туженог. Шире посматрано, ослобођење од плаћања трошкова израз је начела једнакости странака прд судом и представља вид конкретизације начела забране (посредне) дискриминације у остваривању права на правну заштиту по основу имовног стања.<sup>90</sup>

Прописи о ослобођењу од претходног плаћања трошкова поступка садржана су у XII глави Закона о парничном поступку,<sup>91</sup> која носи назив “Трошкови поступка”, у чл. 168-173, под маргиналним насловом “Ослобођење

87 Видети шире: Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (2013) United Nations Development Programme, доступно на: <http://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/Access%20to%20justice.pdf> (приступ 10.10.2018); Uzelac, A. (2019) Pristup pravosuđu – analiza stanja u RH i sažetak teza o mogućim pravcima projekta, <http://alanuzelac.from.hr/Pdf/access.pdf> (приступ 10. 10. 2018).

88 Global Study on Legal Aid (2016), United Nations, Vienna.

89 Рад на Закону о бесплатној правној помоћи започео је још 2008. године, када је објављен први Нацрт закона. У међувремену су предмет јавне расправе биле још три верзије овог закона, да би средином децембра 2018. Влада је усвојила Предлог Закона о бесплатној правној помоћи и упутила га у скупштинску процедуру, тако да се ускоро очекује његово доношење.

90 О посредној дискриминацији, детаљно: Павловић, С. Појам дискриминације, у: Невена Петрушић (ур), Судска грађанскоправна заштита од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности, Правосудна академија, Београд, 2012, стр. 136-141.

91 Закон о парничном поступку, “Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС и 55/2014. (у даљем тексту: ЗПП).

од плаћања трошкова поступка”,<sup>92</sup> а примењују се и у ванпарничном и извршном судском поступку, на основу правила о сходној примени ЗПП.

Законом о парничном поступку регулише услове са потпуно ослобођење од плаћања трошкова поступка, које обухвата ослобођење од плаћања судских такси и полагања предујма за извођење за трошкове сведока, вештака, увиђаја и судских огласа.<sup>93</sup> У погледу услова за делимично ослобођење, тј. ослобођење од плаћања судских такси, које ЗПП прописује само као могућност,<sup>94</sup> меродаван је Закон о судским таксама,<sup>95</sup> на чију примену ЗПП изричито упућује, прописујући да суд може ослободити странку и само од плаћања таксе, у складу са посебним законом.<sup>96</sup> У односу на услове за потпуно ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка прописане ЗПП-ом, Закон о судским таксама на другачији начин регулише услове за ослобођење од плаћања судских такси, као и дејство одлуке којом је странци признато право на ослобођење од плаћања судских такси. Због тога се може рећи да у погледу услова за ослобођење од плаћања трошкова поступка у домаћем правном систему постоје два различита режима – режим потпуног ослобођења, регулисан ЗПП-ом, и режим делимичног ослобођења, тј. ослобођења од плаћања судских такси, који је регулисан Законом о судским таксама.

## 2.1. Услови за ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка

### 2.1.1. Услови за потпуно ослобођење од плаћања трошкова поступка

Актуелни законски режим потпуног ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка преузео је, уз извесне мање измене, законска решења садржана у Закону о парничном поступку из 2004. године.<sup>97</sup> Овај закон у односу на прописе

---

92 Очигледно је да назив института није сасвим адекватан јер наводи на погрешан закључак да странка уопште дужна да плати парничне трошкове поступка. На исти начин је ова установа била означена и у савезном ЗПП, и у литератури је својевремено било указано на њено погрешно означавање. (Triva, S., Dika, M., *Gradansko parnično procesno pravo*, Narodne novine, Zagreb, 2004, str. 473. Штета је што су редактори законског текста пропустили прилику да установи дају коректан назив: - ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка.

93 Члан 186. Ст. 2. ЗПП.

94 Члан 168. ст. 3. ЗПП. Таквог изричитог упућивања није било у раније важећим законима.

95 „Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015 (у даљем тексту: ЗСТ).

96 Члан 168. ст. 3. ЗПП (in fine).

97 Закон о парничном поступку од 15. новембра 2004. године, "Сл. гласник РС", 125/2004 (у даљем тексту: ЗПП 2004).



Закон о парничном поступку из 1976. године,<sup>98</sup> који су важили пре његовог ступања на снагу, није потпуно трансформисао институт ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка, али је поједине одредбе кориговао и отворио простор за рестриктивна тумачења, што је, имајући у виду устаљену судску праксу, довело до сужавања домета ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка.<sup>99</sup> С обзиром да ЗПП није донео битне промене у погледу услова за потпуно ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка, рестриктивност је, као што ће се видети, остала обележје судске праксе и после ступања на снагу ЗПП.

Приликом регулисања ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка, законодавац је следио традиционална законска решења, предвидевши само потпуно или делимично ослобођење. Због оваквог чини се недовољно креативног приступа законодавца, пропуштена је шанса да се домаћи цивилилни процесни систем обогати и неким новим процесним инструментима, као што су одлагање претходног плаћања трошкова поступка до доношења одлуке и оброчно плаћање трошкова поступка,<sup>100</sup> којима би се значајно проширила могућност правних субјеката да приступе суду и остваре своје право на правну заштиту. Ако се зна да у Србији милион људи живи испод линије сиромаштва и да је око два милиона људи социјално угрожено,<sup>101</sup> јасно је да је свака бенефиција

98 До ступања на снагу ЗПП 2004, пред судовима Републике Србије примењиван је савезни Закон о парничном поступку од 24. 12. 1976. године ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и "Службени лист СРЈ", бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02., у даљем ЗПП 1976).

99 Видети резултате истраживања праксе Општинског суда у Нишу објављене у: Адамовић, А. Ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка – пракса Општинског суда у Нишу у 2007. години, у: Петрушић, Н. (ур.) Приступ правосудју – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, тематски зборник радова, књига трећа, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 211- 221.

100 Ovakve instrumente poznaje slovenačko procesno pravo (čl. 186. st. 3. Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečišćeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17). Видети, шире: Ude, L. Civilno procesno pravo, Uradni list, Ljubljana, 2002, str. 248-250.

101 Према резултатима анкета о приходима и условима живота (Survey of Income and Living Conditions - SILC), стопа ризика од сиромаштва износила је 24,6% у 2012. години. У поређењу са 28 земаља ЕУ, Република Србија је имала највећу стопу ризика сиромаштва. Подаци о кретању апсолутног сиромаштва, на основу података из Анкете о потрошњи домаћинства показују да је у 2012. години дошло до значајног раста стопе апсолутног сиромаштва у односу на 2011. годину - са 6,8% на 8,8%, док подаци за 2013. годину показују да је стопа сиромаштва незнатно смањена на 8,6%. Подаци показују да је најугроженије становништво оно које живи изван урбаних подручја, посебно у Централној Србији, деца и млади, необразовани, незапослени и неактивни носиоци домаћинства. Видети: Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији. Влада Србије, 2014. доступно на: <http://www.udruzenjesz.rs/images/PDF/Drugi-nacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smnjenju-siromastva-final.pdf>.

у погледу претходног плаћања трошкова поступка од изузетног значаја како за саме странке, тако и за остваривање принципа владавине права.

Према чл. 168. ст. 1. ЗПП, право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка има странка која према свом општем имовном стању није у могућности да сноси ове трошкове. Док је ранијим прописима право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка странци признато под условом да странка није у могућности да сноси трошкове без штете по нужно истражавање своје и своје породице,<sup>102</sup> ЗПП ово додатно одређење не предвиђа, што би могло да упути на закључак да право на ослобођење од плаћања трошкова поступка има само она странка која нема баш никаквих средстава да плаћа издатке за вођење парнице. Уколико би судови на овај начин тумачили ову одредбу, институт ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка практично не би ни имао значај. С обзиром на сврху института ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка, несумњива је потреба да се ова “немогућност”, кад су у питању физичка лица, процењује с обзиром на имовину којом странка располаже и нето месечне приходе које остварује, тј. приходе који су претходно умањени за издатке неопходне за нужно издржавање саме странке и чланова њене породице које је дужна да издржава.<sup>103</sup>

У чл. 168. ст. 4 ЗПП прописано је да приликом доношења одлуке о ослобођењу од плаћања трошкова поступка суд цени све околности, а нарочито узима у обзир вредност предмета спора, број лица које странка издржава и приходе и имовину које имају странка и чланови њене породице. Иако је апострофирао неколико критеријума за процену могућности странке да претходно сноси трошкове поступка, листа критеријума није затворена, што суду даје могућност, али и намеће обавезу да приликом одлучивања узме у обзир и друге критеријуме за процену могућности странке да сноси трошкове поступка.

Када је реч о вредности предмета спора, као критеријуму за утврђивање могућности странке да претходно сноси трошкове поступка, његова примена подразумева дужност суда да узме у обзир вредност предмета спора у контексту општег имовног стања странке, с обзиром да од вредности предмета спора приближно зависи висина издатака око вођења парнице, имајући у виду најнеповољнији могући исход парнице за странку. Примена таквог индивидуализираног приступа омогућава да суд о праву на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка одлучује оцењујући могућност

---

<sup>102</sup> Члан. 172. ст. 1. ЗПП 1976.

<sup>103</sup> Овакво решење предвиђено је у немачком праву. Видети: Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, München, 1993, стр. 491).

странке да претходно сноси трошкове конкретног поступка, имајући у виду очекиване издатке које ће конкретни поступак за странку произвести. Зато у неким случајевима странку која је релативно добро економски ситуирана, треба ослободити претходног плаћања трошкова поступка, јер због висине вредности предмета спора трошкови које претходно мора да сноси угрожавају њену егистенцију и егистенцију лица која је дужна да издржава.<sup>104</sup>

С друге стране, приликом одлучивања о признавању права на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка, неопходно је да суд узме у обзир врсту у природу спора, односно супстанцијалног права ради чије се заштите поступак покреће, као и његов значај за саму странку.

Када је реч о имовном стању странке, ЗПП прописује да су узима у обзир и приходе и имовину које имају не само странка, већ и чланови њене породице. У вези са тим, неопходно је имати у виду да због релативно добре економске ситуираности чланова породице странке, не би по аутоматизму требало одбити њен захтев за ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка. Наиме, у условима поремећених породичних односа које оптерећују сукоби и неслагања редовно изостаје породична солидарност, тако да опште имовно стање странке може бити веома лоше, упркос томе што чланови њене породице остварују високе приходе. Тако, на пример, уколико је странка покренула парницу за заштиту од насиља у породици против свог супруга, било би неправично и супротно духу института ослобођења претходног плаћања трошкова поступка уколико би се приликом утврђивање њеног општег имовног стања узели у обзир и приходи њеног супруга, јер је само покретање поступка, односно, намера његовог покретања индикација да су односи поремећени и да, упркос доброј економској ситуираности супруга и осталих чланова породице, странка није у стању да сноси трошкове поступка без угрожавања своје егистенције. Као што се код остваривања новчане социјалне помоћи жртвама насиља у породици приходи и имовина извршиоца насиља не узимају у обзир и не утичу на право жртаве насиља у породици да оствари новчану социјалну помоћ, не узимају у обзир приходи извршиоца насиља, што Закон о социјалној заштити<sup>105</sup> изричито прописује (чл. 81. ст. 5. Закона о социјалној заштити), тако у парницама у којима се решавају породичноправни спорови, не треба узети у обзир приходе члана породице кад год се они налазе у супротној страначкој улози. Било би корисно да то буде и изричито законом прописано.

<sup>104</sup> Тако и: Станковић, Г. Грађанско процесно право, Прва свеска, Парнично процесно право, Мегатренд, Београд, 2013, стр. 332.

<sup>105</sup> „Сл. гласник РС”, бр. 24/2011.

### 2.1.2. Услови за ослобођење од плаћања судских такси

Поред лица и органа која су по самом закону ослобођења плаћања судских такси<sup>106</sup> од плаћања таксе може бити ослобођена странка (таксени обвезник) ако би плаћањем таксе, имајући у виду висину средстава из којих се она и чланови њеног домаћинства издржавају, та средства била у толикој мери умањена да би тиме била угрожена њихова социјална сигурност.<sup>107</sup> Формулација наведеног прописа знатно је боља у односу на пропис садржан у ЗПП, којим је потпуно ослобођење од плаћања трошкова поступка условљено немогућношћу странке да сноси трошкове поступка, јер одражава смисао установе ослобођења од плаћања трошкова поступка.

Као и приликом одлучивања о потпуном ослобођењу од плаћања трошкова поступка, и ориликом доношења одлуке о ослобођењу од плаћања судских такси суд је дужан да цени све околности. И у ЗСТ су апострофиране поједине околности које треба узети у обзир, али се оне разликују од околности које су наведене у чл. 168. ст. 4. ЗПП. Према чл. 10. ст. 2. ЗСТ, суд је дужан да води рачуна о вредности меродавној за наплату таксе, укупном приходу странке и чланова њеног домаћинства и броју лица које издржава. За разлику од ЗПП-а, који говори о приходима чланова породице странке, ЗСТ говори о приходима чланова њеног домаћинства, при чему дефинише појам „домаћинство“, прописујући да је то заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода.<sup>108</sup> Решење садржану у ЗСТ је боље и прецизније јер искључује могућност да се приликом утврђивања имовног стања странке изме у обзир имовина члана њене породице са којим странка уопште не живи.

Када је реч о обавези издржавања, као фактору од кога зависи могућност ослобођења од плаћања судских такси, за разлику од ЗПП, који само упућује суд да узме у обзир број чланова породице које је странка дужна да издржава, ЗСТ регулише и круг „издржаваних лица“, у који спадају малолетна деца, односно усвојеници, деца, односно усвојеници на редовном школовању или на ванредним

106 Очигледно је да назив института није сасвим адекватан јер наводи на погрешан закључак да странка уопште дужна да плати парничне трошкове поступка. На исти начин је ова установа била означена и у савезном ЗПП, и у литератури је својевремено било указано на њено погрешно означавање. (Triva, S., Dika, M., *Грађанско парнично процесно право*, Народне новине, Zagreb, 2004, str. 473. Штета је што су редактори законског текста пропустили прилику да установи дају коректан назив: - ослобођење о претходног плаћања трошкова поступка.

107 Члан 10. ст. 1. ЗСТ.

108 Члан 10. ст. 3. ЗСТ.

студијама,<sup>109</sup> ако су незапослени, и то до навршене 26. године живота, унуци, ако их родитељи не издржавају и ако живе у домаћинству са странком, брачни друг<sup>110</sup> и родитељи, односно усвојиоци. Такав приступ у законском нормирању је начелно бољи, јер пружа странкама већу извесност у погледу остваривања права на ослобођење од плаћања судских такси, али је и недовољно флексибилан јер не омогућава да се узме у обзир обавеза издржавања коју странка има према лицу које не спада у круг „издржаваних лица“, какав је, на пример, случај са бабама и дедама странке. 2.2. Поступак за ослобођење од плаћања трошкова поступка

Поступак за потпуно ослобођење од плаћања трошкова поступка, без обзира да ли се тражи потпуно ослобађање или само ослобођење од плаћања судских такси, покреће странка предлогом у коме захтева да јој се призна право на ослобођење од плаћања трошкова поступка.<sup>111</sup>

Предлог се подноси првостепеном суду, а може се поднети у тренутку подизања тужбе, у самом тужбеном поднеску, или касније, у току читавог поступка, све до правноснажног окончања поступка.<sup>112</sup> Законодавац не прописује рок за доношење одлуке о ослобођењу од плаћања трошкова поступка, тако да одлука може бити донета све до правноснажног окончања поступка.

У погледу уредности предлога важе општа правила о уредности поднеска, као и правила о поступању суда када је поднет неуредан поднесак (чл.101. ЗПП). У пракси

<sup>109</sup> Треба приметити да је ова терминологија застарела, имајући у виду да ове категорије студија не постоје у домаћем систему високог образовања.

<sup>110</sup> Треба приметити да законодавац ванбрачне партнере није убројио у круг „издржаваних лица“. С обзиром да право на издржавање Породични закон ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015) признаје и ванбрачним партнерима (чл. 151) и прописује да се на издржавање ванбрачног партнера сходно примењују одредбе о издржавању супружника (чл. 152), приликом одлучивања о ослобођењу од плаћања судских такси треба узети у обзир и обавезу странке да издржава ванбрачног партнера, јер би, у противном, странка била дискриминисана у односу на странку која има обавезу да издржава брачног супружника.

<sup>111</sup> Члан 169. ст. 1. ЗПП и чл. 10. ст. 2 ЗСТ.

<sup>112</sup> Предлог поднет после правноснажног окончања поступка одбацује се као недозвољен. "Како је тужиља предлог за ослобођење од плаћања таксе за тужбу и одлуку поднела после правноснажног окончања поступка, односно пошто је пресуда, П. 4/05 од 12.5.2005. године, постала правноснажна, првостепени суд је правилно поступио када је предлог за ослобођење од плаћања трошкова таксе на тужбу и одлуку одбацио као неблаговремен." (Решење Округног суда у Ваљеву, Гж. 398/2006 од 13.4.2006. године). У пракси се срећу одлуке у којимс судови одбијају касније истакнути предлог за ослобођење, са образложењем да се приликом одлучивања узимају у обзир околности које су постојале у тренутку настанка обавезе плаћања судских такси, а не околности које су касније настале (Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж 39/2015 од 6.3.2015. године).

поједини првостепени судови одмах одбацују неуредни поднесак, без његовог враћања на исправку, односно допуну, што је разлог за укидање таквих решења.<sup>113</sup>

Поступак за ослобођење од плаћања трошкова поступка има катактер инциденталног поступка,<sup>114</sup> који се придружено води уз поступак о главној ствари.

Уз предлог за ослобођење од плаћања трошкова поступка странка је дужна да поднесе доказе о свом имовном стању. Међутим, за разлику од ЗПП 2004, којим је било прописана дужност странке да уз предлог поднесе уверење надлежног органа о имовном стању, уз прецизно навођење еподатака које уверење трба да садржи,<sup>115</sup> важећи ЗПП прописује да је странка која захтева ослобађање од трошкова дужна да уз предлог наведе чињенице и поднесе доказе којима се чињенице потврђују.

Поступак за ослобођење од плаћања трошкова поступка заснован на истражном начелу, јер је у питању примена когентних законских норми. Зато Важећи ЗПП, као и ЗПП 2004, пружа суду могућност да, ако оцени да је потребно, по службеној дужности прибави потребне податке и обавештења о имовном стању странке која тражи ослобађање.<sup>116</sup> Међутим, док је ЗПП 2004 прописивао могућност да суд у погледу околности које се тичу имовног стања странке саслуша противну странку, важећи ЗПП такву могућност не прописује, већ упућује суд да саслуша саму странку о чијем захтеву одлучује, што је свакако боље решење.

Када је реч о начину доказивања имовног стања, ЗСТ (и даље) прописује дужност странке да из предлог за ослобађање од плаћања судских такси поднесе уверење надлежног органа о свом имовном стању, при чему

---

113 “Захтев тужиље јесте неуредан, јер не садржи све што је потребно да би се по њему могло поступити. Међутим, суд није могао одбити неуредан захтев тужиље, а да је претходно није позвао да у року који јој одреди достави потребне доказе, да је поучи о томе које доказе, каква уверења, какве садржине је дужна да достави да би суд одлучио о њеном захтеву за ослобађање од плаћања судске таксе. Законско право на ослобађање од плаћања судске таксе има за циљ да омогући право на судску заштиту и лицима која нису у могућности да плате судску таксу. Решење какво је донео првостепени суд подразумевало би да је свако лице које приступи суду ради заштите права којег сматра да му је повређено дужно да познаје прописана правила о плаћању и ослобађању од плаћања судске таксе. Таква претпоставка није прихватљива и не налази смисао у остварењу једног од основних грађанских права, остварењу права на слободан приступ суду.” (Решење Привредног апелационог суда, Пж. 127/2014 од 16.1.2014. године).

114 Станковић, Г. *op. cit.* стр. 322.

115 Члан 165. ст. 2. и 3. ЗПП 2004.

116 Члан 165. ст. 4. ЗПП 2004 и чл. 169. ст. 3. ЗПП.

детаљано регулише шта уверење треба да садржи, а то су подаци о висини прихода таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства, као и о другим изворима прихода и уопште о имовном стању лица коме се издаје уверење. Закон такође прописује да ово уверење може служи као доказ за ослобођење од плаћања таксе само ако од његовог издавања до подношења предлога за ослобођење није протекло више од шест месеци.<sup>117</sup>

Нејасни су разлози због којих је законодавац предвидео различите режиме у погледу доказа који се могу користити за доказивање имовног стања странке: ако странка тражи потпуно ослобађање од плаћања трошкова поступка, може своје имовно стање доказивати свим расположивим доказима, а ако тражи ослобођење од плаћања судских такси, мора прибавити уверење надлежног органа. Не постоји ни један рационални разлог за постојање ових разлика; странци би требало омогућити да своје имовно стање докаже свим доказима којима располаже.

За разлику од ЗПП, који искључује могућност да суд приликом утврђивања имовног стања странке саслуша њеног противника, ЗСТ ту могућност и даље прописује,<sup>118</sup> иако за тим не постоји потреба, посебно имајући у виду обавезу странке да поднесе уверење надлежног органа о свом имовном стању, коју ЗСТ прописује.

Сматра се да решење којим суд уља захтев за ослобођење од плаћања трошкова поступка, не мора бити формално изражено, већ може бит забележено службеном белешком на спису, односно на оном поднеску у коме је захтев садржан.<sup>119</sup>

У погледу жалбе на решење којим је усвојен предлог страке важе различита правила. Наиме, према чл. 169. ст. 4. ЗПП, против решења суда којим се усваја предлог за ослобођење од плаћања трошкова поступка није дозвољена посебна жалба, док према чл. 11. ст. 6. ЗСТ против решења о ослобађању од плаћања судских такси уопште није допуштена жалба. Нејасни су разлози због којих су правила различита, а свакако их треба уједначити искључивањем могућности да се ово решење напада жалбом, без обзира да ли је реч о потпуном ослобођењу или о ослобођењу од плаћања судских такси. Када је у питању решење којим је одбијен захтев за ослобођење, странка има право на жалбу, која ни на који начин не утиче на ток поступка о главној ствари.

<sup>117</sup> Члан 11. ЗСТ.

<sup>118</sup> Члан 11. ст. 5. ЗСТ.

<sup>119</sup> Станковић, Г. *op. cit.* стр. 323.

### 2.3. Дејство подношења предлога за ослобођење

Подношењем предлога за ослобођење од плаћања трошкова поступка, свих или само судских такси, странка није дужна да плаћа судске таксе, нити да полаже предужем за извођење доказа све док решење којим суд одбија њен захтев не постане правноснажно. То важи и када је странка поднела предлог за ослобађање од плаћања судских такси.

### 2.4. Дејство решења о ослобођењу од плаћања трошкова поступка

Из одредаба ЗПП произлази да решење о потпуном ослобођењу од претходног плаћања трошкова поступка важи само у погледу трошкова судског поступка који је странка покренула. Међутим, ЗСТ знатно проширује дејство решења о ослобађању од плаћања судских такси, прописујући да ослобођење од плаћања таксе дато у парничном и ванпарничном поступку важи и у поступку извршења одлука донетих у тим поступцима, ако се извршење захтева у року од три месеца по правноснажном окончању поступка, као и да ослобођење од плаћања таксе у ванпарничном и извршном поступку важи и у парничном поступку који настане у току и поводом ванпарничног и извршног поступка.<sup>120</sup> Несумњиво је да ова законска правила знатно доприносе остваривању права на приступ правди и требало би да важе и у поступку за потпуно ослобођење од плаћања трошкова поступка.

Законом о судским таксама прописано да се решење којим је усвојен захтев за ослобођење од плаћања судских такси односи на све таксе по одговарајућем предмету, без обзира када је настала таксена обавеза, из чега произлази да решење производи дејство *ex tunc*.<sup>121</sup>

### 2.5. Право правних лица на ослобођење од плаћања трошкова поступка

У време важења југословенског ЗПП, међу домаћим процесуалистима је владало мишљење да право на ослобођење од претходног плаћања трошкова

---

<sup>120</sup> Члан 13. Ст. 2. ЗСТ.

<sup>121</sup> Чл. 14. ст. 1.



поступка има само физичко лице.<sup>122</sup> Овај став преовлађује и у домаћој литератури насталој после доношења ЗПП 2004, мада се све више прихвата схватање да у актуелном процесном режиму право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка ово припада и физичким и правним лицима,<sup>123</sup> што се аргументује чињеницом да Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода гарантује право на правично суђење и физичким и правним лицима.

Законодавац није експлицитно ускратио право правним лицима право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка,<sup>124</sup> нити се децидирано изјаснио ко су титулари права на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка.<sup>125</sup> (користио је неутрални термин “странка”). Из законског текста несумњиво, међутим, произлази да ово право припада само физичким лицима јер су инструкције које је упutio суду у погледу околности о којима треба да води рачуна приликом одлучивања о захтеву странке за ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка (број чланова породичног домаћинства, приходи чланова

122 Видети: Triva, S. Dika, M. *Грађанско парнично процесно право*, Zagreb, 1986, str. 474; Poznić, B., Rakić Vodinečić, V. *Грађанско процесно право*, 15. izdanje, Beograd, 1999, str. 367; Станковић, Г. *Грађанско процесно право*, Јустинијан, Ниш, 2004, стр. 312; Палачкович, Д., *Парнично процесно право*, Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2004, стр. 293. Поједини процесуалисти се нису изјашњавали о томе ко је титулар права на ослобођење од плаћања трошкова поступка (Старовић, Б. Кеча, Р. Грађанско процесно право, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 1995, стр. 209-210.

123 Станковић, Г. *op. cit.* стр. 331; Јакшић, А. *Грађанско процесно право*, Центар за публикације Правног факултета у Београду, Београд, 2006, стр. 496.

124 Такво решење је постојало у словеначком Закону о правном поступку. Одредбама чл. 168. ст. 5. ЗПП било је предвиђено да одредбе о ослобођењу од плаћања трошкова поступка, као и одредбе о одложеном и оброчном плаћању судских такти не важе за предузетнике у парницама везаним за њихову делатности, као ни за правна лица. Ове одредбе су током 2003. године биле предмет оцене уставности и Уставни суд Словеније је својом одлуком прогласио неважећим. Основни аргумент који је Уставни суд навео у образложењу своје одлуке био је да је искључивањем могућности да користе законске бенефиције у погледу плаћања судских такса предузетницима и правним лицима која нису у могућности да плате судске таксе у потпуности онемогућено остваривање права на правну заштиту, с обзиром да је чл.180. ст. 4. ЗПП, предвиђена фикција о повлачењу тужбе за случај да странка уз тужбу није приложила доказе о плаћеним таксама, а нису испуњени услови за ослобођење од плаћања судских такси. Ово правило било је, иначе, било унето у словеначко цивилно процесно право чл. 9. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, “Урадни list RS”, 96/02. (Videti odluku Ustavnog suda RS, br. U-I-55/99-28, od 5. 6. 2003, (“Урадни list RS”, 26/99, 96/02 i 12/03 ur.p.b.).

125 С обзиром да се у нашој законодавној пракси (већ одавно) не практикује објављивање стенографских бележака о раду експертских тимова за припрему законских пројеката, нити се припремају детаљна образложења закона, непознато је да ли су чланови радне групе за припрему Нацрта ЗПП уопште разматрали ко би требало да ужива право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка.

породице и сл.), очигледно дизајниране према “природним” карактеристикама физичких лица. Сагласно томе, од странака се захтева да уз предлог поднесу уверење надлежног органа о имовном стању, у коме се мора назначити износ пореза који плаћа домаћинство и поједини чланови домаћинства, као и други извори њихових прихода и уопште имовно стање странке којој се издаје уверење (чл. 165. ЗПП). Недвосмислено се, дакле, може закључити да се, према важећем ЗПП, само ова лица могу сматрати титуларима права на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка. Због тога не изненађује што се у судској пракси право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка признаје искључиво физичким лицима, што потврђују и ретке публиковане судске одлуке које се тичу ове процесне установе.

Ако је основна сврха и правно-политички циљ права на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка остваривање права на приступ суду, као једног од елемената права на правично суђење, чини се да би ово право требало изричито признати свим физичким и правним лицима, као и облицима удруживања којима је призната страначка способност. У прилог томе могу се навести неколико разлога. Пре свега, треба имати у виду да ЕКЉП гарантује свим правним субјектима право на правично суђење, што произлази из израза “свако”, који је употребљен у формулацији одредбе чл. 6. ст. 1. Конвенције, што је Европски суд за људска права много пута потврдио у својим пресудама. Право на правично суђење припада свим физичким и правним лицима,<sup>126</sup> као и оним социјалним групама које немају правну способност, али које испуњавају услов за признавање страначке способности, односно права стајања пред судом.<sup>127</sup> С друге стране, и према Уставу РС, право на правично суђење припада и физичким и правним лицима јер је у одредби чл. 32. Устава којом је гарантовано право на правично суђење такође употребљен израз “свако”. Коначно, на овакав закључак упућује и одредба чл. 21. Устава РС, према којој “свако” има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

---

126 У државама које су ратификовале ЕКЉП право на правично суђење у грађанскоправним стварима припада свим њеним држављанима, држављанима других држава, као и апатридима, у свим поступцима у којима њихова грађанска права и обавезе утврђује национални суд или неко друго надлежно тело. Право на правични поступак не зависи од било каквих личних својстава или статуса странке, као што су место њеног пребивалишта или бораваишта, њена правна, пословна, страначка или процесна способност, евентуални избеглички статус или статус расељеног лица и сл.

127 О томе детаљно: Petruši N., *Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti prava na rešavanje građanskopravne stvari u разумном року, Европски механизми заштите људских права, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2005, стр. 219).*

Несумњиво је да законодавац има пуну слободу у погледу уређивања правозаштитних механизма и прописивања услова под којима се остварује право на правну заштиту, али је он дужан, сагласно општеприхваћеним међународним стандардима, да свим правним субјектима обезбеди ефективан и делотворан приступ суду. Чињеница је да, поред физичких лица, и правна лица и предузетници могу бити у немогућности да претходно носе издатке које вођење судског поступка подразумева. Таква ситуација редовно настаје кад је правном лицу блокран жирос рачун, што је у пракси честа појава. У појединим ситуацијама стање неликвидности правног лица, односно предузетника последица је нелегалног понашања управо онога против кога правно лице, односно предузетник намерава да покрене поступак. Уколико правно лице, односно предузетник у таквим околностима не би био ослобођен претходног плаћања трошкова поступка, његово право на правично суђење било би озбиљно угрожено.

С друге стране, у појединим ситуацијама постоји посебна потреба да правна лица буду ослобођена претходног плаћања трошкова поступка јер покрећу поступак ради заштите колективних права од посебног друштвеног значаја, какви су нпр. поступци за заштиту од дискриминације групе лица<sup>128</sup> или поступци ради заштите животне средине који се могу покренути путем *actio popularis*.<sup>129</sup> Ови примери потврђује потребу да правним лицима буде изричито призна право на ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка, уз прецизирање адекватних претпоставки под којима би ово право могли да остварују. При томе би требало размислити и о евентуалном привилеговању појединих правних лица, каква су нпр. непрофитне организације за заштиту људских права еколошке организације и др.<sup>130</sup>

128 Члан 46. ст. 1. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, бр. 22/09). О активної легитимацији организација које се баве заштитом људских права у антидискриминационим парницама, детаљно: Петрушић, Н. Крстић, И. Маринковић, Т. Коментар Закона о забрани дискриминације, Гласник, Београд, стр. 335-340.

129 Шире: Петрушић, Н. Заштита од имисија у грађанском судском поступку, Правни живот, тематски број. Право и демократска култура, Год. 52, том 4, бр. 12 (2003), стр. 255-274.

130 Кад су у питању еколошке организације, потреба за олакшавањем приступа правосудју извире и из појединих међународних докумената у области заштите животне средине, као што је, нпр. Архуска конвенција. Детаљно: Право на адекватну животну средину (нр. Тодић, Д. Вукасовић, В), Београд, 2001, стр. 95-107. О проблемима и ризицима са којима се суочавају еколошкеорганизације својим покушајима да издејствују судску одлуку којом се спречева загађење животне средине, детаљно: Петрушић, Н., Грађанскоправни инструменти еколошке заштите у домаћем праву, Зборник радова, “Грађанска кодификација”, Св. 2., Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2003, стр. 339-363.

### 3. Ослобођење од плаћања трошкова поступка у судској пракси – домети, лимити и изазови

Иако још нису остварени потпуни увиди у праксу судова у ослобођењу од плаћања трошкова поступка, истраживања показују да у пракси постоје значајни проблеми у погледу остваривања права на ослобођење од плаћања трошкова поступка.

Према налазима истраживања спроведеног 2018. године, којим су била обухваћена 23 основна суда у Србији,<sup>131</sup> утврђено је да судови не воде евиденцију о поднетим предлозима за ослобађање од плаћања парничних трошкова,<sup>132</sup> а програм за аутоматско вођење предмета (AVP) уопште не садржи рубрику на уношење података о поднетим или усвојеним захтевима за ослобођење од плаћања трошкова поступка. Због тога ни на нивоу судова ни на нивоу државе не постоје подаци о броју странака које су ослобођење претходног плаћања трошкова поступка.<sup>133</sup>

У пракси странке, по правилу, подnose предлог за ослобођење од трошкова поступка без навођења обима ослобођења, а судови, по правилу, ослобађају странке само плаћања судских такси. У свим одлукама, без обзира на обим ослобођења, садржана је поука о правном леку у којој се наводи да жалба на решење није дозвољена. Чак и у случајевима када странке траже потпуно ослобођење од плаћања трошкова поступка, диспозитив решења којим се странци признаје само ослобођење од плаћања судских такси не садржи одлуку да се предлог за ослобађање од плаћања трошкова одбија у делу осталих трошкова поступка. С обзиром да у погледу ових трошкова не постоји одбијајућа одлука, изостаје и образложење разлога због којих суд није у целини усвојио захтев странке, а странци. С друге стране, оваквим поступањем странци се ускрађује право на жалбу против дела одлуке којом је њен захтев одбијен. Када је реч о року за изјављивање жалбе који се наводе у поуци о правном леку, постоји неуједначеност: неки удови странке поучавају да жалбу поднесу у року од 8 дана, а неки наводе рок 15 дана од пријема отправка решења.<sup>134</sup>

---

131 Анализа судске праксе, Поступање судова по предлогу за ослобађање од плаћања судских трошкова у парничној материји, YUCOM, Београд, 2018.  
Доступно на: <http://www.mdftjss.org.rs/archive//file/Analiza%20sudske%20prakse%20oslobadje%20od%20troskova.pdf> (приступ 10. 10. 2018)

132 Анализа судске праксе, оп. цит. стр. 2.

133 Видети: Функционална анализа правосуђа у Србији, Мултидонаторски поверенички фонд за подршку сектору правосуђа у Србији, Београд, 2014. стр. 27.  
Доступно на: [https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Funkcionalna%20analiza%20pravosudja%20u%20Srbiji\\_0.pdf](https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Funkcionalna%20analiza%20pravosudja%20u%20Srbiji_0.pdf) (приступ 10. 10. 2018)

134 Исто.

Пракса судова у прибављању података и обавештења које се тичу услова за ослобођење прилично је неуједначена. Поједини судови сами прибављају податке о чињеницама које је странка изнела у предлогу, неки прибављају податке само у погледу чињенице које сматрају релевантним, а за које сазнају у току поступка о главној ствари, док поједини судови уопште не прибављају податке по службеној дужности, већ одлучују на основу чињеница и доказа које је сама странка поднела.<sup>135</sup>

Приликом одлучивања о предлогу за ослобођење судови углавном имају у виду околности на које сам закон упућује, а спорадично узимају у обзир здравствено стање, године старости и радну способност подносиоца предлога. Околност да је странка током поступка имала адвоката редовно се сагледава као индикатор доброг имовног стања странке.

Посебно забрињава то што судови, по правилу, не утврђују чињенице у погледу имовног стања чланова домаћинства подносиоца предлога, као и укупан приход странке и чланова његовог домаћинства, већ само чињенице које се односе на имовно стање подносиоца предлога.<sup>136</sup>

У пракси је релативно широко распрострањена појава да судови уопште не одлучују о захтеву странке за ослобођењем од плаћања трошкова поступка, што отежава положај странака јер не постоји одлука на коју могу изјавити жалбу. У таквим случајевима странка најпре мора да изјави предлог за доношење допунског решења о ослобађању од плаћања трошкова поступка, а тек након његовог доношења може евентуално изјавити жалбу, што доводи до пролонгира и странку ставља у неизвесан положај у погледу могућности да даље учествује у поступку. Због тога не изненађује да је у многим поступцима у којима је стављен предлог за ослобођење од плаћања трошкова поступка долази до повлачења тужбе.<sup>137</sup>

---

135 Исто

136 Исто

137 Видети Адамовић, А. *op. cit.* стр. 218.

#### **4. Уместо закључка**

Ослобођење од претходног плаћања трошкова је традиционална установа која је израз настојања да се омогући једнакост у приступу правди и странкама слабијег имовног стања омогући да траже и остваре судску заштиту својих грађанских субјективних права. Анализа законских прописа показује да су многа решења неадекватна и рестриктивна и да постоји неусаглашеност у погледу услова под којима се према ЗПП и ЗСТ странци признаје право на ослобођење од плаћања трошкова. Негативне ефекте неадекватних законских решења додатно појачава и неправилна и рестриктивна примена законских прописа, која сужава домета установе ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка.

**Јадранка Митровски**

Судија Апелационог суда у Нишу

## **МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР ЗАБРАНЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ**

*Абстракт:*

*Увек актуелно питање дискриминације, тј. њеног сузбијања, ни у актуелном националном, нити на пољу интернационалног права, није изгубило на значају. Штавише, данашња геополитичка ситуација намеће потребу успостављања што ефикаснијег правног оквира, али и његове дословне примене у овом домену. Узевши у обзир положај судијске функције у правном поретку наше земље, као особа које свакодневно примењују, тумаче и конкретизују апстрактне правне норме, од изузетног је значаја добро познавање националне регулативе, али се пажња мора поклонити и међународноправном оквиру за заштиту од дискриминације. Аутор у овом реферату даје приказ најзначајнијих докумената створених у домену међународно-правне заштите од дискриминације.*

*Кључне речи:*

*забрана дискриминације, међународно право, људска права, Уједињене нација, Савет Европе*

### **ПОЛОЖАЈ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Пре свега неопходно је одредити положај међународног права у односу на национално право, односно на прецизан начин дефинисати место међународног права у правном поретку Републике Србије. Одговор на

ово питање може се пронаћи у Уставу Републике Србије из 2006 године. Чл. 16. ст. 2 Устава прокламује „Општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују.“ Тумачењем ове норме може се закључити да је уставотворац прихватио монистичку концепцију по којој су национално и међународно право део јединственог правног поретка. Што се тиче примене норми из домена међународног права, други део овог става члана 16. Устава прописује њихову директну примену, тј. међународни обичаји самим тренутком настанка постају део нашег правног поретка, док се међународни уговори тренутком потврђивања инкорпоришу у правни систем Републике Србије. Када се говори о непосредној примени међународног права неизоставно је поменути и члан 18. Устава који и носи наслов „Непосредна примена зајамчених права“ и који прописује да се Уставом јемче и непосредно примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима.

Такође, врло је важно на адекватан начин одредити и позицију на хијерархијској лествици општих аката у нашем правном поретку. Наш позитивни Устав не садржи изричиту одредбу која регулише однос између унутрашњег и међународног права, за разлику од решења које је постојало у акту који је важио до његовог доношења<sup>138</sup>. Тумачењем одредаба Устава може се закључити однос унутрашњег и међународног права, и то анализом, већ поменутог, члана 16. Устава, где се након већ цитираног дела наводи и да потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом. Поред члана 16. од значаја су и члан 194. који уређује хијерархију општих аката, као и члан 167. којим се уређује надлежност Уставног суда. Из наведеног се може доћи до закључка да је Устав, наравно, највиши правни акт, да сви остали акти морају бити у складу са њим, укључујући и потврђене међународне уговоре, а да закони, поред тога што морају бити у складу са Уставом, не смеју бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права, при чему оцену уставности међународних

---

<sup>138</sup> Уставна повеља Државне заједнице СЦГ експлицитно је давала примат међународном праву у односу на национално, што се може видети из члана 16. овог конституционалног акта: „Ратификовани међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права имају примат над правом Србије и Црне Горе и правом држава чланица.“



уговора и усклађености закона и подзаконских аката са међународним уговорима врши Уставни суд Републике Србије.

Као добар пример за примену међународних уговора од стране домаћих судова може се навести познати случај „Крсмановача.“ У том случају радник Спортско-рекреативног центра „Крсмановача“ у Шапцу није дозволио да троје лица уђе на базен само због тога што су Роми. Након првостепеног и другостепеног поступка пред надлежним судовима, поднет је захтев за ревизију о коме је одлучивао тадашњи Врховни суд Србије. Обзиром да тада није постојао ниједан антидискриминациони закон (2000. године), Суд се директно позвао на ратификоване међународне уговоре који су забрањивали дискриминацију, и то на Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације и на Пакт о грађанским и политичким правима, и у образложењу одлуке навео: „Ратификоване међународне конвенције, по изричитим одредбама Устава, чине саставни део унутрашњег правног поретка.“

Позиција наше земље у оквиру глобалне и регионалне међународне заједнице намеће обавезу разликовања између регулативе која постоји у оквиру Организације Уједињених нација (као најзначајније глобалне организације) и регулативе која постоји у оквиру организација које делују на тлу Европе.

### **УНИВЕРЗАЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ**

Бројни су међународни документи на глобалном плану који имају значај у овој области. Поједини од њих нису искључиво фокусирани на забрану дискриминације, већ регулишу шири круг питања, при чему је забрана дискриминације само једно од питања којима се баве. Са друге стране, постоји и друга група докумената која је искључиво посвећена сузбијању појединачних облика дискриминације. У прву групу докумената могу се убројити Повеља Уједињених нација, Општа декларација о људским правима, Пакт о грађанским и политичким правима и Пакт о економским, социјалним и културним правима, док у другу категорију спадају Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена и Конвенција о правима особа са инвалидитетом.

## ПОВЕЉА УН

Повељом Организације Уједињених нација пре свега регулисани су односи између држава чланица, али овај акт садржи и одредбе које се тичу људских права, при чему је посебно наглашена забрана дискриминације. У самој преамбули Повеље истиче се: „Ми, народи УН, решени ... да поново потврдимо веру у основна права човека, у достојанство и вредности људске личности, у равноправност мушкараца и жена и нација великих и малих ...“ Такође, као један од четири главна циља Организације, наводи се остваривање међународне сарадње ради решавања међународних проблема, економске, социјалне, културне и хуманитарне природе, као и ради унапређења и подстицања поштовања људских права и основних слобода за све, без обзира на расу, пол, језик или веру. Неопходно је поменути и чл. 55. Повеље, не мање важан, да ће Уједињене нације ради стварања услова стабилности и благостања, који су неопходни за пријатељске и мирољубиве односе између нација, засноване на поштовању начела равноправности и самоопредељења, помагати поштовање и уважавање људских права као и основних слобода за све без обзира на расу, пол, језик или веру.

Уношењем наведених одредби у „устав“ међународне заједнице недвосмислено су интернационализована људска права, чиме су су изузета из искључиве надлежности држава чланица, те је обавеза њиховог поштовања добила шири карактер. Услед различитог нивоа поштовања људских права у државама оснивачима УН и карактера Повеље, у овај документ нису унети високи и конкретни стандарди, али је очигледно да је већ тада постојала спремност да се елиминише дискриминација у уживању људских права, тако да она припадају свима без обзира на расу, пол, језик или веру. Како је правна природа норме садржаних у Повељи била апстрактна, било је неопходно конкретизовати их, што је и учињено усвајањем Опште декларације о људским правима.

## ОПШТА ДЕКЛАРАЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Општа декларација о људским правима усвојена је од стране Генералне скупштине УН 1948. године. У погледу забране дискриминације треба поменути преамбулу Декларације у којој је истакнуто да су „признавање урођеног достојанства и једнаких неотуђивих права свих припадника људског рода темељ слободе, правде и мира у свету“. Најважнија правила

за забрану дискриминације налазе се у чл. 1. и 2. Опште декларације. У чл. 1. прокламовано је следеће начело: „Сва људска бића се рађају слободна и једнака у достојанству и правима“. Чл. 2 ст. 1. овог акта сваком лицу гарантује једнакост у правима и слободама прописаним овим инструментом, без икакве разлике, по основу „расе, боје коже, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или неког другог статуса“. Други став истог члана забрањује прављење разлике и на основу политичког, правног или међународног статуса земље којој неко лице припада, тако да сва лица уживају иста права без обзира да ли живе у земљи која је независна, под старатељством, несамоуправна или јој је сувереност на било који други начин ограничена.

Право на једнакост и забрана дискриминације истакнути су у Општој декларацији још на неколико места. У члану 7. стоји да су сви једнаки пред законом и да сви имају право, без икакве разлике, на подједнаку законску заштиту. Истим чланом свим лицима се гарантује заштита од сваке дискриминације којом се крши Декларација и забрањује подстицање на дискриминацију. У члану 16. и чл. 21. ст. 2 признаје се равноправност пунолетних мушкараца и жена код склапања брака, као и код приступа јавним службама у својој земљи. На крају, чл. 23. ст. 2 истиче да „Свако, без икакве разлике, има право на једнаку плату за једнак рад“.

## **ПАКТ О ГРАЂАНСКИМ И ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА**

Пакт о грађанским и политичким правима усвојен је 1966. године, а ступио је на снагу 1976. године.<sup>139</sup> Уз овај Пакт усвојена су и два факултативна протокола, од којих је првим омогућено подношење индивидуалних претставки Комитету за људска права, док се другим укида смртна казна. Наша држава уговорница је како самог Пакта, тако и оба факултативна протокола.

Пакт садржи више чланова који се односе на забрану дискриминације, од којих су најзначајнији чл. 2, 3. и 26.

---

<sup>139</sup> ПГПП ступио је на снагу три месеца након депоновања 35. ратификационог инструмента код овлашћеног депозитара (Генерални секретар Уједињених нација)

Чланови 2. и 3. Пакта садрже тзв. зависне одредбе, јер забрањују дискриминацију у погледу поштовања оних људских права садржаних у Пакту. Ови чланови се односе само на дискриминацију у уживању грађанских и политичких права гарантованих Пактом, као што је нпр. право на приватност, слобода кретања, право на удруживање или мирно окупљање. Другим речима, лица се не могу позвати само на чл. 2 и / или чл. 3, већ се једино могу позвати на њихово кршење у вези са неким другим правом гарантованим самим Пактом.

За разлику од чланова поменутих у претходном ставу, члан 26. је независан. Њиме је предвиђена забрана дискриминације у остваривању било ког права предвиђеног националним правом. Ово подразумева да забрана дискриминације прокламована овим чланом није ограничена само на права зајемчена Пактом о грађанским и политичким правима, већ се овим чланом захтева од држава да приликом доношења националних прописа не врше дискриминацију, чак ни приликом формулисања оних права чије признавање сам Пакт не захтева. Дакле, државе имају слободу да одлуче да ли ће у своје законодавство унети нека права које Пакт не садржи, али ако таква права уграде у национално законодавство, та права морају бити призната свима без икакве дискриминације. При томе, државе морају имати овакав приступ не само у погледу грађанских и политичких права, већ и у погледу економских, социјалних и културних права<sup>140</sup>.

Од велике је важности напоменути да листа забрањених основа у претходно наведеним члановима није затворена, јер се на крају набрајања наводи да то може бити и било који други статус. Дакле, листа побројаних основа дата је *exempli causa*, у ком смислу је Комитет за људска права, као забрањене основе дискриминације, прихватио и држављанство, старосно доба, брачно стање, сексуалну оријентацију и др.

## ПАКТ О ЕКОНОМСКИМ, СОЦИЈАЛНИМ И КУЛТУРНИМ ПРАВИМА

Генеза Пакта о економским, социјалним и културним правима идентична је настанку Пакта о грађанским и политичким правима (усвојен 1966. године; ступио на снагу 1976. године). Уз овај Пакт усвојен је и Факултативани

---

<sup>140</sup> Комитет за људска права категорички је признао ово у предмету *Broeks v. the Netherlands* (Human Rights Committee, S. W. M. Broeks v. The Netherlands, Communication No. 172/1984).

протокол, при чему наша држава, иако је уговорница и овог Пакта, још увек није ратификовала Факултативни протокол.

Кључна норма која се односи на забрану дискриминације садржана је у чл. 2 Пакта и представља несамосталну гаранцију, јер се од држава уговорница захтева да обезбеде остваривање без дискриминације само оних права која су зајемчена овим Пактом. Забрањени основи дискриминације исти су као и код Пакта о грађанским и политичким правима, што подразумева да листа побројаних основа дискриминације није дефинитивна, већ индикативна.

### **КОНВЕНЦИЈА О УКИДАЊУ СВИХ ОБЛИКА РАСНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ**

Усвајању Конвенције претходила је Декларација о укидању свих облика расне дискриминације, коју је усвојила Генерална скупштина УН 1963. године у форми резолуције. Као ни остале резолуције Генералне скупштине, ни ова Декларација није имала обавезујући карактер, те је, у оквиру УН, две године касније усвојена Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, која ће имати обавезну снагу за све државе уговорнице. Конвенција је преузела доста одредби из Декларације, али је унела и нека побољшања, дајући пре свега дефиницију расне дискриминације и оснивање међународног надзорног механизма над применом Конвенције. Конвенција данас има 177 држава уговорница, међу којима је и Србија, а ступила је на снагу 1969. године.

Ова Конвенција, за разлику од Пактова о људским правима, садржи дефиницију дискриминације и то у чл. 1. ст. 1. Конвенције: „Расна дискриминација представља свако разликовање, искључивање, ограничавање или давање првенства које се заснива на раси, боји коже, прецима, националном или етничком пореклу и која има за циљ или за резултат да наруши или угрози признавање, уживање или вршење, под једнаким условима, људских права у политичкој, привредној, социјалној, културној или било којој другој области јавног живота.“

Ратификацијом Конвенције државе су се обавезале да предузму све мере како би укинуле расну дискриминацију и њено подстицање, укључујући и измену свог законодавства (чл. 2). Посебно се осуђује расна сегрегација и апартејд и захтева од држава да то спрече, забране и укину (чл. 3). Такође државе су преузеле обавезу да прогласе кривичним делом ширење идеја

заснованих на расној мржњи, подстицање на расну дискриминацију, као и сва дела насиља уперена против припадника других раса, друге боје коже или другог етничког порекла (чл. 4). Државе уговорнице имају и обавезу да свим лицима под својом јурисдикцијом обезбеде стварну заштиту, право на жалбу пред националним судовима и осталим државним органима, као и право да траже одговарајућу накнаду за штету проузроковану дискриминацијом (чл. 6). Установљен је и Комитет за укидање расне дискриминације и његова надлежност је одређена самим уговором. Уз ову Конвенцију нису донети посебни протоколи којима би се регулисала надлежност комитета. Комитет се састоји од осамнаест стручњака и према Конвенцији надлежан је да разматра извештаје држава уговорница, међудржавна саопштења и индивидуалне представке (при чему ће последњу надлежност Комитет имати само у односу на државе које дају посебну изјаву у том смислу).

### КОНВЕНЦИЈА О УКИДАЊУ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА

Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена усвојена је 1979. године од стране Генералне скупштине УН, а ступила је на снагу 1981. године. Она је позната и под скраћеним називом *CEDAW*<sup>141</sup>. Конвенција данас има 189 држава уговорница, међу којима је и наша земља. Конвенција је први међународноправни инструмент који на свеобухватан начин штити грађанска, политичка, економска, социјална и културна права жена, па се због тога назива и „Међународни бил о правима жена“. Уз ову Конвенцију 1999. године је усвојен Факултативни протокол, који је ступио на снагу 2000. године. Протокол има 108 уговорница, међу којима је и наша држава.

Конвенција следи приступ Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације и даје дефиницију дискриминације. Она под дискриминацијом жена, у члану 1. подразумева: „свако разликовање, искључивање или ограничење на основу пола, којим се спречава једнако уживање или остваривање људских права и основних слобода на политичком, економском, социјалном, културном, грађанском и другим подручјима живота жена, независно од њиховог брачног статуса.“

---

141 *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.*

Заштита од дискриминације у овом уговору ограничена је на само један основ, а то је пол. Одредба којом се дефинише дискриминација је независна, узевши у обзир да забрањује дискриминацију на „политичком, економском, социјалном, културном, грађанском и другим подручјима.“

Ратификовањем Конвенције, државе се обавезују да предузму низ мера како би окончале сваку врсту дискриминације жена, укључујући: а) уношење принципа једнакости мушкараца и жена у своје правне системе, укидање свих дискриминаторских закона и усвајање одговарајућих закона којима се забрањује дискриминација жена; б) усвајање законских мера, укључујући и санкције, којима се забрањују сви видови дискриминације жена; в) оснивање трибунала и других јавних институција како би се обезбедила ефикасна заштита жена од дискриминације; г) уздржавање од сваког поступка или праксе дискриминације жена и елиминисање свих аката дискриминације против жена од стране лица, организација или предузећа (чл. 2). Од државе се захтева предузимање активности ради измене друштвених и културних обичаја у погледу понашања мушкараца и жена како би се отклониле предрасуде и уобичајена пракса заснована на схватању о инфериорности или супериорности једног или другог пола или традиционалној улози мушкараца, односно жена (чл. 5).

Конвенцијом је створен Комитет за укидање дискриминације жена, чија је једина надлежност према Конвенцији да разматра извештаје које подносе државе уговорнице. Факултативним протоком из 1999. године надлежност Комитета је проширена, тако да он сада прима индивидуалне представке и може покретати истрагу по службеној дужности у случају тешког или систематског кршења права загарантованих Конвенцијом.

Као што се може видети, Комитет и даље нема надлежност да разматра међудржавне представке и по томе се издваја од готово свих других комитета створених уговорима о људским правима донетим под окриљем УН<sup>142</sup>.

## **КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

Међународно право није посвећивало довољно пажње особама са инвалидитетом. Заштита ових особа била је регулисана, углавном, у склопу

---

142 Ову надлежност нема једино још Комитет за права особа са инвалидитетом.

опште заштите људских права, тако да осим Конвенције Међународне организације рада о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица са инвалидитетом из 1983. године, није било ни једног другог међународног уговора посвећеног заштити особа са инвалидитетом. Истина, постојао је већи број докумената тзв. „меког“ права усвојених од стране међународних организација (препоруке, декларације, резолуције, начела), али они нису били правно обавезујући, те је њихова примена зависила од воље држава. Показало се да такав приступ није био добар, јер особе са инвалидитетом често нису биле у могућности да остваре своја људска права и трпела су различите облике дискриминације, нарочито у области образовања, запошљавања и приступа јавним местима. Лоше стање у пракси и чињеница да око 10% укупне светске популације има неки облик инвалидитета, утицало је на УН да приступе изради посебног међународног уговора посвећеног заштити особа са инвалидитетом. Генерална скупштина те организације формирала је 2001. године *ad hoc* комитет за израду нацрта такве конвенције. Комитет је након петогодишњег рада успешно обавио постављени задатак, што је омогућило да Генерална скупштина УН крајем 2006. године усвоји Конвенцију о правима особа са инвалидитетом. Конвенција данас има 168 уговорница, међу којима је и наша држава. Истовремено са Конвенцијом усвојен је и Факултативни протокол, који проширује надлежност Комитета за права особа са инвалидитетом. Протокол има 92 државе уговорнице, међу којима је и Србија.

Особа са инвалидитетом се дефинише као „особа која има дугорочна физичка, ментална, интелектуална или сензорна оштећења, која у садејству са различитим баријерама могу отежати пуно и ефективно учешће те особе у друштву на основу једнакости са другима.“

Дискриминација по основу инвалидности подразумева „свако прављење разлике, искључивање или ограничавање по основу инвалидности чији циљ или последица јесте ограничавање или поништавање признања, уживања или спровођења свих људских права и основних слобода у областима политике, економије, социјалних, културних, грађанских права и било којој другој области. Дискриминација укључује све облике дискриминације, укључујући ускраћивање разумних адаптација“ (чл. 2. ст. 1. т. 3). Како сам текст ове Конвенције дефинише, разумне адаптације јесу „неопходне и одговарајуће модификације и прилагођавања које не представљају несразмеран или непримерен терет, а потребне су у конкретним случајевима како би се особама са



инвалидитетом гарантовало уживање или остваривање свих људских права и основних слобода на једнаким основама“.

Конвенција претежно садржи каталог људских права и слобода, који постоји у и другим међународним уговорима, с тим што су та права доведена у везу и прилагођена потребама и положају лица са инвалидитетом. Конвенцијом су зајемчена сва класична грађанска и политичка права, и то: право на живот, слободу и личну сигурност, право на једнакост пред законом без дискриминације, право на правну и пословну способност, право на поштовање физичког и менталног интегритета, забрана тортуре, забрана експлоатације, насиља и злоупотребе, право на држављанство и слобода кретања, право на живот у заједници, слобода мисли и изражавања, право на поштовање приватности, право на поштовање дома и породичног живота. Када су у питању економска, социјална и културна права, Конвенција посебно гарантује право на образовање, здравствену заштиту, рад и запошљавање, одговарајући животни стандард и социјалну заштиту и учешће у културном и спортском животу, рекреацији и слободним активностима. У Конвенцији се срећу и нека права која су карактеристична само за особе са инвалидитетом, и то: приступ јавним местима и услугама (чл. 9), обезбеђење личне покретљивости (чл. 20) и право на хабилитацију и рехабилитацију (чл. 26).

У Конвенцији су садржане посебне одредбе посвећене заштити жена и деце са инвалидитетом. Овај уговор наглашава да се предузимање посебних мера у циљу постизања и убрзавање *de facto* једнакости особа са инвалидитетом неће сматрати дискриминацијом (тзв. афирмативне мере).

Конвенцијом је установљен Комитет за права особа са инвалидитетом, чија је једина надлежност према том уговору разматрање извештаја држава уговорница о мерама предузетим ради остваривања права признатих Конвенцијом и напретку у уживању тих права. Факултативним протоколом уз Конвенцију Комитету је призната и надлежност да разматра индивидуалне представке и да по службеној дужности спроводи истраге у случају озбиљног или систематског кршења права из Конвенције у одређеној држави. Као и Комитет за укидање дискриминације жена, Комитет за права особа са инвалидитетом нема надлежност да разматра међудржавне представке.

## **ЕВРОПСКИ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ СТАНДАРДИ И НАДЗОР НАД ЊИХОВИМ ПОШТОВАЊЕМ**

За нашу државу веома су важни, поред универзалних стандарда за заштиту од дискриминације и стандарди усвојени од стране две европске регионалне организације, Савета Европе и Европске уније. Као чланица Савета Европе, Република Србија ратификовала је значајан број уговора, који су значајни за заштиту од дискриминације. Наша држава није чланица ЕУ, али је са њом закључила Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и започела преговоре о приступању. Клаузулом о хармонизација садржаној у ССП-у наша држава обавезана је да постепено усклађује домаће право са правом ЕУ, те је од значаја познавати легислативу ЕУ о заштити од дискриминације и праксу Суда правде ЕУ у овом домену.

У оквиру Савета Европе (СЕ) донето је више уговора који су значајни за заштиту од дискриминације. Међу њима треба посебно истаћи Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокол бр. 12 уз Европску конвенцију<sup>143</sup>, Европску повељу о регионалним или мањинским језицима, Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина и (Ревидирану) Европску социјалну повељу.

### **ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА И ПРОТОКОЛ бр.12**

Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода усвојена је 1950. године, а ступила на снагу 1953.године. Данас има 47 држава уговорница, међу којима је и наша држава.

Европска конвенција претежно штити грађанска и политичка права. Између осталог, у чл. 14. прокламује и забрану дискриминације. Из формулације овог члана може се видети да он не садржи неко самостално право, већ је примена ограничена на права која су већ зајемчена Европском конвенцијом или њеним протоколима. Конвенција углавном гарантује грађанска и политичка права, тако да су изван њене заштите остала многобројна економска, социјална и културна права. Листа забрањених основа дискриминације дата у овом члану

---

<sup>143</sup> Нарочито је значајна надзорна улога Европског Суда за људска права устројена Протоколом бр. 12.

није дефинитивна, већ је индикативна јер су у њему наведени неки основи дискриминације (пол, раса, боја коже...), али су они дати егземпларно, уз остављање могућности да то буде „и неки други статус“<sup>144</sup>.

Ступањем на снагу Протокола бр. 12 (2005. године), проширена је забрана дискриминације у односу на сва права, а не само на права призната Европском конвенцијом. Протокол 12, садржи самосталну одредбу о заштити од дискриминације, која се односи на сва права предвиђена националним прописима, а не само на она загарантована Европском конвенцијом о људским правима. Протокол наводи неке конкретне основе, али оставља листу отворену.

Обзиром да чл. 14. Европске конвенције не садржи дефиницију дискриминације, да дефиницију није дао ни Протокол бр. 12, Европски суд за људска права изградио је одређене критеријуме за утврђивање постојања дискриминације, односно да ће дискриминација постојати уколико: 1. постоји различито поступање према особама у истим или битно сличним ситуацијама; и 2. то различито поступање нема објективно и разумно оправдање.

## ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О РЕГИОНАЛНИМ ИЛИ МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Обзиром да Европска Конвенција не обезбеђује посебну заштиту регионалних и мањинских језика, а имајући у виду да забрана дискриминације не пружа довољну заштиту у овом погледу, у оквиру СЕ 1992. године, усвојена је Европска Повеља о регионалним или мањинским језицима, чија је чланица и наша држава. Примарни циљ ове Повеље није заштита мањина, већ очување језичке разноликости, као једног од најважнијих елемената Европске културне баштине.

## ОКВИРНА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Оквирна Конвенција донета је да би се на потпунији начин регулисала мањинска заштита на тлу Европе и то је учињено 1994. године, када је од

---

<sup>144</sup> Европски суд за људска права је као основе дискриминације прихватио и инвалидитет, старосно доба, сексуалну оријентацију, брачни статус, професионални статус

стране Комитета министара СЕ усвојена оквирна Конвенција, чија је чланица и Србија. Ово је први мултилатерални уговор посвећен општој заштити мањина.

## **(РЕВИДИРАНА) ЕВРОПСКА СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА**

Европска социјална Повеља усвојена 1961. године ради регулисања економских и социјалних права, која су остала изван домашаја Европске Конвенције о људским правима. Код овог уговора, као и код његове ревидиране верзије из 1996. године државе имају могућност да бирају која ће права прихватити, тако да обим преузетих обавеза није исти за све уговорнице. Иницијална верзија допуњена је са три протокола и тренутно су на снази обе верзије повеље али се очекује да Ревидирана повеља постепено замени иницијалну верзију из 1961. године. Наша држава је страна уговорница Ревидиране социјалне повеље. У преамбули Европске социјалне повеље истакнуто је да уживање социјалних права треба обезбедити без дискриминације на основу расе, боје коже, пола, вере, политичког мишљења, националне припадности или социјалног порекла. Ревидирана повеља одредбу о забрани дискриминације дислоцира из преамбуле у оперативни део уз значајно побољшање тако да општа забрана дискриминације гласи: „Уживање права предвиђених овом Повељом биће обезбеђено без дискриминације по било ком основу као што је раса, боја коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, здравствено стање, повезаност са националном мањином, рођење или други статус.“ У Ревидираној социјалној повељи садржане су и посебне одредбе које се односе на права разних потенцијалних осетљивих група као што су деца и млади (чл. 7, 17), жене (чл. 8), особе са инвалидитетом (чл. 15), мигранти (чл. 19) и старе особе (чл. 23).

## **АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ СТАНДАРДИ И НАДЗОР У ОКВИРУ ЕУ**

Промоција једнакости и поштовања људских права данас је кључни циљ ЕУ. Принцип једнакости је од самог почетка представљао један од основа те организације и њених претеча. Он је првобитно формулисан и разрађен у сфери полне равноправности. Чл. 119 Римског уговора из 1957. године захтевао је да мушкарци и жене добијају исту зараду за исти рад. Та одредба је спречавала државе чланице да исплаћивањем нижих плата женама остваре конкурентску предност на тржишту. Временом је подручје примене начела

једнакости значајно проширено (пензије, породилска одсуства и обавезно социјално осигурање), али је и даље везивано само за рад и покривало је једино дискриминацију засновану на полу.

На основу чл. 119, Савет европских заједница је средином 70-их година прошлог века донео Директиву о једнакој заради (1975) и Директиву о једнаком третману (1976), која је забрањивала полну дискриминацију приликом запошљавања, професионалне обуке, напредовања и обезбеђивања услова рада. Све до 2000. године антидискриминационо право у ЕУ се и даље примењивало искључиво на подручју запошљавања и социјалног осигурања и штитило само од полне дискриминације.

Тек ступањем на снагу Амстердамског уговора (1999. године), ствара се правни основ за борбу против дискриминације и по другим основима. Дато је овлашћење Комисији, Савету и Европском парламенту да доносе прописе ради борбе против дискриминације засноване на полу, раси или етничком пореклу, вери или убеђењу, инвалидности, старосном добу и сексуалној оријентацији. У складу са тим овлашћењем, поменуте институције ЕУ су извршиле ревизију постојећих директива о родној равноправности и донеле нове директиве које штите од дискриминације по основу неких од нововедених основа.

Лисабонски уговор је начинио значајан искорак у борби против дискриминације. Најпре, он је иновирао ранија правила о заштити од дискриминације садржана у Амстердамском уговору. Поред тога, дао је обавезујући карактер Повељи о основним правима ЕУ, што је значајно допринело проширењу заштите од дискриминације и повећању њене ефикасности.

## **ЗАКЉУЧАК**

Од круцијалне је важности да у сваком правном поретку постоји адекватно устројени механизам заштите осетљивих друштвених група од дискриминације. Иако је достигла одређени степен развика, заштита пружена антидискриминационим актима на унутрашњем и међународном плану увек је дефицитарна, те је неопходно континуирано радити на њеном усавршавању, као и на стварању нових механизма заштите осетљивих група.

**Милица Златковић,**  
судија Апелационог суда у Нишу

**Сања Костић,**  
судија Основног суда у Нишу

## СУДСКА МЕДИЈАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

### *Абстракт*

*Овај рад је посвећен основним карактеристикама, развоју, предностима и примени медијације као једном од алтернативних начина решавања спорова у Републици Србији, а посебно примени медијације у пракси Вишег и Основног суда у Нишу, који су кроз Инфо- службу за подршку алтернативном начину решавања спорова постигли значајне резултате у овој области. Као координатори Инфо службе за алтернативно решавање спорова, аутори овог текста представиће између осталог и рад и организацију саме службе, као и број и врсту успешно решених предмета за врло кратко време свог постојања, а указаћемо и на важност промоције медијације и мерама за њено унапређење, што смо ми учинили између осталог и кроз организацију “Недеље медијације”. Посебно место у овом тексту дато је и правној регулативи, основним карактеристикама и начелима медијације, која омогућавају бројне предности медијације у односу на судски поступак, а као веома значајан сегмент обрађени су и трошкови поступка. Будући да је наша пракса показала да је примена медијације могућа у различитој врсти спорова, да се спорови који су вођени више година окончавају у поступку медијације чак и на једној сесији, да постоји подршка адвоката који су пронашли свој интерес у медијацији и који сами преузимају професију медијатора, као и сарадња судија да предмете упућују на медијацију, циљ овог рада је да укажемо на суштинске предности и недостатке и да прикажемо пример изузетно добре праксе. Како је обраћање редовним судовима већ уобичајена пракса грађана, аутори овог текста сматрају да је промоција, подстицање и поспешивање овог алтернативног начина решавања спорова у интересу не само правосуђа и растерећења судова, већ и друштва у целини и развијању свести о медијацији као филозофији живљења и опхођења, јер је решавање спорова путем медијације ефикасније, јефтиније, друштвено прихватљиво и пожељно понашање.*

## Кључне речи

*Судска медијација, Алтернативни начин решавања спорова, Начела медијације, Закон о посредовању у решавању спорова, Етички кодекс, Правилник о тарифи о накнадама и наградама у поступку посредовања, Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, Упутство за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решавању спорова, Инфо- служба за подршку алтернативном решавању спорова, Протокол о сарадњи у примени посредовања као алтернативног начина решавања спорова.*

## УВОД

Медијација потиче од латинске речи “mediate”<sup>145</sup>, што у преводу значи посредовати.

Претеча данашње медијације, односно посредовања у решавању спорова је тековина најстаријих цивилизација. Први облици посредовања датирају још из Старог века, а исти су током времена модификовани и примењивани су у Кини и Јапану, док се извесни облици медијације јављају и у периоду Хришћанства. Медијација прави смисао добија 80-их година двадесетог века, када почиње да се примењује на систематски и уређени начин и када започиње њена имплементација у судски систем.

Амерички председник Абрахам Линколн је још 1850.г. у свом јавном обраћању истакао велики значај овог алтернативног начина решавања спорова.

“Обесхрабрите парничење. Убедите суседе да постигну компромис кад год је то могуће. Објасните им да је победник на папиру заправо губитник у стварности, имајући у виду све судске трошкове и изгубљено време”<sup>146</sup>

Такође, Декларација независности САД (1776) и Француска Декларација о правима човека и грађанина (1778) поставиле су темељ људских права на америчком и европском континенту. Основне идеје ових Декларација

<sup>145</sup> <https://en.wiktionary.org/wiki/mediate>

<sup>146</sup> <https://www.nytimes.com/1991/07/12/opinion/1-persuade-your-neighbors-to-compromise-218791.html>  
Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser -- in fees, expenses and waste of time.”

допринеле су развоју владавине права и заузеле значајно место, посебно након страдања у Другом светском рату, када се међу европским народима јавила потреба за уједињењем, а у циљу очувања мира. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1949), која се базира управо на идејама америчке и француске Декларације и представља тријумф у заштити људских права и слобода, у чл. 39 регулише појам „пријатељског поравнања“.<sup>147</sup>

„1. У свакој фази поступка Суд се може ставити на располагање странама у спору како би се постигло пријатељско поравнање засновано на поштовању људских права установљених Конвенцијом и протоколима уз њу.

2. Поступак који се води на основу става 1. поверљиве је природе.

3. Ако се постигне пријатељско поравнање Суд скида предмет са своје листе одлуком која садржи кратак опис чињеница и постигнутог решења.

4. Одлука се доставља Комитету министара који надгледа извршење одредаба пријатељског поравнања предвиђених одлуком“<sup>148</sup>

Дакле, кроз историју, са развојем правне и политичке мисли, медијација добила је велики значај и примену у пракси, како на америчком, тако и на европском континенту.

У Србији, медијација, као алтернативни начин решавања спорова и њен развој, представља саставни део Националне стратегије реформе правосуђа и саставни део Преговарачког поглавља 23 за приступ Србије Европској Унији, што указује на чињеницу да је развој медијације од изузетне важности за правосудни систем.

Наше истраживање се односи на развој судске медијације у Србији, са посебним освртом на праксу судова у Нишу, као примерима веома успешне праксе у 2018.г. у Србији.

---

147 Violeta Beširević i dr., *Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda*, Službeni Glasnik, Beograd, 2017, 511.

148 *Ибид* 2



## ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Медијација је уведена у правни систем Србије као последица усаглашавања са европским правним стандардима и испуњења обавеза, које произилазе из потписаних међународних уговора. Основни циљеви увођења медијације у судски систем Србије су мањи број судских предмета, краћа дужина трајања спорова и снижење трошкова поступка, укључивање странака у решавање спорова и повећање поверења грађана у суд, као и укључивање правосудја у савремене токове промена.

Медијација је постојала у Србији у извесном облику и то увиду мировних већа Самоуправних судова, а што је било регулисано одредбом чл. 468 Закона о парничном поступку<sup>149</sup> Сл. Гласник бр.4 /77 од 14.01.1977.г.

По препорукама Комитета министара Савета Европе, доношењем Закона о парничном поступку<sup>150</sup> 2004.г. савремен облик медијације је обуваћен законским оквиром и добио је легитимност. Одредбом чл. 11 наведеног Закона је прописано је да ће суд и странке пре и у току поступка настојати да се грађанскоправни спорови решавају посредовањем или на други миран начин. На овај начин медијација је постала законом предвиђена процедура и њено постојање је обезбеђено у правном систему Републике Србије. Првобитним законским одредбама је предвиђено трајање медијације на 30 дана.

Први Закон који регулише искључиво медијацију јесте Закон о посредовању - медијацији<sup>151</sup>, који је донет 2005.г. Овим Законом медијација је као процедура регулисана на један уопштен начин. Поред прописа који се односе на сам поступак медијације, предвиђени су услови и начин избора медијатора. У чл. 2 наведеног Закона медијација је регулисана као сваки поступак, без обзира на његов назив, у коме стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника-медијатора, који странама помажу да постигну споразум.

Ради унапређења законских решења у Србији је донет нови Закон о посредовању у решавању спорова, који се примењује од 01.01.2015.г.

---

149 Закон о парничном поступку, Сл.гласник РС. 4 /77 од 14.01.1977.г.

150 Закон о парничном поступку, „Сл.гласник РС.“, бр. 125/2004, у даљем тексту ЗПП из 2004. године.

151 Закон о посредовању - медијацији „Сл.гласник РС.“, 18/2005.

Међутим, из примене су тренутно искључене одредбе чл.6. до 8. и чл.. 33. Ст. 5, а које одредбе ће се примењивати од тренутка приступа Републике Србије Европској Унији.

Важећи Закон о посредовању у решавању спорова састављен је од девет делова, а то су уводне одредбе, међународно посредовање и посредовање у прекограничним споровима, начела посредовања, поступак посредовања, однос посредовања и судског или другог поступка, посредник, издавање дозволе за посредовање, обука посредника и прелазне и завршне одредбе.

Наведени Закон настао је као последица неопходности проширења поља примене овог института. Наиме, новим Законом су поред имовинскоправних, трговинских, породичних, радних, грађанскоправних спорова, управних и кривичних ствари у делу који се односе на имовинскоправни захте, као медијабилни спорови предвиђени и потрошачки спорови, спорови из области заштите животне средине и прекршајни спорови, такође у погледу имовинскоправног захтева.

Из наведеног очигледно произилази да је интенција законодавца била проширење примене института медијације, па је новим Законом између осталог у поглављу примене Закона прописано у чл. 3 и “да се одредбе овог Закона не примењују на решавање спорних односа у вези са утврђивањем и наплатом јавних прихода”<sup>152</sup> Такође, Закон предвиђа да уколико неко питање није изричито уређено, у том случају примениће се начела посредовања која су превиђена овим Законом, као и важећи стандарди посредовања садржаних у актима Уједињених нација, Европске Уније и Савета Европе.

Закон такође предвиђа основна начела, која се не разликују од решења из претходног Закона, и то начело добровољности, равноправности, поверљивости, неутралности, хитности, као и искључење јавности. Новину представља и допуштеност употребе доказа у другим поступцима у чл.16.<sup>153</sup>

У погледу самог поступка, поступак се сматра покренутим закључењем споразума о приступању посредовању.<sup>154</sup> Ова одредба је од изузетног значаја имајући у виду да се споразумом регулишу права и обавезе страна, а нарочито сагласне изјаве странака о избору посредника, као и одредба у

---

152 Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр.18 /2005, чл.3.

153 Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр. 18 /2005, чл.16.

154 Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр.18 /2005, чл.18.

погледу трошкова поступка, што је такође од посебне важности у поступку медијације. У Инфо-служби Вишег и Основног суда у Нишу, уз координацију наших сарадника, странке могу вршити избор медијатора и потписати споразум о приступању посредовању. Осим овог формалног дела у погледу споразума за приступање поступку, сам поступак медијације је неформалан.

Стране које су пристале не поступак медијације бирају посредника, односно медијатора, са листе регистрованих медијатора. На сајту Вишег и Основног суда у Нишу објављен је и списак медијатора, са њиховим основним квалификацијама, тако да се странке могу унапред информисати о личности медијатора. Дакле, начело добровољности, које се нарочито односи на садржину самог споразума, дошло је до изражаја и у овом члану Закона, где стране добровољно бирају медијатора. То само не може бити судија који поступа у предмету у коме су стране пристале да покушају да спор реше мирним путем.

Значајна новина се огледа и у погледу рокова који се односе на застарелост, а која превентивно има за циљ да се спречи злоупотреба поступка медијације. Наиме, одредбом чл. 25 је прописано да покретањем поступка посредовања почиње застој застарелости потраживања у односу на захтев поводом кога се спроводи поступак посредовања, који не може трајати дуже од 60 дана. По истеку рока из става 1. овог члана рок застарелости наставља да тече. Ако је законом одређен посебан рок за подношење тужбе, тај рок не тече док поступак посредовања траје, али не дуже од 60 дана.<sup>155</sup> Дакле, странама у поступку је пружена правна заштита од наступања застарелости, што представља значајан напредак у заштити од забране злоупотребе процесних овлашћења.

Такође, једна од најзначајних новина које предвиђа Закон односи се на то да споразум који се постигне у поступку посредовања може имати снагу извршне исправе, ако су претходно испуњени услови прописани у чл. 27 и то да садржи изјаву дужника којом пристаје да поверилац на основу споразума о решавању спора путем посредовања, након доспелости потраживања може покренути поступак принудног извршења (клаузула извршности) и да су потписи страна и посредника оверени од стране суда или јавног бележника.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр. 18 /2005, чл.25.

<sup>156</sup> Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр. 18 /2005, чл.27.

Диспозиција страна у поступку се огледа и у цитираном члану, што значи да споразум може имати снагу извршне исправе само у случају испуњења наведених услова и пристајак дужника.

У сваком случају неће се дозволити принудно извршење споразума о решавању спора путем посредовања ако закључење овог споразума није дозвољено, ако је споразум супротан јавном поретку, ако споразум није подобан за извршење или је предмет извршења немогућ.

Поред наведеног, сматрамо да је од значаја да истакнемо и то да је цитираним Законом прописано да свака странка сноси своје трошкове, а заједничке трошкове, који подразумевају награду за рад посредника и накнаду трошкова које је посредник имао, сnose на једнаке делове, уколико се стране у поступку не споразумеју другачије. Ова одредба упућује на закључак да је законодавац и овде дао примат слободи диспозиције воље страна у поступку и оставио могућност да стране и другачије по сопственој вољи уреде питање трошкова.

Законски прописи који такође регулишу област медијације су: Закон о парничном поступку<sup>157</sup>, Закон о мирном решавању радних спорова<sup>158</sup>, Закон о осигурању<sup>159</sup>, Породични закон<sup>160</sup>, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица<sup>161</sup>, Закон о забрани дискриминације<sup>162</sup>, Закон о стечају<sup>163</sup>, Закон о спречавању злостављања на раду<sup>164</sup>, Закон о заштити потрошача<sup>165</sup>, Закон о споразумном финансијском реструктурирању<sup>166</sup>, Законик о кривичном поступку<sup>167</sup>.

Осим наведеног најзначајнији подзаконски прописи су: Правилник о начину вођења регистра посредника, Правилник о програму основне обуке посредника, Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања

---

157 „Сл.Гласник РС“ бр. 71/2011, 49/2013 –одлука УС, 74/2013 –одлука УС и 55/2014.

158 „Сл.Гласник РС“ бр. 125/2004 и 104/2009.

159 „Сл.Гласник РС“ бр. 55/2004.

160 „Сл.Гласник РС“ бр. 18/2005.

161 „Сл.Гласник РС“ бр. 85/2005.

162 „Сл.Гласник РС“ бр. 22/2009.

163 „Сл.Гласник РС“ бр. 104/2009.

164 „Сл.Гласник РС“ бр. 36/2010.

165 „Сл.Гласник РС“ бр. 62/2014.

166 „Сл.Гласник РС“ бр. 36/2011.

167 „Сл.Гласник РС“ бр. 55/2015.

дозволе за посреднике, Етички кодекс посредника<sup>168</sup>, Правилник о тарифи и наградама и накнадама у поступку посредовања<sup>169</sup> и др.

## БИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Медијација представља интервенцију непристрасне и неутралне треће стране која помаже странама у сукобу да својом вољом постигну обострано прихватљив споразум о предмету сукоба.

Први услов који је неопходан да би се медијација спровела је да стране у сукобу бирају медијатора, који мора бити непристрасан, што значи да не даје предност ни једној страни и неутралан, што подразумева да медијатор нема никакав интерес у вези предмета спора. Поред тога, основне карактеристике медијатора су и поверљивост, аналитичност, објективност и емпатичност. Без ауторитативне моћи доношења одлуке, медијатор искључиво охрабрује и помаже странама у спору да постигну заједничко прихватљиво решење у обостраном интересу, уважавајући потребе обе стране у поступку.

У поступку медијације нема поражених, стране у сукобу свакако не треба да поставе победу за циљ и нема пресуђења. Дакле, смисао овог поступка није утврђење ко је у праву, већ је циљ споразум који је у интересу у обе стране, али не и супротан јавном интересу и моралу.

Стране могу да пристану на медијацију у свакој фази поступка, па чак и у жалбеном и извршном поступку. Уколико до споразума не дође, наставља се судски поступак, без икаквих последица по стране у спору.

Поред ограниченог трајања, што подразумева и велику уштеду трошкова, што је детаљније образложено у наредним поглављима, у интересу страна је и могућност да кроз један поступак медијације реше и више спорова, што доприноси отклањању неспоразума и изградњи међуљудских односа, а са друге стране представља и велику релаксацију за буџет.

---

168 *Сл.Гласник РС* “ бр. 146/2014.

169 *Сл.Гласник РС* “ бр. 35/1015.

## ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПРЕДНОСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ

Основна начела медијације су: добровољност, равноправност, учествовање и присуствовање у поступку посредовања, искључење јавности, поверљивост, неутралност и хитност.

За разлику од судског поступка који за странке, а пре свега тужену страну, представља принудни поступак, поступак медијације је потпуно добровољан, заснован у потпуности на диспозицији страна. Сам поступак је потпуно флексибилан и комфоран за стране, управо супротно судском поступку који је не само строго формалан, већ често и веома непријатан за странке.

Једно од посебно значајних начела поступка медијације је *поверљивост самог поступка*, што представља велику предност у односу на судски поступак који је јаван, а што учесницима у поступку улива непроцењиву сигурност да подаци и чињенице изнети у поступку медијације остају практично тајна између учесника и медијатора. Примена овог начела за странке има посебни значај, нарочито у веома деликатним парничним поступцима који се тичу стицања у брачној или породичној заједници, где су углавном лични и породични односи између страна изузетно поремећени и где свакако свака страна има основни интерес да све чињенице и подаци остану поверљиви. У том смислу, стране, њихови законски заступници и пуномоћници, као и сам посредник или трећа лица која присуствују поступку посредовања, односно лица која обављају административне послове за потребе посредовања, дужни су да све податке, предлоге и изјаве у вези са поступком посредовања чувају као тајну и одговарају за штету насталу кршењем ове обавезе. Такође, предлози изнети током посредовања који су дати искључиво ради закључења споразума, не могу се користити у судском, арбитражном или другом поступку, нити саопштити на други начин.

*Начело равноправности странака*, те инсистирање законодавца на личном учешћу странака као физичких лица у поступку, говори у прилог чињеници колико је овај поступак, у сваком погледу заснован на овлашћењима странака да га заправо саме воде и уређују, у складу са својим најбољим интересима, што је у поређењу са веома крутим и формалним судским поступком, велика предност.

Наиме, судски поступак води судија, поштујући веома строга и увек веома формална правила прописана процесним законом, док поступак медијације заправо воде саме стране, уз помоћ медијатора. Улога медијатора није да странама намеће било каква решења, па чак ни даје конкретне предлоге, већ је његова једина улога да стране наведе да саме, споразумно и на обострану корист дођу до заједничког решења, у чему се огледа основни смисао *начела неутралности*. У смислу наведеног, док се судски поступак готово увек окончава решењем прихватљивим само за једну страну, поступак медијације се окончава решењем које је не само прихватљиво за обе стране, већ у њиховом најбољем заједничком интересу, а што свакако има изузетно позитиван утицај на уопштене односе страна.

Имајући у виду управо наведено, једна од главних предности поступка медијације је и његова свеобухватност, јер се медијацијом не решава само конкретно спорно правно питање између страна, већ срегулишу И међусобни, лични односи страна у спору, услед чије нарушености као последица углавном и настају судски спорови, те се поступком медијације заправо постиже двоструко дејство: решава се конкретан спор, али се и лични односи између страна знатно побољшавају, а некада чак и у потпуности изгледе. Насупрот томе, у судском поступку, правило је да у највећем броју спорова успева само једна странка са својим захтевом, док лични односи између странака остају и даље веома нарушени и чини се све гори, а посебно имајући у виду извршни поступак као завршну фазу судског поступка, који свакако због саме своје природе представља изузетно принудни поступак и самим тим са собом носи велике непријатности.

## ТРОШКОВИ И ХИТНОСТ ПОСТУПКА

Имајући у виду да се медијација може водити пре покретања судског поступка (вансудска медијација), у току судског поступка (судски анексирана медијација) и у току жалбеног поступка, оно што је свакако једна од најзначајнијих предности, независно од врсте медијације, јесу трошкови поступка. Наиме, медијација је у односу на судски поступак изузетно економичан и јефтин поступак. *Правилником о тарифи о накнадама и наградама у поступку посредовања*<sup>170</sup>, (у даље тексту: „Правилник“),

<sup>170</sup> “Sl. Glasnik RS”, br. 35/2015.

утврђена је висина награде за рад и висина накнаде трошкова посредника. У смислу наведеног, одредбом чл. 4 наведеног Правилника обрачуната је награда по одржаном посредничком састанку према вредности спора, док је одредбом чл. 5 регулисана висина награде у непроцењивим предметима.

Како је одредбом чл. 3 Правилника прописано да вредност поена износи 100 динара, то значи да награда за вредност спора од 1 до 100.000 динара, износи 7.500 динара.

*Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката*<sup>171</sup>, тарифним бројем 13, чији се преглед у новчаним апоенима може видети у доњој табели, прописано је, за спорове чија вредност износи до 450.000 динара, трошкови писање поднеска од стране адвоката износе 6.000 динара, док заступање на једном одржаном рочишту износи 7.500 динара.

Простом анализом датих вредности, долази се до закључка, да само један излазак пуномоћника из редова адвоката на рочиште у предмету чија је вредност 100.000 динара, износи онолико, колико би коштао читав поступак медијације. Имајући при томе у виду да странке сnose трошкове медијације на једнаке делове, то значи да би поступак медијације странку коштао заправо 3.500 динара.

Према подацима Министарства правде<sup>172</sup>, објављеним на званичном сајту, медијација је у поређењу са редовним трошковима судског поступка, у зависности од висине вредности спора, јефтинија од 35% до 60%, што је свакако значајна уштеда трошкова.

Осим уштеде у новцу, свакако није занемарљива ни уштеда времена трајања самог поступка. Опште је позната чињеница да судски поступци неретко трају и више година, док се поступак медијације углавном успешно реши на само једном одржаном састанку.

Како у конкретном случају говоримо о судској медијацији, сам поступак трајања је лимитиран и самим *Законом о посредовању у решавању спорова*<sup>173</sup>, чијом је одредбом чл. 24 ст. 1 тач.4 прописано да се поступак посредовања окончава протеком рока од 60 дана од дана закључења споразума о

---

171 "Sl. Glasnik RS", br. 121/2012.

172 <https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/15868/medijacija.php>

173 "Сл. Гласник РС", бр. 55/2014.



приступању посредовању, осим уколико се стране не споразумеју другачије, што значи да је рок од 60 дана, на колико је такође одређен и застој поступка, сходно одредби чл. 18 ст. 3 истог Закона, заправо рок у коме се поступак посредовања мора спровести.

## ПРИМЕНА МЕДИЈАЦИЈЕ У ПРАКСИ

Судска медијација у Србији је званично уведена 2002.године, када је Врховни суд Србије, кроз пилот пројекат, организовао „Недељу поравнања“, у оквиру које су се разматрали парнични предмети старији од три године. У пројекту је учествовало 138 судова, а медијатори су били пензионисане судије углавном Врховног суда. Према статистичким показатељима, у овој недељи медијацијом је решено 14,5% предмета, а као главни проблеми дефинисани су пре свега недовољна информисаност грађана, незаинтересованост судија, отпор адвоката, али и недостатак законске регулативе.

Ради отклањања уочених сметњи за примену медијације, убрзо је отпочето са радом на доношењу закона и 2005.године донет је Закон о посредовању – медијацији<sup>174</sup>, који је био на снази до 31.12.2014.г.Како за време важења овог закона, нису постигнути значајнији резултати, донет је нови Закон о посредовању у решавању спорова, који је још увек је у примени.

У смислу боље практичне имплементације Закона, дана 28.06.2017. године, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства и министар правде Републике Србије, донели су *Упутство за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решавању спорова*<sup>175</sup>, (у даљем тексту: „Упутство”), а ради подстицања предузимања системских мера од стране судова у циљу подршке овом алтернативном начину решавања спорова.

Као једна од мера предвиђених Упутством је оснивање Инфо-службе за подршку алтернативним начинима решавања спорова. Наиме, предвиђено је да сви Основни, Виши и Привредни судови требају основати Инфо-службу за подршку алтернативним начинима решавања спорова у оквиру суда (у даљем тексту: „Инфо-служба”), ради пружања обавештења о могућности

174 “Сл. Гласник РС”, бр. 18/2005.

175 [https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0\\_0\\_0.pdf](https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_0_0.pdf)

и поступку алтернативног решавања спорова. Такође, прописано је и да ће годишњим распоредом послова, председник суда одредити судију који ће да руководи Инфо-службом и судијске помоћнике који ће обављати послове у оквиру Инфо службе.

Посебан део у Упутству посвећен је промоцији и обуци судија и председника судова, што је према мишљењу аутора, а на основу непосредног искуства у примени овог Упутства, од посебног значаја, а сходно утиску да је недовољна информисаност не само обичне, већ и стручне јавности, о предностима решавања спорова алтернативним методама.

### **Инфо-служба за подршку алтернативном решавању спорова Вишег и Основног суда у Нишу**

Убрзо после доношења напред наведеног Упутства, у Вишем и Основном суду у Нишу, формирана је Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова и од стране председника суда одређени координатори службе, који су и аутори овог рада.

Након перманентне медијске кампање и информисања јавности о постојању Инфо- службе, али и основним предностима медијације као алтернативног начина решавања спорова, те одржавања састанака са судијама парничног одељења оба суда и представницима Адвокатске коморе града Ниша, Инфо-служба је званично почела са радом у јануару 2018.године. Поступајуће судије у првостепеним поступцима, су сходно сопственим проценама о медијабилности предмета, исте упућивале у Инфо-службу, где су странке добијале сва даља обавештења како о самом поступку. Након потписивања Споразума о приступању посредовању у писаној форми и избора посредника, поступајући судија је у судском предмету решењем одређивао застој поступка до 60 дана, у ком року је предмет морао бити или окончан договором или враћен судији на даљи поступак.

У циљу промоције и унапређења поступка медијације, Виши и Основни суд су дана 18.01.2018.године и 25.09.2018.г. закључили Протоколе о сарадњи у примени посредовања као алтернативног начина решавања спорова, са градским комуналним предузећима ЈКП Обједињена наплата и ЈКП Горица, а са циљем решавања спорова које комунално предузеће већ води пред

Основним судом против својих корисника услуга, ван рочишта за главну расправу и избегавања трошкова парничног поступка.

Према анализи направљеној за шест месеци рада Инфо службе, од разматраних 88 предмета, медијацијом је успешно решен 31 предмет, међу којима је било предмета брачне тековине, стицања у породичној заједници и накнаде штета, изузетно комплексних парница. Такође, на само једној сесији, успешно је решен предмет у коме је парнични поступак трајао пуних 9 година, а први пут је од почетка примене медијације у правном систему Републике Србије, овом методом решен предмет у фази жалбеног поступка. О наведеном, могу се пронаћи званична саопштења на веб страници Вишег суда у Нишу<sup>176</sup>

Према званичним испитивањима Министарства правде и Врховног касационог суда Србије, у овом тренутку Виши и Основни суд у Нишу су практично једини судови у Републици Србији који са знатном успешношћу примењују судску медијацију.

Како на жалост оваква пракса за сада није заживела и у осталим судовима у држави, примери Вишег и Основног суда у Нишу, свакако указују на изузетну успешност примене медијације као алтернативног начина решавања спорова, пре свега у погледу старих предмета, а све у циљу растерећења судова у што већој мери, што је у коначном и стратешко опредељење наше државе, предвиђено стратешком смерницом 5.3.1. Националне стратегије реформе правосуђа<sup>177</sup>, али и активностима број 1.3.6.29. Акционог плана за поглавље 23<sup>178</sup>.

Такође, досадашња пракса Инфо-службе, показала је да је медијација могућа и у другостепеном поступку, што је од посебне важности, имајући у виду енормну оптерећеност другостепених судова, те све чешће повреде права на суђење у разумном року.

За ово кратко време постојања и рада Инфо-службе судова у Нишу, евидентирани су и неки од основних проблема који, према мишљењу аутора, имају пресудан утицај за бољу и ширу примену медијације. Пре свега неопходна је хитна измена Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и Председника судова,

176 <http://www.ni.vi.sud.rs/>

177 <https://www.mpravde.gov.rs/files/Nacionalna-Strategija-reforme-pravosudja-za-period-2013.-2018.-godine.pdf>

178 <https://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023.pdf>

чијим је чланом 17 ставом 6, предвиђено да се два предмета окончана закључењем споразума о решавању спора посредовањем, рачунају као један мериторно решен предмет, што се свакако негативно одражава пре свега на заинтересованост самих судија за активно учешће у поступку медијације и упућивање предмета. Такође, неопходна је и хитна измена Закона о судским таксама, којим би странке које успеју у медијацији биле ослобођене од плаћања судских такси. Како је напред већ поменуто, потребно је посебну пажњу посветити промоцији медијације као алтернативне методе и то је потребно учинити системски од стране државе, која би морала да организује веома озбиљну промотивну кампању и то не само у области информисању јавног мњења о бенефитима алтернативних метода решавања спорова, већ и организовања стручних обука и усавршавања судија и судског особља, пре свега на тему медијабилности предмета. Посебна пажња, морала би бити усмерена на адвокатске коморе, будући да без апсолутне сарадње адвоката, поступак медијације није могућ, а према непосредним сазнањима аутора, за све време рада Инфо службе, као ни у периоду пре тога, није спроведена готово никаква едукација адвоката на ову тему.

## **ЗАКЉУЧАК**

Суштинска разлика између класичног судског поступка и алтернативног начина решавања спорова огледа се у начелу аутономије воље, односно начелу добровољности, који је карактеристичан управо за алтернативни начин решавања спорова.

Медијација је најчешће примењиван метод алтернативног начина решавања спорова у Сједињеним Америчким државама и Европи и подразумева да странке решавају спор у неформалном поступку уз помоћ треће неутралне особе, односно лиценцираног медијатора, који им помаже у превазилажењу проблема и закључењу споразума у заједничком интересу страна.

У медијацији супротстављене стране добијају win-win исход, што значи да у овом поступку не постоји страна која губи, већ су сви на добитку, а стране могу унапред решити и више спорова пред судом и коначно и унапредити своје нарушене односе, без доношења судске пресуде, уз велику уштеду трошкова и у кратком временском периоду.

У Републици Србији медијација је регулисана Законом о посредовању у решавању спорова и донето је седам подзаконских аката. Досадашња пракса у примени медијације је показала да је брже, ефикасније, хуманије и јефтиније решавање проблема уз унапређење односа у сваком случају од вишеструке користи за грађане од формалног судског поступка.

Ипак, чињеница је да је Инфо служба за подршку алтернативном начину решавања спорова Вишег и Основног суда у Нишу остварила неупоредиво боље резултате у односу на друге судове у земљи, а што је допринело и растрећењу у раду, имајући у виду велику оптерећеност судова. Успех је остварен кроз стручну и ефикасну организацију унутар службе, отвореност и сарадњу са колегама судијама, адвокатима и медијаторима, закључењу Протокола са комуналним предузећем, организовању Недеље медијације, преговорима са јавним предузећима који имају велики број поступка пред судом у циљу закључења нових Протокола о сарадњи, као и перманентном промоцијом медијације, истицањем њених предности и важности путем медија од стране координатора ове службе, односно аутора овог текста.

На крају, осим тога што сматрамо да је неопходно извршити корекцију Закон о судским таксама и Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и Председника судова, рад на унапређењу медијације подразумева и едукације за судије, адвокате, едукације у циљу подизања свести грађана, као и организовање обука за медијаторе. Такође, указујемо на чињеницу да је развој медијације од великог значаја не само за правосуђе, већ и за друштво у целини и да судови кроз оснивање Инфо служби за подршку алтернативном начину решавања спорова треба да допринесу развоју медијације, јер се њеном применом растеређује судски апарат и буџет грађана, а грађанима се омогућава право на приступ правди.

## РЕФЕРЕНЦЕ

- Виолета Беширевић и др., „Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода”, Службени Гласник, Београд, 2017, 511
- Закон о парничном поступку, „Сл.гласник РС“ бр.4 /77 од 14.01.1977.г.
- Закон о парничном поступку, „Сл.гласник РС.“, бр. 125/2004, у даљем тексту ЗПП из 2004. године.
- Закон о посредовању -медијацији „Сл.гласник РС.“, 18 /2005.
- Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр.18 /2005, чл.3.
- Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр. 18 /2005, чл.16.
- Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр.18 /2005, чл.18.
- Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр. 18 /2005, чл.25.
- Закон о посредовању у решавању спорова „Сл.гласник РС.“, бр. 18 /2005, чл.27.

- "Сл.Гласник РС" бр. 71/2011, 49/2013 –одлука УС, 74/2013 –одлука УС и 55/2014.
- "Сл.Гласник РС" бр. 125/2004 и 104/2009.
- "Сл.Гласник РС" бр. 55/2004.
- "Сл.Гласник РС" бр. 18/2005.
- "Сл. Гласник РС", бр. 35/2015.
- "Сл. Гласник РС", бр. 121/2012.
- "Сл. Гласник РС", бр. 55/2014.
- "Сл. Гласник РС", бр. 18/2005.
- <https://en.wiktionary.org/wiki/mediate>
- <https://www.nytimes.com/1991/07/12/opinion/1-persuade-your-neighbors-to-compromise-218791.html> "Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser -- in fees, expenses and waste of time."
- [https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0\\_0\\_0.pdf](https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_0_0.pdf)
- <https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/15868/medijacija.php>
- <http://www.belami.rs/sporovi-gradana-i-objedinjene-naplate-resavace-se-medijacijom/>
- <http://www.ni.vi.sud.rs/>
- <https://www.mpravde.gov.rs/files/Nacionalna-Strategija-reforme-pravosudja-za-period-2013.-2018.-godine.pdf>
- <https://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023.pdf>

## JUDICIAL MEDIATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA

### *Abstract*

This paper is devoted to the basic characteristics, development, advantages and application of mediation as one of the alternative methods of resolving disputes in the Republic of Serbia, with special emphasis on the application of mediation in the practice of the Higher and Basic Court in Nis, which through the Info Service for Supporting Alternative Dispute Resolution reached significant results in this area. As coordinators of the Info Service for Alternative Dispute Resolution, the authors of this text will present, among other things, the work and organization of the service itself, as well as the number and type of successfully resolved cases for a very short period of existence, and we will also point out the importance of promotion of mediation and measures for its improvement, what we did, among other things, through the organization of the “Mediation Week”. A special place in this text is given to the legal regulations, basic characteristics and principles of mediation, which provide numerous advantages of mediation in relation to the court proceedings, and as a very significant segment, the costs of the procedure are processed. Since our practice has shown that the application of mediation is possible in a different type of disputes, that disputes that have been guided over several years finished in the mediation process even in one session, that there is huge support from lawyers who have finally found their interest in mediation, as well as the cooperation of judges, the aim of this paper is to point out the essential advantages and disadvantages and to present an example of extremely good practice. As the citizens have common practice to address their problems to the court, the authors of this text believe that the promotion, encouragement and promotion of this alternative way of resolving disputes is in the interests of not only the judiciary, but also society as a whole and the development of awareness of mediation as a philosophy of life and behavior, because solving disputes through mediation is more efficient, cheaper, socially acceptable and desirable behavior.

### **KEY WORDS:**

Judicial mediation, Alternative dispute resolution, Mediation principles, Dispute mediation law, Code of Ethics, Code of Regulations on fees and rewards in the mediation procedure, Tariff on rewards and reimbursements for the work of lawyers, Instruction for improvement of mediation in the Republic of Serbia The Law on Mediation in Dispute Resolution, the Info-Service for Supporting Alternative Dispute Resolution, the Protocol on Cooperation in the Application of Mediation as an Alternative Dispute Resolution.

Тијана Митровић,

судијски сарадник Апелационог суда у Нишу

## О ПРИМЕНИ РАСПРАВНОГ НАЧЕЛА И ПРАВИЛА О ТЕРЕТУ ДОКАЗИВАЊА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

### *Анстракт:*

*У раду је извршена анализа права и обавеза странака и дужности суда, у поступку утврђивања чињеничне подлоге судске одлуке. Прво поглавље посвећено је анализи нормативног оквира расправног начела у парничном поступку, које се односи на дужност странака да активно учествују у прикупљању и предлагању доказног материјала, уз истовремено указивање на изузетке од прихваћеног правила, у којима суд примењује истражно начело. Затим је указано на одговорност странака за формирање чињеничне основе пресуде, иницијативу суда у подстицању и усмеравању странака да предложе доказе за утврђивање чињеница које представљају основ за доношење пресуде и кроз његову дужност да утврди чињенице како би спречио недозвољена располагања странака. Предмет расправљања је била и анализа правила о терету доказивања у парничном поступку, при чему је најпре указано на разлике између субјективног и објективног правила о терету доказивања, које произилазе из општих правила о терету доказивања, како бисмо одговорили на питања: ко је носилац терета доказивања, када се поставља питање о терету доказивања и који је садржај правила у терету доказивања. У последњем одељку указано је на значај припремног рочишта у поступку доказивања и на дужности странака и суда у погледу изношења и прикупљања чињеничног материјала, док је у закључку указано на тешкоће које се јављају у практичној примени правила о терету доказивања.*

**Кључне речи:** *одлучне чињенице, примена материјалног права, слободна оцена доказа, терет доказивања, припремно рочиште.*



## 1. Примена расправног начела у парничном поступку

Доношењем новог Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС и 55/14) доследно је афирмисана примена расправног начела у парничном поступку и напуштен је дотадашњи концепт примене истражног начела и утврђивања материјалне истине од стране суда који је могао по службеној дужности да прикупља и изводи доказе, па и оне које странке нису предложиле. Неактивност странака у предлагању доказа је по, старом закону, толерисана од стране суда, што је негативно утицало на трајање поступка.

За разлику од тадашњих решења, сада је расправно начело правило приликом утврђивања чињеничне подлоге пресуде. У том смислу је и прописано правило из члана 7. ЗПП да су странке дужне да изнесу све чињенице на којима заснивају своје захтеве и да предложе доказе којима се утврђују те чињенице (став 1). Суд ће да размотри и утврди само чињенице које су странке изнеле и да изведе само доказе које су странке предложиле, ако законом није другачије прописано (став 2). Суд је овлашћен да утврди и чињенице које странке нису изнеле и изведе доказе које странке нису предложиле, ако из резултата расправљања и доказивања произилази да странке располажу захтевима којима не могу да располажу (став 3). У циљу доследног спровођења расправног начела, како би се његовом применом допринело остваривању начела ефикасности и економичности поступка, законом су странкама наметнута одређена ограничења како би се појачала њихова процесна дисциплина и спречило одлуговлачење поступка. То се, пре свега, односи на фазу поступка у којој је дозвољено истицање нових чињеница и предлагање доказа и на прописивање правила везаних за примену правила о терету доказивања чињеница, како у случају истицања нових чињеница, тако и у случају истицања процесно-правних и материјално-правних приговора.

У границама важења расправног начела, суд има одређену улогу приликом прикупљања чињеничног и доказног материјала и у димензионирању чињеничне подлоге, иако од странке искључиво зависи које ће чињенице изнети и које ће доказе предложити. Суд је овлашћен и дужан да чињенични супстрат, као подлогу за одлуку, образује само од чињеница које су странке изнеле и о којима су странке имале могућност да расправљају у току поступка.<sup>179</sup> Међутим, суд је у обавези да

<sup>179</sup> Г. Станковић, *Грађанско процесно право*, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010, стр. 222.

процесне претпоставке испитује по службеној дужности, независно од чињеница на које се странке позивају. По службеној дужности се одвија и примена права и сазнавање правних норми. Једно од најважнијих ограничења расправног начела је овлашћење суда из члана 313. ЗПП којим је наглашена дужност суда да се постављањем питања стара да се у току расправе пружи потребна објашњења, у циљу утврђивања чињеница од којих зависи одлука о основаности тужбеног захтева. У том смислу и суд и парнични противник могу тражити објашњења о појединим чињеничним наводима, а све у смислу чл. 7. ст. 2. ЗПП.

Дакле, суду је дата могућност да, изузетно, одреди извођење доказа по службеној дужности, ради утврђивања чињеница које су битне за одлуку о тужбеном захтеву, када је то прописано законом.<sup>180</sup>

На основу наведеног, може се рећи да истражно начело и даље постоји, али је сведено на минимум и примењује се у случају спречавања злоупотребе права када је на суду да применом материјалног права утврди да су у питању захтеви којима странке не могу да располажу. У том смислу је и одредба чл. 3. ст. 3. ЗПП којом је прописано да је суд овлашћен да утврди и чињенице које странке нису изнеле и изведе доказе које странке нису предложили, ако из резултата расправљања и доказивања произилази да странке располажу захтевима којима не могу да располажу. У другим случајевима, суд је у обавези да примењује истражно начело када су му та овлашћења дата посебним прописом, као што је то случај када су у питању поступци из породичноправних односа.

## 2. Одлучне чињенице и доказивање

Најважнији део парничног поступка свакако представља доказивање, које се спроводи како би се утврдиле све одлучне чињенице које утичу на доношење одлуке и које се називају одлучним или битним чињеницама, па у поступку треба изводити само оне доказе од чијег постојања односно непостојања зависи исход спора. Превасходна одговорност за формирање чињеничне основе пресуде лежи на парничним странкама. Странке су дужне да изнесу чињенице и предложе доказе на којима заснивају свој захтев или којим оспоравају наводе и доказе противника, у складу са овим законом (члан 228. ЗПП). Дакле, иницијатива за доказивање, сходно наведеном члану, мора да потекне од странке, обзиром да суд формира чињеничну подлогу која ће бити основа за доношење пресуде на

---

<sup>180</sup> Н. Петрушић, Д. Симоновић, *Коментар Закона о парничном поступку*, стр. 587.

основу доказа које су странке предложили, док се иницијатива суда огледа у подстицању и усмеравању странака да предложе доказе за утврђивање чињеница које представљају основ за доношење пресуде и кроз његову дужност да утврди чињенице како би спречио недозвољена располагања странака у смислу чл. 3. ст. 3. ЗПП и када је на то овлашћен посебним прописима.

Да би суд стекао уверење о томе које доказе треба извести потребно је да судија у фази када добије одговор на тужбу, или када странке дају изјаву на првом рочишту ако није поднет одговор на тужбу, изврши анализу правне природе спорног односа, да би након тога проценио које су одлучне чињенице од којих зависи исход спора и које су од тих чињеница спорне а које неспорне. Након утврђивања које су одлучне чињенице спорне, судија одлучује који ће докази бити изведени.<sup>181</sup>

## 2. 1. Структура чињеничне подлоге

На основу изнесених чињеница суд формира подлогу за доношење пресуде у коју улазе само оне чињенице које су значајне за решење спора, а то су оне чињенице за које суд сматра да су правнорелевантне.

У чињеничну подлогу пресуде улазе чињенице о којима суд води рачуна по службеној дужности, неспорне чињенице на којима странке заснивају своје захтеве, као и спорне чињенице чија се истинитост проверава путем доказивања. Када су у питању чињенице о којима суд мора да води рачуна по службеној дужности, он ће их проверити без обзира на то да ли су оне неспорне или спорне међу странкама.

Чињенице које улазе у ту групу су правно-релевантне мериторне чињенице (чињенице на којима се заснивају грађанскоправни односи или грађанска субјективна права, а којима њихови титулари не могу слободно располагати); чињенице од којих зависи примена процесног права и чињенице од којих зависе услови и допуштеност пружања судске заштите.<sup>182</sup>

Иако иницијатива за прикупљање процесне грађе на основу које суд треба да донесе одлуку сада обликују искључиво странке, уз изузетке који су предвиђени законом, суд је задржао право да одлучује о релевантности понуђених доказа за утврђивање чињеничног стања. Због сложености проблематике која се односи

<sup>181</sup> С. Сворцан, *Коментар Закона о парничном поступку*, Институт за правне и друштвене науке Правног факултета у Крагујевцу, 2012, стр. 554.

<sup>182</sup> Г. Станковић, *Грађанско процесно право*, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010, стр. 411.

на правилну примену правила о терету доказивања у теорији је извршена категоризација чињеница у четири групе и то на чињенице за које се веже настанак одређеног права; чињенице које преображавају одређено право; чињенице које гасе одређено право и чињенице које спречавају настанак одређеног права. Међутим, проблем може настати онда када је спорно да ли је постојање чињенице услов за настанак одређеног права или непостојање такве чињенице спречава настанак тог права. Од тога како се таква чињеница квалификује, зависиће и одговор на којој од странака лежи терет доказивања.<sup>183</sup>

## 2.2. Предмет доказивања

Приликом формирања чињеничне основе за доношење пресуде, суд мора да провери истинитост твђења странака о одређеним чињеницама, при чему није у обавези да као основу за одлуку узме све чињенице које су странке навеле. Доказивање обухвата све чињенице које су важне за доношење одлуке (члан 229. ст. 1.ЗПП).

Суд није везан за правни основ тужбеног захтева али је зато везан за чињенице на којима је тужилац засновао захтев. Суд тужиоцу може да пружи правну заштиту у оквиру постављеног тужбеног захтева само у оном обиму у коме то, с обзиром на чињеничне наводе (исти животни догађај), омогућују прописи материјалног права. Везаност суда за животни догађај произилази из члана 192. става 1. ЗПП по коме, између осталог, тужба треба да осим захтева садржи и „чињенице на којима тужилац заснива захтев.“<sup>184</sup>

Предмет доказивања су пре свега правнорелевантне чињенице, за које правна норма коју треба применити везује одређене правне последице. Суд одлучује који ће се докази извести ради утврђивања битних чињеница (члан 229. ст. 2. ЗПП) Које ће чињенице бити правнорелевантне у конкретном случају зависи од тога како је суд квалификовао спорну ствар као и од природе спорног правног односа, па се након утврђивања истих, путем доказивања проверава њихова истинитост.

<sup>183</sup> С. Бркић, *Терет доказивања у кривичном и парничном поступку*, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2012, стр. 316.

<sup>184</sup> „Те чињенице су у конкретном случају (а што не спори тужилац ни у ревизији, на то сам указујући) да уговорену количину робе тужилац није испоручио првотуженом по закљученом уговору, него да је без налога првотуженог исту испоручио друготуженом у доцњи и робом неодговарајућег квалитета. За те животне чињенице суд је везан, па другостепени суд правилно закључује да нема правног основа за обавезивање првотуженог (над друготуженим је закључен стечајни поступак) на повраћај предметне робе у смислу чл. 132. ст. 2. у вези чл. 125. ст. 1. Закона о облигационим односима.“ Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 23/99 од 25.10.2000. године.

Предмет доказивања не могу бити признате чињенице, ноторне чињенице и чињенице утврђене пресудом кривичног суда.

Не доказују се чињенице које је странка признала пред судом у току парнице, односно чињенице које није оспорила (члан 230. ст. 1). Дакле, правило је да се у поступку доказују само спорне правно релевантне чињенице, док неспорне чињенице не могу бити предмет доказивања.

Ово је примена принципа афирмативне литисконтестације, по којој се неоспоревање чињенице сматра њиховим прећутним признањем, који принцип је у основи пресуде због пропуштања. Страка, дакле, има задатак да се јасно изјасни о томе које чињенице противника оспорава, па ће неактивност странке у том смислу имати за последицу да ће се чињенице које она није оспорила узети као признате, а ћутање странке се не може изједначавати са оспоравањем.<sup>185</sup>

Суд има могућност да одлучи да се доказују и признате чињенице како би спречио недозвољена располагања странака, па је у том смислу и одредба чл. 230. ст. 2. ЗПП којом је прописано да суд може да одлучи да се доказују и признате чињенице ако сматра да странка њиховим признањем иде за тим да располаже захтевом којим не може располагати (члан 3. ст.3). Према одредби чл. 3. ст. 3. ЗПП, суд неће дозволити располагања странака која су у супротности са принудним прописима, јавним поретком, правилима морала и добрим обичајима.<sup>186</sup>

У ситуацији када странка најпре изричито призна једну чињеницу, а након тога потпуно или делимично оспори признање те чињенице, долази до сложене процесне ситуације за суд у погледу третирања такве чињенице. Одредбом чл. 230. ст. 3. ЗПП је прописано да ће суд, узимајући у обзир све околности, да оцени да ли ће да узме за признату или оспорену чињеницу коју је странка најпре признала, а после потпуно или делимично оспорила, или ограничила признање додавањем других чињеница. У таквој ситуацији потребно је да суд затражи да странка пружи разлоге за такво поступање, а од датих разлога зависиће и одлука суда о томе да ли ће ту чињеницу узети за признату или оспорену.

<sup>185</sup> Н. Бодирога, *Нови закон о парничном поступку*, Правни факултет Универзитета у Београду, 2012, стр. 161.

<sup>186</sup> На овом месту ћемо указати на потребу разликовања између признања чињеница из напред наведеног члана и признања тужбеног захтева, будући да признањем једне чињенице она постаје неспорна чиме се отклања потреба за њеним доказивањем, док признање тужбеног захтева представља диспозитивну парничну радњу и може довести до доношења пресуде на основу признања, уколико су испуњени законом прописани услови.

Не треба изводити доказе у вези са чињеницама које су општепознате (члан 230. ст. 4. ЗПП), при чему се са општепознатим чињеницама више не изједначавају чињенице које је суд сазнао у вршењу судијске функције. То не би било у складу са принципом по којем суд не може да донесе одлуку о чињеницама о којима странкама није била пружена прилика да се изјасне, али ни у складу са принципом отвореног правосуђа ни са чланом 6. ЕКЈП.<sup>187</sup> Допуштено је доказивати да одређена ноторна чињеница не постоји или да није постојала, као и то да одређена чињеница није ноторна. Предмет доказивања не могу бити ни чињенице које су утврђене правноснажном осуђујућом пресудом кривичног суда у погледу обележја кривичног дела за које је оптужени оглашен кривим и у погледу одговорности учиниоца, јер је парнични суд тим чињеницама везан. Пресуда кривичног суда којом је окривљени ослобођен оптужбе нема правну снагу правноснажне осуђујуће пресуде кривичног суда.<sup>188</sup>

### 3. О терету доказивања

Код правила о терету доказивања битна су два питања: ко треба да доказује садржај одређене тврдње (субјективно правило) и ко сноси ризик недоказаности – неуспеха (објективно правило), због чега су и установљена одређена правила о терету доказивања.<sup>189</sup> До примене правила о терету доказивања не долази када суду стоји на располагању довољно квалитетних доказних средстава и када он, помоћу њих, може да се увери у истинитост или неистинитост изнесених чињеничних навода. Значај правила о терету доказивања долази до изражаја тек кад суд на основу расположивих доказних средстава не може да формира суд, уверење о истинитости правно релевантне чињенице упркос слободној оцени доказа.<sup>190</sup> Суд је дужан да одлучи о основаности тужбеног захтева чиме се елиминише самопомоћ, да свако сам штити своје право ван органа који је за то надлежан. Приликом одлучивања суд полази од познате римске максиме: *Idem est non esse aut non probari* – што није доказано исто је као и да не постоји. На тај

---

187 Н. Бодирого, нав. дело, стр. 162.

188 Г. Станковић, Грађанско процесно право, стр. 417-418.

189 С. Бркић, нав. дело, стр. 302.

190 Г. Станковић, *Терет доказивања*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 1/10, стр. 8.

начин, суд може да донесе мериторну одлуку, неповољну за странку која је изнела тврдњу, а није је успела доказати.<sup>191</sup>

### 3. 1. Субјективно и објективно правило о терету доказивања

Субјективно правило о терету доказивања представља директну последицу примене начела диспозиције и расправног начела у парничном поступку. Према расправном начелу, које представља директну последицу начела диспозиције у погледу располагања процесним материјалном, странке су одговорне у погледу изношења чињеница и доказа, односно странка је дужна да понуди суду доказе како би доказала правно дејство одређене чињенице. Дакле, странка која тврди да има неко право дужна је да докаже чињенице које су битне за настанак односно остварење тог права, док странка која оспорава постојање неког права доказује чињенице које су спречиле настанак или остваривање тог права, односно које су довеле до његовог престанка.<sup>192</sup>

Са друге стране суд, у циљу правилне примене материјалног права, има обавезу да утиче на странке и да их усмерава током прикупљања чињеничне подлоге и доказног материјала за своју одлуку, кроз постављање питања и усмеравање странака приликом изношења битних чињеница, у смислу чл. 313.

191 Б. Ђурићин, *О терету доказивања у парничном поступку*; Право – теорија и пракса, бр. 7-8/1995, стр. 67-68. „Наиме, Уставни суд налази да је у конкретном случају другостепени суд произвољно применио правила о терету доказивања, те да је сав терет доказивања пребацио на тужилу када је одбио њен тужбени захтев. При томе, Уставни суд је имао у виду да је првостепеном пресудом одбијен тужилин тужбени захтев, јер је оцењено да на страни туженог недостаје пасивна легитимација за вођење спора, а оспореном другостепеном пресудом тужбени захтев је одбијен јер тужена није доказала да је тужени пре објављивања текста могао да утврди истинитост, односно неистинитост информације, па ни са пажњом примереном околностима. Уставни суд закључује да у првостепеном поступку нису утврђене чињенице које су од значаја за одлучивање, имајући у виду да је оцењено да тужени није пасивно легитимисан у спору, због чега ни другостепени суд у оспореној пресуди није могао да преиспита првостепену пресуду у погледу утврђеног чињеничног стања, које треба да представља чињеничну основу пресуде, од које зависи примена материјалног права.“ Одлука Уставног суда Уж. бр. 6181/2013 од 05.12.2016. године.

192 Првостепени суд је прихватајући доказани предлог тужиле за саслушање њеног оца, који је потврдио да супружници нису имали новца за улагање, на околност улагања у градњу, прихватио исказе родитеља туженог ББ пошто поседује писане наменске уговоре о зајму, односно кредиту, при чему није прихватио наводе тужиле и исказ сведока да је у градњи учествовао износом од 55.000 ДЕМ из разлога што такви наводи нису поткрепљени доказима, па је правилно применио одредбу чл. 223. ЗПП када је одбио предлог тужиле за саслушање сведока ЖЖ и ЗЗ на околност градње и предлог за грађевинско и економско вештачење и извео правилан закључак да тужиле није доказала учешће у градњи. Овакав закључак потврђује садржина уговора о нагодби који су тужиле и тужени ББ закључили пред Вишим судом ... дана 17.11.1998. године, према коме ће свака страна задржати искључиво власништво на покретној имовини која се налази у њиховом поседу и ниједна страна неће имати било каква потраживања од друге стране. Иако се овим уговором не регулише право својине на спорној непокретности, може се закључити да тужиле није имала потраживање према тој имовини у време развода брака странака, а тужба у овој паници поднета је 11 година након развода“. Пресуда Врховног касационог суда Рев. 2241/2016 од 09.05.2018. године.

ЗПП. У току извођења доказа суд поставља питања и сведоцима и вештацима, као и странкама, како би стање ствари разјаснио и формирао чињеничну основу за доношење законите одлуке. Суд не може засновати своју одлуку на чињеницама о којима противној странци није била пружена могућност да се изјасни, сходно начелу обостраног саслушања из чл. 5. ст. 1. ЗПП којим је прописано да је суд дужан да свакој странци пружи могућност да се изјасни о захтевима, предлозима и наводима противне странке.

Дакле, користећи се процесним овлашћењима које има у управљању поступком и у извиђању суд ће настојати да прикупи све чињенице које су од значаја за правилну примену материјалног права, при чему странке имају обавезу да својим понашањем у поступку омогуће суду да утврди све чињенице, па уколико изостане њихова активност у том смислу, односно уколику суду не понуде одговарајуће доказе, суд ће одлучити на основу расположивог процесног материјала примењујући правила о терету доказивања.<sup>193</sup>

Субјективно правило о терету доказивања формулисано је у чл. 228. ЗПП као процесна дужност односно терет одређене странке да суду пружи обавештење о доказним средствима, односно да означи доказна средства помоћу којих се суд може уверити у истинитост исказа о одређеној правно релевантној чињеници. Дакле, од тужиоца који тврди да су му угрожена, повређена или оспорена грађанска субјективна права, очекује се да докаже истинитост својих навода и тврдњи, односно потребно је да докаже чињенице које су од значаја за примену материјалноправне норме. Уколико тужени оспори чињенице на којима тужилац заснива свој захтев

---

<sup>193</sup> „Без утврђивања „количине ствари“ која је била предмет уговора о зајму није могуће правилно применити материјално-правну одредбу о враћању позајмице из чл. 562. ст. 1. ЗОО, због чега, у конкретном случају, без утврђивања висине дуга, није могуће донети одлуку о обавези враћања позајмљеног новца. Отуда ревизијске наводе у овом спору око висине дуга треба третирати и као захтев за правилну примену материјалног права, односно са тог аспекта треба ценити наводе ревизије“. Пресуда Врховног касационог суда Рев. 407/2017 од 19.04.2018. године.



или и сам истиче какав захтев, треба да понуди доказе за своје захтеве и чињенице које су од значаја за осујећење или одбијање тужбеног захтева.<sup>194</sup>

Субјективни терет доказивања даје одговор на питање која странка је дужна да суду пружи доказе о истинитости чињеничних тврдњи, док терет доказивања у објективном смислу одговара на питање која ће странка сносити ризик недоказаности, односно која ће странка изгубити парницу ако суд није дошао до одређеног закључка о постојању спорне чињенице.<sup>195</sup>

Дакле, уколико на крају поступка, и поред примене општег правила о терету доказивања у субјективном смислу, одређене правнорелевантне чињенице не буду доказане, одређена странка мора да сноси последицу недоказаности те спорне релевантне чињенице па ће суд, применом правила о терету доказивања у објективном смислу, одлучити на штету оне странке која је била дужна да доказује постојање одређене правно релевантне чињенице од чијег постојања зависи примена одређене правне норме.<sup>196</sup>

Правило о терету доказивања у објективном смислу конкретизовано је у чл. 231. ЗПП, чија примена долази до изражаја када суд на основу изведених доказа, поступајући по начелу слободне оцене доказа из чл. 8. ЗПП, није стекао уверење о истинитости спорне чињенице. Пошто суд у таквој ситуацији не сме да одбије мериторно одлучивање јер обема странкама припада право на правну заштиту, законодавац га овлашћује да примени правила о терету доказивања, којим је прописано на чијој страни лежи ризик недоказаности једне чињенице.<sup>197</sup> Ова правила се не свде на то која странка треба да доказује поједине чињенице, већ

194 Г. Станковић, *Терет доказивања*, стр. 4-5. У ситуацији када међу парничним странкама, а ни према доказима у списима предмета, није спорна чињеница да је тужени дужник по основу ино-кредита по основу неспорно потписаних уговора о кредиту између ББ и туженог, за које је Народна банка Србије издала допис у коме је наведено да споразум о репрограмирању дуга СР Југославије према Швајцарској у оквиру Париског клуба обухватају и обавезе дужника АА овде туженог по основу кредита коришћених преко ББ, уз навођење и одређених износа дуговања, које је Народна банка Србије као агент Државе за за сервисирање спољног дуга прихватила у Споразуму са повериоцима Париског и Лондонског клуба, не може се пребацити терет доказивања на тужиоца посебно у погледу доказа о висини дуга по основу кредита, за коју чињеницу доказе мора имати, пре свега, тужени као корисник кредита у својој књиговодственој евиденцији на основу које је тужени потписивао ИОС образце о постојању дуга у одређеном износу. На туженом је и терет доказивања да је део кредитом добијених средстава вратио и да је тиме умањио своја дуговања. Из тих разлога је у оспореној одлуци погрешно примењено правило о терету доказивања, када је терет доказивања пребачен на тужиоца. Погрешно је цењена и доказна снага ИОС образаца као доказа о постојању дуга и његовој висини, у контексту са другим достављеним доказима; Решење Врховног Касационог суда Прев. 73/2017 од 03.10.2017. године.

195 Б. Познић, *Грађанско процесно право*, Савремена администрација, Београд, 1982, стр. 242.

196 Г. Станковић, нав. дело, стр. 8.

197 Н. Петрушић, Д. Симоновић, нав. дело, стр. 492.

дају одговор на питање како међу парничарима поделити ризик недоказаности одређене правнорелевантне чињенице. Наиме, подела терета доказивања врши се с обзиром на врсту чињеница у питању па странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права, странка која оспорава постојање неког права, сноси терет доказивања чињенице која је спречила настанак или остваривање права или услед које је право престало да постоји, ако законом није другачије прописано (чл. 231. ст. 2. и 3. ЗПП). Оба правила важе под условом да законом није другачије прописано. Уколико суд и после извођења доказа у погледу одлучних чињеница које је предложио тужилац, не може са сигурношћу да закључи да ли одређена чињеница постоји или не, узме да ту чињеницу тужилац у спроведеном поступку није доказао, што се односи и на туженог који у току поступка није пружио суду доказе у погледу чињеница које је истицао у поступку.<sup>198</sup>

Дакле, ако је чињеница остала недоказана, терет доказивања пада на ону странку која ју је предложила, при чему се недоказаност појављује у релацији према скупини чињеница битних за досуђење захтева одређене странке и изражава као недостатак уверења о истинитости чињеничних тврдњи једне странке о постојању одлучних чињеница из којих странка изводи право на досуђивање тужбеног или противтужбеног захтева.<sup>199</sup>

### 3.2. Правила о терету доказивања прописана нормама материјалног права

Основаност тужбеног захтева зависи од испуњености одређених услова која су прописана нормама материјалног права које регулишу конкретни спорни

198 „Током поступка, а по обављеном финансијском вештачењу, тужени је не само спорио да су поједини износи били уопште предмет позајмице већ и коначан закључак вештака о постојању дуга односно да износи који су били предмет зајма нису враћени, а при истим примедбама тужени је остао и у ревизији. Међутим, у вези тих питања другостепени суд с правом указује на правило о терету доказивања из члана 228. у вези члана 231. ЗПП. Тужилац је имао посебну обавезу да докаже постојање уговора о зајму и износе који су позајмљени, а на туженом је била обавеза да побие те чињенице, али са друге стране и да за износе за које је утврђено да су били предмет позајмице да докаже да су ти износи враћени. У складу са тим, тужилац је доставио писмене исправе – молбе овлашћеног лица туженог за позајмицу одређених средстава за конкретне намене као и доказе да је тужилац по тим молбама извршио дознаку тих средстава на начин како је то у молбама тражено, о чему су и вештачи више пута изјашњавали, а тужени није успео да адекватним доказима те закључке вештака, које је суд прихватио, побие. Тужени је истицао да су одређени новчани износи који су неспорно позајмљени од тужиоца враћени од средстава која су добијена продајом играча – фудбалера у иностранству, али и те околности, а на бази доказа које је тужени пружио у поступку, вештачи су ценили и нашли да од тих средстава дуг није враћен, што су нижестепени судови с правом прихватили“. Пресуда Врховног касационог суда Рев. 407/2017 од 19.04.2018. године.

199 С. Бркић, нав. дело, стр. 314.

правни однос, па су и елементи правног односа поводом којег тужилац истиче свој захтев, по правилу, одређени нормама материјалног права у којима треба тражити одговор на питање које чињенице треба доказати и ко то треба да уради.<sup>200</sup>

Наиме, појединим нормама материјалног права изричито је предвиђено коју страну у једном правном односу погађа терет доказивања одређене правнорелевантне чињенице. Тако, на пример, Закон о облигационим односима у одредби чл. 154. прописује да ко другоме проузрокује штету дужан је да је накнади, ако не докаже да је штета настала без његове кривице. Уколико штетник не пружи суду одговарајуће доказе на околност да није крив тј. да постоје околности које искључују његову одговорност или да се догађај из ког је настала штета није десио на начин како је то наведено у тужби, а тужилац, са друге стране, уз тужбу пружи доказе да је радњама туженог проузрокована штета, тужбени захтев ће бити усвојен на основу тих доказа и законске претпоставке о одговорности туженог. Даље, нпр. по тужби за предају ствари у својину тужилац на основу одредбе чл. 37. Закона о основама својинскоправних односа мора да докаже своје право својине и да се ствар налази у државини туженог, а тужени уколико неку од ових чињеница спори мора да докаже правни основ по коме се ствар налази код њега (да је ствар његова), да припада трећем лицу, односно да та ствар уопште није у његовој државини.

#### 4. Припремно рочиште и правила о предлагању доказа

У оквиру одредаба које се односе на припремање главне расправе, а које припреме у смислу чл. 289. ст. 2. ЗПП обухватају претходно испитивање тужбе, достављање тужбе туженом на одговор, одржавање припремног рочишта и заказивање главне расправе, прописана су и правила која се у значајној мери разликују у односу на претходна решења. Сада су спојене у једну целину одредбе које регулишу припремно рочиште и заказивање главне расправе.

200 Б. Ђуричин, нав. дело, стр. 68. „Према члану 1. Закона о меници, меница мора да садржи, као битан елемент, меничну своту. У случају да постоје сви други битни елементи менице, нема законске забране да издавалац менице овласти корисника да сам унесе меничну своту, као што је у конкретном случају, и корисник је у обавези да меницу попуни у складу са меничним овлашћењем. У супротном, меница је ништава. Због начела писмености и меничне строгости, важи претпоставка пуноважности попуњене менице, а на меничном дужнику је терет доказивања да је меница попуњена противно основном уговору чијем обезбеђењу меница и служи, па првостепени суд није дао јасне разлоге из којих сматра да је терет доказивања на тужиоцу обзиром да је тужени јемац платац који је ради обезбеђења плаћања своје обавезе тужиоцу дао менице са меничним овлашћењем, а меницу је тужилац попунио и на основу исте и тражи наплату свог потраживања.“; Решење Привредног апелационог суда, Пж. 2358/2014 од 16.09.2015. године.

#### 4. 1. Поступање суда на припремном рочишту

За разлику од претходног решења по коме није био прописан рок у коме ће суд заказати припремно рочиште, сада је суд дужан да закаже и одржи припремно рочиште у року од 30 дана од дана достављања тужиоцу одговора на тужбу, а ако тужени није поднео одговор на тужбу, а нема услова за доношење пресуде због пропуштања, у року од 30 дана када је истекао рок за достављање одговора на тужбу (члан 301. ЗПП). Позив за припремно рочиште садржи упозорење странака о њиховим дужностима у погледу изношења чињеница и предлагања доказа, што је прописаном чланом 303. ЗПП, све у складу са обавезом суда да поучава странке у погледу њихових процесних права и терета.

Најзначајније обавезе суда на припремном рочишту, у смислу чл. 308. ст. 2. ЗПП огледају се у његовој дужности да утврди: 1) које су чињенице неспорне, ноторне, а које су спорне; 2) која правна питања треба да се расправе; 3) која ће доказна средства да изведе на главној расправи, као и да 4) донесе решење о одређивању временског оквира.<sup>201</sup> Да би суд извршио одвајање спорних од неспорних чињеница, средио процесну грађу и утврдио који ће докази бити изведени ради утврђивања спорних чињеница, потребно је да постављањем питања утиче на странке да изнесу све чињенице и да се изјасне о свим чињеницама које је изнела супротна странка.

На истом (припремном или првом расправном рочишту), сагласно одредби чл. 308. ст. 3. ЗПП, суд је дужан да донесе решење о томе које ће доказе извести на главној расправи. Приликом одлучивања, водиће рачуна, да се доказивање ограничи на правно релевантне чињенице за које норме материјалног права везују одређене правне последице. Чл. 308. ст. 5. ЗПП садржи овлашћење суда да одбије доказни предлог странака који не сматра битним за доношење одлуке, о чему одлучује решењем против кога није дозвољена посебна жалба. Међутим, суд је дужан да у образложењу пресуде наведе које је доказне предлоге одбио и из којих разлога.

---

<sup>201</sup> Може се десити да, на пример, суд од првобитно пет предложених сведока прихвати да саслуша два, а да накнадно процени да је потребно саслушање и неостала три сведока, али би се тада морао одредити нови временски оквир за окончање поступка. У сваком случају, пред судом је озбиљан задатак да на припремном рочишту одреди које су чињенице спорне и који би докази требали да се изведу. У том смислу би увек требало ићи на прихватање више доказних предлога, да не би настала потреба за накнадним изменама; Н. Бодирога, нав. дело, стр. 186.

## 4.2. Поступање странака и преклузија

Странке су дужне да у фази припремања главне расправе благовремено достављају поднеске у којима наводе чињенице на којима заснивају своје захтеве и предлажу доказе којима се потврђују те чињенице (члан 289. ст. 3. ЗПП). Одредбе ЗПП-а из 2004. године прописивале су да „странке у циљу припремања главне расправе могу да упућују поднеске у којима ће навести чињенице које намеравају да изнесу на главној расправи, као и доказе чије извођење намеравају да предложе“. Странке сада имају обавезу, под претњом пропуштања, да благовремено наведу све чињенице и доказе на којима заснивају своје захтеве.

Напуштање досадашње концепције по којој су странке без ограничења могле да изнесу нове чињенице и доказе све до закључења главне расправе пред првостепеним судом, конкретизовано је кроз одредбу чл. 308. ст. 1. ЗПП којом је приписано да је странка дужна да најкасније на припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну расправу, ако припремно рочиште није обавезно: 1) изнесе све чињенице потребне за образложење својих предлога, 2) да предложи доказе којима се потврђују изнете чињенице, 3) да се изјасни о наводима и понуђеним доказима противне странке као и 4) да предложи временски оквир за спровођење поступка.

Основ парничног поступка је један животни догађај, чија су обележја странкама добро позната и пре његовог покретања. Спор претходи парничном поступку, а не развија се упоредо са њим. Чињенични основ спора је познат пре покретања парничног поступка а на странкама је да, у складу са расправним начелом, предложе суду чињенице и доказе којима ће се исте утврдити пред судом и то на припремном рочишту уколико се оно одржава.<sup>202</sup>

Дакле, већина одредаба из чл. 308. ЗПП представљају новину у односу на ранија решења и њима су прописане дужности странака у погледу изношења процесног материјала и њиховог учешћа у утврђивању временског оквира за спровођење поступка, као и дужности суда у погледу прикупљања и селекције процесног материјала и утврђивања временског оквира за спровођење поступка. Ове дужности странака и суда су у функцији остваривања начела концентрације поступка, кроз ојачавања његове временске и садржинске димензије, у циљу остваривања начела ефикасности поступка.<sup>203</sup>

202 Н. Бодирога, нав. дело, стр. 185.

203 Н. Петрушић, Д. Симоновић, нав. дело. стр. 577-578.

### **Закључна разматрања**

Прихватањем расправног начела као доминантног у парничном поступку, уз сужену примену истражног начела, законодавац је прописао дужност странака да изнесу све чињенице на којима заснивају своје захтеве и да предложе доказе којима се утврђују те чињенице. Истражно начело је сведено на изузетак и то у ситуацији када странке располажу захтевима којима не могу располагати и када је то предвиђено посебним прописом. Такође, суд по службеној дужности утврђује процесне претпоставке и води рачуна да се у поступку утврде све чињенице које су од утицаја на правилну примену материјалног права, користећи се овлашћењем да се постављањем питања и на други начин стара да се у поступку изнесу све битне чињенице, да се означи или допуне доказна средства која се односе на наводе странака и да се пружи сва разјашњења како би се утврдило чињенично стање важно за одлуку. Суд је, дакле, одговоран да се у поступку утврде све чињенице које су потребне за примену одговарајуће одредбе материјалног права, при чему је без утицаја да ли се ради о утврђивању чињеница на основу оцене доказа или применом правила о терету доказивања.

Када суд на основу слободне оцене доказа не може са сигурношћу извести закључак о постојању одређене правнорелевантне чињенице, која је од утицаја на правилну примену норме материјалног права, насталу чињеничну неизвесност решиће применом правила о терету доказивања, који у процесној литератури има двојако значење. С једне стране, њиме се означава субјективни терет доказивања који подразумева дужност странке да суду пружи информације о доказним средствима на основу којих се суд може уверити у истинитост исказа о одређеној правно релевантној чињеници, која је од значаја за примену норме материјалног права, па ће странке у току доказног поступка, настојати да се тај терет пребаци на другу странку, и да се одбију настојања противника да тај терет врати натраг странци која га се ослободила.

Говорећи о субјективном терету доказивања, говоримо о наизменичној потреби да се у поступку активира једна односно друга страна, о прелажењу иницијативе са једне на другу странку док, са друге стране, правила о терету доказивања у објективном смислу дају одговор на питање ко сноси ризик у случају да нека од чињеница не буде доказана и примењује се закон окончања

доказног поступка, за разлику од субјективног правила које се примењује до закључења главне расправе.<sup>204</sup>

Дакле, суштина правила о терету доказивања огледа се у томе да терет доказивања лежи на оној странци која се позива на чињеницу на којој заснива своје право или, у другом облику, свака странка треба да докаже претпоставке за примену правне норме која је по њу повољнија.<sup>205</sup>

На овом месту ћемо указати и то да су ретке одредбе закона које изричито регулишу дистрибуцију терета доказивања. Наиме, поред општих правила о терету доказивања која су садржана у ЗПП, постоје и посебна правила којима је регулисан распоред терета доказивања, као што је случај у парницама за заштиту од дискриминације у којима се примењују специфична правила о прерасподели терета доказивања.<sup>206</sup>

Позивање судова на правила о терету доказивања не сме се вршити без давања јасних разлога за примену овог правила, па је потребно да суд у образложењу своје одлуке наведе да ли се ради о чињеници важној за доношење одлуке, која странка је имала обавезу доказивања те чињенице и да ли се уопште радило о потреби доказивања те чињенице. Ово с тога што опште правило о терету доказивања пружа тек уопштен оквир за одлучивање у индивидуалним случајевима – оквир који изискује додатну интерпретацију и конкретизацију, о чему образложење пресуде мора садржати јасне разлоге у сваком конкретном случају.

204 У овом контексту треба подсетити и на обавезе странака да нове чињенице и нове доказе изнесу на припремном рочишту, а ако оно није држано на првом рочишту за главну расправу. Могу их изнети и касније, до закључења главне расправе, само ако учине вероватним да их без своје кривице нису могле изнети раније.

205 А. Узелац, Терет доказивања, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, стр. 339.

206 Одредбом чл. 45. ст.2. Закона о заштити од дискриминације прописано је да, уколико тужилац учини вероватним да је тужени извршио акт дискриминације, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза сноси тужени. Наиме, у парници за заштиту од дискриминације тужилац треба да учини вероватним да је до дискриминације дошло, при чему степен извесности мора бити такав да се постојање дискриминације чини вероватнијим него да дискриминације није било, а ти изгледи се заснивају на доказима на којима се темељи постојање вероватноће да је дошло до дискриминације. У погледу прерасподеле терета доказивања, једнак стандард требао би да важи како за тужиоца тако и за туженог. Дакле, ако је довољно да тужилац учини вероватним да је тужени учинио акт дискриминације, чини се да би и за туженог требало да буде довољан исти степен извесности да би се ослободио обавезе која из прерасподеле терета доказивања проистиче. У ту сврху, он може користити противдоказ, којим ће накнадно довести у питање вероватност онога што је тужилац требало да докаже или доказ о противном којим ће доказати да је вероватније да дискриминација не постоји доказавши да је вероватније супротно. А. Тасић, Поступак у парницама за заштиту од дискриминације – Докторска дисертација, стр. 315-317.



## NAŠ TIM

Za uspešno poslovanje potrebna je  
kvalitetna pravno-ekonomska baza.  
Za kvalitetnu bazu potreban je profesionalan tim.  
Naš tim broji preko:

- ◆ 180 zaposlenih koji se svakodnevno brinu o tome da dobijete blagovremenu i tačnu informaciju
- ◆ 200 stalnih autora iz oblasti pravnih, ekonomskih i ostalih nauka
- ◆ 17.000 višegodišnjih korisnika koji svojim sugestijama doprinose kvalitetu baze "Paragraf Lex"

BUDŽETSKI  
INSTRUKTOR

SUDSKA  
PRAKSA

SLUŽBENA  
MIŠLENJA

PRAVNO-  
EKONOMSKE  
VESTI

OBRASCI

CARINSKA  
TARIFA

STRANA  
SUDSKA  
PRAKSA

PROPSI

MODELI

PRAVNIK  
U PRAVOSUĐU

EVROPSKO  
ZAKONODAVSTVO

PORESKO  
RAČUNOVODSTVENI  
INSTRUKTOR

INSPEKTOR

PRAVNIK  
U JAVNOM  
SEKTORU

PRAVNIK  
U PRIVREDI

SPECIJALIS  
ZA CARINE

Želite pouzdanu pravno-ekonomsku bazu na koju možete  
da se oslonite i koja će Vam ponuditi stručne tekstove,  
pronaći odgovore i biti Vaš virtuelni saradnik?

IMAMO REŠENJE ZA VAS!

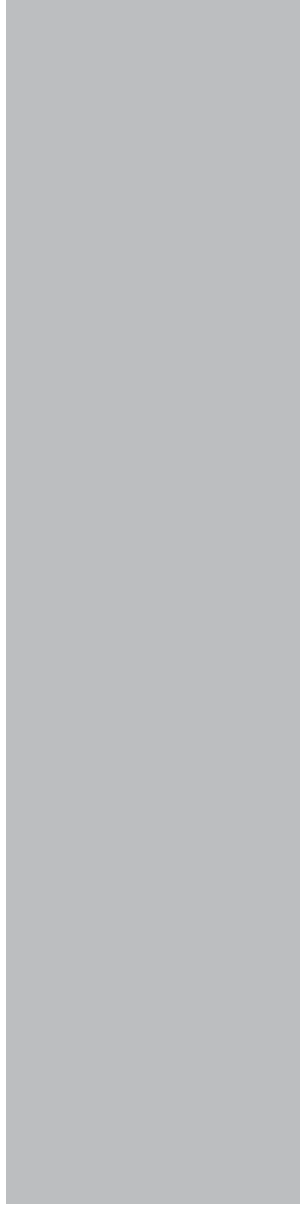


**Paragraf Lex**  
PRAVNA BAZA

[www.paragraf.rs](http://www.paragraf.rs)



**ПРАВНИ СТАВОВИ,  
ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ  
НА СПОРНА ПИТАЊА**





## **ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА**

представника грађанских одељења и одељења за радне спорове Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и Привредног Апелационог суда, у присуству представника Врховног касационог суда, на заједничким седницама одржаним у току 2017. и 2018. години, око спорних питања од значаја за функционисање судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе (члан 24.став 3.Закона о уређењу судова- “Службени гласник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда)).

### **ЗАКЉУЧЦИ СА ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА И ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ОДРЖАНОГ У БЕОГРАДУ ДАНА 08.12.2017.ГОДИНЕ.**

Констатује се да су на овом састанку, од стране свих апелационих судова **једногласно усвојени следећи**

#### **ЗАКЉУЧЦИ**

1. У погледу застарелости потраживања у односу на предузетнике, примењује се рок од 10 година, прописан одредбом чл.371. Закона о облигационим односима ( с тим што судије Апелационог суда у Крагујевцу имају подељено мишљење о овом питању).
2. Камата код регресних потраживања осигуравачу припада од стране исплате накнаде штете.
3. Привредни суд је надлежан за поступање по тужби ради проглашења извршења недопуштеним када је тужба поднета након отварања поступка стечаја над тужиоцем.

**Питање о којем се апелациони судови нису усагласили**

1. Да ли се тужбени захтеви идентификују искључиво по тужбеном предлогу, петитуму, или се идентификују и по чињеницама на којима се ти предлози заснивају (чињенични услов тужбеног захтева), у ситуацијама када сепетитумом тужбеног захтева тражи да се ништи уговор, а чињенични наводи тужбе се односе на утврђење апсолутне ништавости?

**ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДНИЦЕ ГРАЂАНСКИХ ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ, АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ, АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ И ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА, СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 23.03.2018.ГОДИНЕ У НОВОМ САДУ.**

**Констатује се да на састанку**

Поводом коначног правног става Апелационог суда у Београду о питању застарелости наплате судске таксе:

- Постоји сагласност апелационих судова да се наплата судске таксе спроводи у судском, а не административном поступку;
- Не постоји сагласност апелационих судова да суд не пазе по службеној дужности на застарелост права наплате судске таксе;
- Постоји сагласност апелационих судова да се приговор застарелости може истицати у правном леку против решења о вршењу донетог на основу чл.40. Закона о судским таксама;
- Не постоји сагласност апелационих судова да се застарела прекида достављањем опомене или налога за плаћања судске таксе у складу са чл.388. ЗОО;
- Не постоји сагласност апелационих судова око природе рока за наплату судске таксе.

Поводом коначног правног става Апелационог суда у Београду о питању ништавости одредбе уговора о кредиту, којом се корисник обавезује да

банци плати трошкове обраде кредита у процентуалном износу од износа одобреног кредита издвојеног мишљења судија Драгане Миросављевић, досадашњег става Привредног апелационог суда о праву банке на трошкове обраде кредита и алтернативе судије Снежане марић о ништавости уговорне одредбе и накнади трошкове обраде кредита.

- **Не постоји сагласност** апелационих судова о праву банке на трошкове обраде кредита.

**ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДНИЦЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ, АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ И АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ, СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ОДРЖАНЕ 15.06.2018.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА.**

**Констатује се да су на састанку од стране свих апелационих судова једногласно усвојени правни ставови**

1. Прихваћен је став Апелационог суда у Новом Саду, да припадницима полиције, након доношења одговарајућег решења о распоређивању и коефицијената за обрачун плате по Правилнику од 2012.године, због утврђеног додатног коефицијента садржаног у плати, не припада право на увећање плате 30-50 %, по основу чл.146. Закона о полицији из 2011. године са изменама.

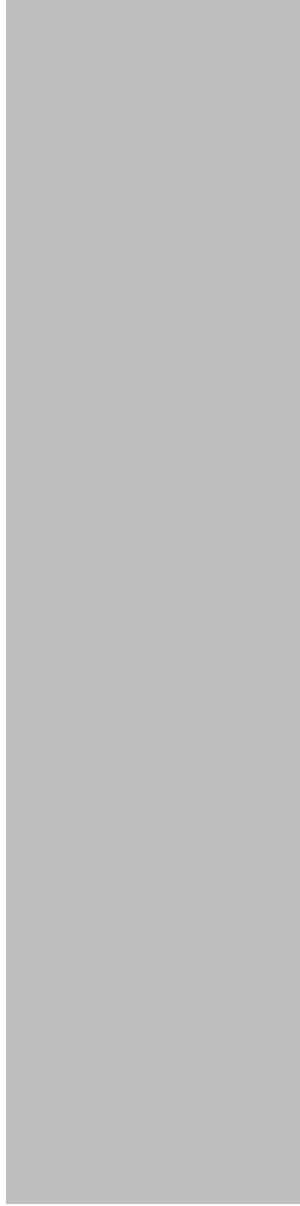
**Констатује се да на састанку од стране свих апелација не постоји јединствен став по питању**

1. Када је у поступцима за заштиту од насиља у породици првостепени суд изреком пресуде најпре утврдио да је насиље учињено, са детаљним описом начина, радњи и периода извршења, а затим одлучио о мерама заштите, да ли у ситуацији када досуђује мере треба потврдити Апелациони суд као другостепени има овлашћење да тако утврђујући део изреке пресуде укине и у том делу одбаци тужбу, без обзира да ли се на то указује жалбом или не?

2. Запослени у МУП-у који се определио за долазак и одлазак са рада у висини месечне претплатне карте у месецу у коме нема пун фонд часова рада, има право на накнаду истих трошкова максимално у вредности цене месечне претплатне карте обрачунате према броју радних дана остварених у месецу у вредности појединачне дневне превозне карте.

# ГРАЂАНСКО ПРАВО

## СУДСКА ПРАКСА







## ПРОЦЕСНО ПРАВО

### СТРАНАЧКА СПОСОБНОСТ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И ДОСТАВЉАЊЕ

(чл. 5. Закона о политичким странкама)

**Градски одбор политичке странке нема својство правног лица и не може бити странка у поступку због недостатка парничне способности, па се достављање свих писмена врши у средишту политичке странке, која има својство правног лица, а не у организационој јединици која нема својство правног лица и није овлашћена за пријем писмена.**

#### *Из образложења:*

Према чл. 5 Закона о политичким странкама, политичка странка стиче статус правног лица даном уписа у Регистар политичких странака. Политичку странку заступа лице овлашћено за заступање политичке странке, изабрано односно именовано на начин утврђен Статутом. У Регистар се поред осталог уписује лично име заступника политичке странке. Организационе јединице по територијалном принципу немају статус правног лица. У конкретном случају Градски одбор политичке странке нема својство правног лица, па нема ни страначку способност. Достављање писмена врши се достављањем правном лицу, а не организационој јединици која нема својство правног лица и није овлашћена за пријем писмена. Како су тужба, поднесци и позиви, као и првостепена пресуда достављени Градском одбору политичке странке, а не странци у њеном седишту као правном лицу, то је на наведени начин учињена апсолутно битна повреда одредаба парничног поступка у смислу чл. 374. ст. 2 тач.9 ЗПП, због чега је побијана пресуда морала бити укинута.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж.бр.451/16 од 30.03.2016. године)*

*Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски  
сарадник Апелационог суда у Нишу*

## ПРАВНИ ИНТЕРЕС УМЕШАЧА

(чл. 215.ст.1. Закона о парничном поступку)

**Приликом оцене правног интереса, суд не треба да утврђује да ли умешач, неко своје право може остваривати другим правним путем, већ само, да ли одлука у парници која се води може бити од утицаја на одређена права и обавезе умешача.**

### *Из објасњења:*

Према утврђеном чињеничном стању од стране првостепеног суда, тужбу у овој правној ствари поднела је мал. М. П., кћи умешача П. П., који је законски наследник, пок. Ј. П.. Пок. Ј. је закључио са туженима Уговор о доживотном издржавању, који је оверен пред Основним судом у Нишу дана 16.06.2014. год. под бр....., у коме је наведено да живи сам од 1969. год. и да има једног сина (овде умешача), који га је комплетно занемарио, не обилази га и не интересује се за његово здравствено стање, бежи од обавезе издржавања и указивања неопходне помоћи, па га сматра недостојним за наслеђивање и искључује га из наслеђа. На овако утврђено чињенично стање, првостепени суд стаје на становишту, да се уговором о доживотном издржавању не може законски наследник искључити из наслеђа, јер је недостојност за наслеђе прописана Законом о наслеђивању, а умешач своја права може остварити у посебној парници за поништај закљученог уговора, уколико сматра да су испуњени законски услови, па налази да, умешач нема правни интерес да се у ову парницу умеша.

Овакав став првостепеног суда се не може прихватити.

Члан 215 ст. 1 ЗПП-а прописује да лице које има правни интерес да у парници која се води међу другим странкама успе, може да се придружи тој странци.

Приликом оцене правног интереса, суд не треба да утврђује да ли умешач неко своје право може остваривати другим правним путем, већ само, да ли одлука у парници која се води може бити од утицаја на одређена права и обавезе умешача. Правни интерес умешача постоји увек када га правноснажност пресуде донете у парници других странака погађа, тј. када та пресуда својом садржином може деловати и на њега, у ком случају умешачу треба омогућити да он својом процесном активношћу у туђој парници, утиче на њену садржину, због чега правни интерес представља процесну претпоставку за ступање у туђу парницу.

У конкретном случају првостепени суд правилно налази да се уговором о доживотном издржавању законски наследник не може искључити из наслеђа, већ да се то може учинити само на начин прописан чл. 64-65 Закона о наслеђивању и да је умешач законски наследник пок. Ј. Међутим, пропушта да цени, имајући у виду да је предмет овде примарног тужбеног захтева тужиле утврђење ништавости уговора о доживотном издржавању, закљученог између оца умешача и овде тужених и утврђење права својине на стварима којима је тим уговором располагао, односно да је предмет евентуалног тужбеног захтева, раскид истог уговора о доживотном издржавању и утврђење да наведене ствари из уговора представљају заоставштину пок. Ј. П, да ли одлука донета у овој парници може бити од утицаја на права и обавезе умешача, као законског наследника пок. Ј., те да ли он има правни интерес у смислу чл. 215 ст. 1 ЗПП-а да се придружи парници на страни тужиле.

*( Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. бр. 2639/17 од 09.05.2017. године )*

*Аутори сентенце: Зорица Стошић, судија Апелационог суда  
у Нишу са судијским помоћником Иваном Стевановић*

## ПРИХВАТАЊЕ НОВОГ ДОКАЗА ПОДНЕТОГ УЗ ЖАЛБУ

чл.372 ст.1 ЗПП

Када туженог као странку, која је непознатог пребивалишта, у поступку заступа привремени заступник, тада она, у жалбеном поступку, може побијати пресуду уз прилагање нових доказа, јер исте није могла да достави до закључења главне расправе.

### *Из образложења:*

Жалбом тужене указује се на неправилност првостепене пресуде са позивањем на то да тужиле немају активну легитимацију за подношење тужбе у овој правној ствари, имајући у виду приложени доказ-отправак записника о поравнању Р1 бр.32/2008 од 17.06.2008.године, сачињен пред Општинским судом у З....., као и решење Службе за катастар непокретности од 06.10.2017.године.

Другостепени суд је узео у обзир нове доказе приложене уз жалбу, сходно одредби чл.372 ст.1 ЗПП, јер је тужена, која је за парницу сазнала тек у жалбеном поступку, учинила вероватним да исте, без своје кривице, није могла доставити до закључења главне расправе пред првостепеним судом, с обзиром да ју је током првостепеног поступка заступао привремени заступник, који није имао увид у чињенично и правно стање за доношење законите и правилне одлуке.

Првостепени суд у побијаној пресуди утврђује да су тужиле сувласнице предметног стана из тужбеног захтева, међутим, из приложених доказа уз жалбу произилази да су оне, на име свог сувласничког удела, од стране осталих сувласника исплаћене по поравнању износом од 7.000 евра, након чега су се ови уписали као власници наведеног стана код СКН. Како ови докази нису могли бити изведени и цењени у првостепеном поступку све до закључења главне расправе, то је првостепена одлука морала бити укинута, јер је заснована на погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању.

*Пресуда Основног суда у Зајечару П 1091/17 од 04.06.2018 године,  
Решење Апелационог суда у Нишу Гж. 5446/2018 од 20.09.2018 године  
Аутор сенценце: Добрила Здравковић, судија Апелационог суда у Нишу*

## **НЕПОСТОЈАЊЕ ПАСИВНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ГАРАНТНОГ ФОНДА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ**

Чл.99. Закона о осигурању имовине и лице

Гарантни фонд није пасивно легитимисан за штету, нанету возилом чији се власник није осигурао од одговорности, а која је настала пре ступања на снагу одредаба Закона о осигурању имовине и лица, које регулишу поступак пред овим фондом и његова овлашћења.

### ***Из образложења:***

Апелациони суд је закључио да се на накнаду штете, настале услед штетног догађаја, који се десио 01.06.1996. године, не могу применити одредбе о Гарантном фонду чије је оснивање предвиђено одредбама чл. 99 ст.1 Закона

о осигурању имовине и лица („Сл.лист СРЈ“ бр. 30/96, 57/98-исправка, 53/99 и 55/99- исправка), како је то неправилно закључио првостепени суд, пошто су ове одредбе ступиле на снагу годину дана након ступања на снагу самог закона 06.07.1996 године, а сходно одредби чл.156. Одредбама овог закона није предвиђено да Удружење осигуравача Србије- Гарантни фонд одговара за накнаду штета које су настале пре ступања на снагу одредаба о Гарантном фонду, већ да се оне надокнађују на начин предвиђен чл. 157. Закона.

Одлучна чињеница за утврђење постојања одговорности туженог је тренутак настанка штете, а сходно одредби чл. 186.ЗОО, према којој се обавеза накнаде штете сматра доспелом у тренутку наступања штете. Имајући у виду да се штетни догађај десио 06.01.1996.године, дакле пре ступања на снагу Закона о осигурању имовине и лица, накнада штете, нанете возилом чији власник се није осигурао од одговорности, може се остварити само у складу са законом који је тада био на снази, а то је Закон о основама система осигурања имовине и лица („Службени лист СФРЈ“ бр- 17/90 и др.). Одредбе чл. 99. ст. 1. и 2. тог закона, које иначе одговарају одредбама чл. 157. ст.1. и 2. Закона о осигурању имовине и лица, предвиђају поступак по коме се накнада штете може остварити у таквим случајевима. Стога је основан приговор недостатка пасивне легитимације, истакнут од стране туженог, јер он није одговоран за накнаду штета које су настале пре ступања на снагу одредба о Гарантном фонду 06.07.1997.године. Тужилца је имала на располагању Законом предвиђен правни пут за остварење свог потраживања, који није искористила, већ је тужбени захтев усмерила према туженом, као правном лицу које није ни било основано у тренутку настанка штете, па тиме не може бити дужно да је накнади.

Из наведених разлога Апелациони суд је преиначио првостепену пресуду и одбио тужбени захтев за накнаду штете као неоснован.

***Пресуда Основног суда у Лесковцу П.бр. 3926/2017 од 16.11.2017.године***  
***Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 242/2018 од 20.09.2018.године***  
***Аутор сентенце: Добрила Здравковић, судија Апелационог суда у Нишу***

## ОСНОВНИ И ЕВЕНТУАЛНИ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ

Када првостепени суд поступи супротно чл. 197. ст. 2. ЗПП и усвоји примарни тужбени захтев а онда одлучи и о евентуалном па исти одбије, другостепени суд је овлашћен да по службеној дужности при одлучивању о жалби против првостепене пресуде у делу којим је усвојен примарни тужбени захтев, одлучи и о делу пресуде којим је одбијен евентуални тужбени захтев и када на тај део пресуде жалба није изјављена.

### *Из образложења:*

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је 1971. године са сада пок. С. Ђ., оцем туженог М. постигао усмени споразум о трампи, тако да се кат. парцели тужиоца бр. 617 припоји део кат. парцеле бр. 618/4 власништво сада пок. Ђорђа, а да тужилац за ове непокретности сада пок. Ђ. уступи кат. парцелу бр. 619/4. Након постигнутог споразума тужилац је припојио свом дворишту део уступљене парцеле и поставио дрвену ограду од тараба, коју је касније заменио бетонским парапетом и оградом од жице. Тужилац је основним тужбеним захтевом тражио да се утврди да је по основу закљученог уговора о трампи из 1971. године постао власник кп.бр. 618/4, док је евентуалним тужбеним захтевом тражио утврђивање права својине на предметној непокретности по основу одржаја. Одлучујући о основаности тужбеног захтева првостепени суд је ставом првим изреке усвојио основни тужбени захтев тужиоца, док је ставом другим изреке одбио евентуални тужбени захтев као неоснован. Против наведене пресуде жалбу је изјавио тужени побијајући је у ставу првом изреке којим је усвојен основни-примарни тужбени захтев.

Апелациони суд налази да се да се због противуречних и нејасних разлога изнето становиште првостепеног суда за сада не може прихватити као правилно.

Првостепени суд није дао јасне ни довољне разлоге када је усвојивши основни-примарни тужбени захтев тужиоца за утврђивање права својине по основу уговора о трампи, одбио као неоснован евентуални тужбени захтев тужиоца за стицање права својине на предметним непокретностима по основу одржаја, уз образложење да због тога што је усвојен примарни тужбени захтев тужиоца, евентуални тужбени захтев треба одбити као

неоснован. Наиме, одлучивање о евентуалном захтеву је допуштено тек кад суд нађе да основни захтев није основан. Кад суд усвоји основни захтев, одлучивање о евентуално кумулираним захтевима постаје беспредметно. Како се у конкретном случају ради о тзв. евентуалном спајању тужбених захтева, у ком случају је тужилац, сагласно одредби чл. 197. ст. 2. ЗПП у једној тужби истакао два међусобно повезана тужбена захтева, али тако да суд може да усвоји следећи од тих захтева ако нађе да онај који је испред њега истакнут није основан, то првостепени суд није имао законско овлашћење да, у конкретном случају, одбије евентуални тужбени захтев као неоснован. Ово са разлога што уколико суд нађе да је главни-примарни тужбени захтев основан, тада се о евентуално постављеном тужбеном захтеву не одлучује.

Са изнетог овај суд је по службеној дужности укинуо и одлуку првостепеног суда у односу на одбијајући део тужбеног захтева постављеног у форми евентуалног захтева, на који део пресуде тужени М. није изјавио жалбу, јер се ради о конексним захтевима.

*(Решење Апелационог суда у Нишу 26Гж.1238/2018 од 19.09.2018. године)*

*Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски  
сарадник Апелационог суда у Нишу*

## УВЕЋАЊЕ ТРОШКОВА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА НА ИМЕ ПДВ-а

**Достављени „обрачун“ о награди и накнади трошкова адвоката који садржи број предмета али не садржи број рачуна, не може представљати валидан доказ о издавању рачуна за извршене адвокатске услуге.**

### ***Из образложења:***

Првостепени суд је правилно закључио да тужиоцима не припада увећање трошкова за 20% на име ПДВ-а јер је одредбом чл. 42 Закона о порезу на додату вредност прописана обавеза пореског обвезника да изда рачун за сваки промет, добара и услуга, а у конкретном случају пуномоћник

тужилаца није издао рачун за пружане адвокатске услуге, нити је доказ о издатом рачуну доставио суду у законском року након доношења пресуде на основу признања ван рочишта, због чега приложени обрачун (а не рачун о награди и накнади трошкова адвоката) уз жалбу није од утицаја на другачију одлуку овог суда.

Наиме, правилна примена одредбе Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката налаже да пуномоћник адвокат достави суду доказ да је обвезник пореза на додату вредност, и рачун за извршене адвокатске услуге, јер му само у том случају припада увећање на име ПДВ-а за извршен обрачун накнаде и трошкова, што није учинио, са којих разлога истом не припадају трошкови увећани за износ ПДВ-а за пружене услуге. Осим наведеног, достављени обрачун о награди и накнади трошкова адвоката који садржи број предмета али не садржи број рачуна, (а самим тим ни доказ да је заведен у пословну књигу пуномоћника тужилаца, као издаваоца рачуна), не може представљати валидан доказ о издавању рачуна за извршене адвокатске услуге према одредбама Закона о рачуноводству (члан 10), а самим тим ни да су подаци из те исправе стално доступни сходно чл. 8. истог закона. Због наведеног, како пуномоћник тужилаца, сем доказа да је обвезник ПДВ није доставио рачун за извршене адвокатске услуге као законом прописану рачуноводствену исправу, то је правилно првостепени суд одлучио да му ти трошкови и не припадају.

***(Решење Апелационог суда у Нишу 21Гж.бр.4408/2018 од 17.10.2018. године)  
Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски  
сарадник Апелационог суда у Нишу***



## ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

### НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ИЛИ НЕПРАВИЛНОГ РАДА ДРЖАВНОГ ОРГАНА

Правилност коначног управног решења (на основу ког је предузећу тужиоца одузета роба), које је донето од стране надлежног органа управе у законом прописаном поступку, не може бити испитивана у парничном поступку ради утврђивања основа за накнаду штете у смислу чл. 172. ст. 1. ЗОО, јер је тужилац имао могућност покретања управног спора због ћутања администрације, уколико је сматрао да наведено решење није донето у законом прописаном року, што исти није учинио, па није ни доказао постојање незаконитог или неправилног рада државног органа, које би оправдавало досуђивање тражене накнаде штете.

#### *Из образложења:*

Првостепени суд је правилно закључио да не постоји основ за повраћај робе која је предмет тужбеног захтева јер је иста одузета на основу коначног и правноснажног решења донетог у управном поступку. У току првостепеног поступка је утврђено да је након поништаја донетих решења од стране надлежног органа тужене, поново спроведен првостепени управни поступак у коме је донето решење о одузимању предметне робе од предузећа ПП „К. п.“, против ког решења није изјављена жалба, чиме је исто постало коначно. С обзиром на наведено, како парнични суд није овлашћен да у редовном парничном поступку преиспитује законитост и правилност правноснажног решења донетог у управном поступку, на основу кога је тужиоцу у поступку контроле одузета предметна роба, јер се ради о управној ствари, неоснован је тужбени захтев тужиоца за утврђење да су органи тужене неосновано, односно незаконито одузели робу у власништву тужиоца, како је то правилно утврдио и првостепени суд. Правилност и законитост наведеног решења могли су бити предмет оцене само у жалбеном поступку пред надлежним другостепеним управним органом или у управном спору, који није покренут. Са изнетих разлога без утицаја су на другачију одлуку суда наводи тужиоца да спорно решење није никада примио, јер је имао могућност покретања

управног спора због ћутања управе, уколико је сматрао да наведено решење у одређеном року није донето. Како у конкретном случају није утврђено постојање незаконитог или неправилног рада државних органа, у смислу чл.172 ЗОО и како је роба од предузећа тужиоца била одузета на основу коначног управног решења, донетог од стране надлежног органа у прописаном поступку, које решење је од прејудицијелног значаја за одлучивање у овој парници, а чија правилност не може бити предмет овог поступка, то је првостепени суд правилно одбио тужбени захтев тужиоца и одлучио као у ставу првом изреке побијане пресуде.

*Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж.бр.1897/16 од 13.10.2016. године*  
*Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски*  
*сарадник Апелационог суда у Нишу*

## РЕГРЕСНО ПОТРАЖИВАЊЕ СОЛИДАРНИХ ДУЖНИКА

Обавезе солидарних дужника су самосталне, па један дужник не може својим поступцима отежати положај осталих садужника, због чега поравнање које је закључио један солидарни дужник са повериоцем, без утврђења солидарне обавезе дужника, како по основу тако и по висини, не обавезује остале солидарне дужнике који такво поравнање нису прихватили.

### *Из образложења:*

Првостепени суд је ценећи основаност тужбеног захтева тужиоца у смислу одредби чл. 414. ст. 1. и чл. 418. ЗОО правилно закључио да је тужилац Компанија „Дунав осигурање“ са оштећеном Д. закључио вансудско поравнање бр.01-4198 дана 23.06.2008. године тако што је на име душевних болова због умањења животне активности исте добровољно исплатио износ од 180.000,00 динара, на име наружености износ од 80.000,00 динара и на име трошкова парничног поступка износ од 87.000,00 динара, укупно 347.000,00 динара, на који начин је извршио исплату без изведеног доказа вештачења душевних болова за наведене видове тражене штете, на шта је указано пресудом Окружног суда у Лесковцу Гж.бр.1140/07 од 18.02.2008. године, на који начин би се утврдило да ли оштећена Б. Д. има право на накнаду тражених видова

нематеријалне штете и ако има, висину исте, сходно степену умањења животне активности и наружености и интензитету и дужини трајања душевних болова, на којој је био терет доказивања у смислу чл.231. ст.2. ЗПП. Дакле, Компанија „Дунав осигурање“ је закључила наведено вансудско поравнање и оштећеној исплатила напред наведене износе без утврђења солидарне обавезе дужника како по основу тако и по висини за наведене видове тражене нематеријалне штете и трошкове парничног поступка. Како обавеза солидарних дужника није била утврђена, а овде тужени Б. Т. није био уговорна страна у закљученом вансудском поравнању, нити је наведено вансудско поравнање прихватио, то износ који је тужилац исплатио оштећеној у смислу чл.418. ЗОО туженика не обавезује, због чега тужбени захтев тужиоца није основан.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж.бр.1929/16 од 14.09.2016. године)*  
*Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски*  
*сарадник Апелационог суда у Нишу*

## НЕПРАВИЛНО ОЗНАЧЕЊЕ СТРАНKE У УГОВОРУ

(Члан 103 Закона о облигационим односима и  
 чл. 33 Закона о привредним друштвима)

Није од утицаја на пуноважност закљученог уговора околност, да је приликом сачињавања уговора коришћењем формуларног обрасца, грешком као уговорна страна у уговору означено привредно друштво које је у моменту закључења уговора већ престало да постоји услед спроведене статусне промене брисања услед припајања, уколико је уговор снабдевен печатом привредног друштва које је као друштво стицалац, правни следбеник и потписан од стране овлашћеног лица правног следбеника.

### *Из образложења:*

Тужилац је поднео тужбу Основном суду у П. ради утврђења ништавости закљученог уговора о вансудском поравнању, а као разлоге ништавости између осталог је навео погрешно означање повериоца у уговору, који је непостојећи привредни субјект, јер је у моменту закључења уговора већ престао да постоји услед спроведене статусне промене брисања услед припајања.

Првостепени суд је одбио тужбени захтев тужиоца налазећи да је уговор правно ваљан.

Неосновано се у жалби тужиоца указује на начињену битну повреду одредбе чл.374. ст.2. тач.12. ЗПП и да пресуда садржи противуречне разлоге у погледу означања уговорне стране – повериоца, у предметном уговору. Ово стога, што је првостепени суд правилно ценио, да је у самом тексту уговора као поверилац означено привредно друштво које је статусном променом у моменту закључења уговора већ престало да постоји, али је при том правилно ценио и, да је закључени уговор снабдевен печатом привредног друштва стицаоца и потписом овлашћеног лица друштва стицаоца, обзиром да је у смислу чл. 33 Закона о привредним друштвима од стране самог друштва прихваћено иступање потписника уговора у име туженог, а тужилац до закључења главне расправе није спорио његово овлашћење за заступање, па суд правилно закључује да овакав пропуст у самом уговору није од утицаја на правну ваљаност уговора. Уговор није закључен између непостојећег привредног субјекта на страни повериоца, како се то жалбом указује, већ од стране правног следбеника брисаног субјекта, који је сходно чл.505. Закона о привредним друштвима, као друштво стицалац, преузео сва права и обавезе припојеног привредног друштва, па сама околност да је коришћењем формуларног текста при изради уговора, начињена грешка у означању повериоца, при чињеници да је као поверилац у уговорном односу заиста иступао овде тужени, а што потврђује отисак печата на уговору, не може бити од утицаја на правну ваљаност уговора.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж бр. 4835/17 од 15.05.2018. год.)*

## ИЗМАКЛА КОРИСТ

(чл. 189. Закона о облигационим односима)

**Када суд досуди тужиоцу накнаду услед немогућности коришћења објекта на коме је настала штета, као последица учињених пропуста, таква накнада има карактер изгубљене добити, у смислу чл.219 ЗОО, а не ренте која је будућа штета.**

*Из образложења:*

Правноснажном пресудом Општинског суда у Л. тужена је обавезана на накнаду штете у виду измакле користи за 2004-2008.годину у обрачунатом износу за сваку годину понаособ и на исплату будуће штете у месечним износима од по 7.845,90 динара, која обавеза доспева од 1-ог до 5-ог у месецу за текући месец и која ће постојати све док не наступе околности које је мењају или укидају.

По поднетој тужби за измену овако досуђеног износа будуће штете - ренте, првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев којим је тужилац тражио да се измени напред наведена пресуда и тужена обавезе, на име накнаде штете пропуштањем користи због немогућности издавања локала, власништво тужиоца, који је оштећен кривицом тужене, а по основу правноснажно утврђене одговорности органа тужене, да на име будуће месечне ренте исплаћује износе од по 44.943,13 дин..

Првостепени суд је на основу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања, правилно применио материјално право када је закључио да је неоснован тужбени захтев тужиоца да се измени напред наведена правоснажна пресуда, у делу утврђене висине ренте.

Наиме, иако је тужиоцу правноснажном пресудом досуђена будућа штета, што би указивало на ренту, како је тужилац и поставио свој тужбени захтев, у конкретном случају нема основа за ренту. Рента као облик sukcesивне накнаде штете у будућности прописана је чл. 188 ЗОО, а иста се досуђује у случају смрти, телесне повреде или оштећења здравља, доживотно или на одређено време. Рента има за циљ, да оштећеном лицу обезбеди накнаду новчаних средстава која су за оштећеног изостала, услед губитка издржавања или смањене или изгубљене могућности остваривања зараде, а што је конкретизовано одредбама чл. 194 и 195 ЗОО.

Правноснажно досуђени износ месечне будуће штете не може представљати ренту, с обзиром на то да је исти досуђен као последица учињених пропусти на објекту тужене, услед којих је настала штета на објекту тужиоца, те накнада на коју је тужиоцу признато право има карактер изгубљене добити, а не ренте.

У конкретном случају на страни тужиоца не постоје околности услед којих би се могло закључити да је његова ситуација доведена у неповољнији положај, имајући у виду да тужилац потражује исплату у виду ренте, да му је месечни износ будуће накнаде већ раније правноснажно досуђен и да за евентуално већу штету од досуђеног износа тужилац има адекватно средство-могућност

да принудно спроведе правноснажну пресуду у делу којом је туженој наложено отклањање узрока штете, чиме би се његова ситуација довела у исто стање како је било пре изазивања штете.

*(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. бр. 2676/17 од 09.01.2018.. године )  
Аутори сенценце: Зорица Стошић, судија Апелационог суда  
у Нишу са судијским помоћником Иваном Стевановић*

## **ОДГОВОРНОСТ МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА ПРЕМА КОМЕ ЈЕ ПРОПУШТЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ МЕНИЦЕ НА ИСПЛАТУ**

(чл.37. ст.1. и чл.52. ст.1. Закона о меници)

Када тужена није дужник по закљученом уговору о коришћењу позајмице, нити по основу уговора о јемству, већ менични дужник према коме је пропуштен рок за подношење менице на исплату, из чл.37. ст.1. Закона о меници, то иста није одговорна за дуг туженог М. према тужиоцу, сходно чл.52. ст.1. Закона о меници.

### ***Из образложења:***

Одредбом чл.37. ст.1. Закона о меници. предвиђено је да меница платива на одређени дан или на одређено време после издања или виђења, мора се поднети на исплату било на сам дан плаћања било једног од два радна дана који долазе одмах за њим, док чл. 42. Закона о меници прописује да ималац менице може вршити регрес против индосаната, трасанта и осталих обвезника о доспелости, ако меница није плаћена у целости или делимично. Чланом 52. ст.1. истог закона предвиђено је да са протеком рокова за подношење на исплату менице која садржи одредбе „без протеста“ ималац менице губи своја права против индосаната, против трасанта и против осталих обвезника, изузев акцептанта.

Из цитираних законских одредби произилази да менични поверилац има обавезу да о доспелости поднесе меницу на исплату, те да уколико то не учини на дан доспелости или у два наредна дана, губи право на исплату меничног износа од свих споредних меничних дужника. У конкретном случају, тужена Г.П. је меницу потписала као трасант и истом се обавезала „без протеста“ да попуњени износ од 1.058.299,36 динара у меници уплати о доспелости, из чега

произилази да иста има положај споредног меничног дужника. Подношење менице на исплату меничном дужнику у роковима предвиђеним чл., 52. ст.1. Закона о меници представља посебну обавезу, меничну радњу, која се предузима пре покретања судског поступка и повлачи последице у погледу саме могућности реализације потраживања у поступку наплате меничног потраживања. Стога је тужилац као ималац менице био дужан да по доспелости плаћања претходно, у прописаном року меницу поднесе на исплату туженима као меничним дужницима. Како је тужилац пропустио да предузме ову меничну радњу тј. меницу је попунио 14.05.2014. године а тек 24.06.2014. године поднео предлог за извршење, меница је постала прејудиицирана, што доводи до тога да се тужена Г.П. ослобађа обавезе по меници јер тужилац током поступка није доказао да је по доспелости 14.05.2014. године поднео меницу на наплату.

Обзиром да тужена Г. П. није дужник по закљученом уговору о коришћењу позајмице, нити по основу уговора о јемству, већ менични дужник, према коме је пропуштен рок за подношење менице на исплату, иста није одговорна за дуг туженог М. према тужиоцу, због чега је тужбени захтев према њој неоснован.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.1233/18 од 01.03.2018. године), аутор сентенце Мирјана Милутиновић, виши судијски сарадник Апелационог суда у Нишу*

## ПРАВО НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ (чл.560. ст.3. Закона о кривичном поступку)

**Тужилац нема право на накнаду нематеријалне штете због неоснованог лишења слободе, сходно чл.560. ст.3. ЗКП, у ситуацији када је својим недозвољеним поступцима проузроковао лишење слободе.**

### *Из образложења:*

Одредбом чл.560. ст.1. тач.1. ЗКП прописано је да право на наканду штете припада лицу које је било у притвору а није дошло до покретрања кривичног поступка, или је поступак обустављен правноснажним решењем, или је

правноснажном пресудом ослобођен од оптужбе, или је оптужба одбијена. Ставом 3 истог члана прописано је да накнада штете не припада лицу које је својим недовољеним поступцима проузроковало лишење слободе.

У конкретном случају је утврђено да је тужилац својим понашањем допринео лишењу слободе, јер није био доступан правосудним органима, иако је знао да се против њега води кривични поступак, није пронађен на адреси коју је суду пријавио, нити је пријавио промену адресе пребивалишта. Тужилац, саслушан као окривљени на седници већа одржаној дана 21.06.2012. године, је изјавио да није обавестио суд да иде у иностранство, да је био упознат да се против њега води кривични поступак, да је био у Ш. 9 месеци и да због тога сноси одговорност. Решењем Основног суда у Нишу Кв.бр.1248/12 од 21.06.2012.године остало је на снази решење тог суда о одређивању притвора Кв.бр.436/12 од 23.03.2012. године управо из разлога што су постојале околности да би окривљени, уколико би био пуштен на слободу, могао поново да се крије и бежи.

Правилно је првостепени суд закључио да тужилац нема право на накнаду тражене нематеријалне штете, сходно чл.560. ст.3. ЗКП, јер је својим недозвољеним поступцима проузроковао лишење слободе.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.2740/18 од 15.05.2018.године),  
аутор сентенце Мирјана Милутиновић, виши  
судијски сарадник Апелационог суда у Нишу*

## **ПРАВО СУВЛАСНИКА НА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ ОД СТРАНЕ ДРУГОГ СУВЛАСНИКА** (чл.210. и чл.219. Закона о облигационим односима)

**У пасивном понашању сувласника манифестује се воља да ствар не користи, тако да сувласник ствари који ствар не употребљава нема право на накнаду за коришћење исте ако понашање другог сувласника-држаоца није противправно.**

### ***Из образложења:***

Тужилца након престанка брачне заједнице, нити након доношења наведене делимичне пресуде којом је у коначном утврђен њен удео у предметним непокретностима, није предложила ни у судском поступку ни ван суда уређење



начина коришћења предметне непокретности, нити је тражила физичку деобу истих, то је првостепени суд правилно закључио да тужила није показала стварну и озбиљну вољу да користи свој сувласнички удео у спорним непокретностима. Осим тога, не произилази ни да је тужени на неки незаконит начин онемогућавао тужилу у коришћењу њеног сувласничког удела, већ је тужени предметну непокретност користио и користи за становање са њиховом заједничком децом, те је првостепени суд, имајући у виду начело савесности и поштења, правилно закључио да у конкретном случају нису испуњени услови чл.210. и 219. ЗОО, те да с тога тужила од туженог нема право захтевати накнаду за коришћење предметних непокретности у висини њеног удела у истима од износа укупне закупнине за утужени период.

У пасивном понашању сувласника манифестује се воља да ствар не користи, тако да сувласник ствари који ствар не употребљава нема право на накнаду за коришћење исте ако понашање другог сувласника-држаоца није противправно. Сходно наведеном, претпоставке за остварење права на накнаду за коришћење сувласничког удела јесу депоседираност сувласника недржаоца, његово активно понашање усмерено на остварење припадајућег права коришћења и противправно поступање сувласника који то онемогућава, које претпоставке морају бити кумулативно испуњење, а што у овој парници није случај.

*(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.4056/17 од 03.04.2018.године),  
аутор сентенце Мирјана Милутиновић, виши  
судијски сарадник Апелационог суда у Нишу.*

## НИШТАВОСТ СУДСКОГ ПОРАВНАЊА

Судско поравнање којим је уговорен поништај уговора о купопродаји који је закључен између парничних странака, под условом да једна уговорна страна из поравнања исплати другој одређени новчани износ, је апсолутно ништаво у смислу чл. 103. ЗОО јер је садржина предмета уговорне обавезе недопуштена у смислу чл. 49. ЗОО.

### *Из образложења:*

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је против туженог водио парнични поступак пред Основним судом у Прокупљу у предмету 6П. бр. 991/12, ради поништаја уговора о купопродаји. Парничне странке су у том поступку закључиле

судско поравнање на рочишту за главну расправу одржаном дана 14.03.2013. године. Закљученим судским поравнањем тужилац се обавезао да туженом до 15.03.2014. године исплати износ од 3000 евра у динарској противвредности по најповољнијем курсу по коме НБС откупљује ефективни страни новац, а да се након извршене исплате поништава уговор о купопродаји Ов. I бр. 10767/06 од 29.09.2006. године те да, уколико тужилац не исплати туженом 3000 евра у наведеном року, уговор о купопродаји Ов. I бр. 10767/06 од 29.09.2006. године остаје на снази. Постављеним тужбеним захтевом тужилац је тражио да се утврди да је ништаво поравнање закључено између парничних странака дана 14.03.2013. године, у поступку пред Основним судом у Прокупљу, у предмету 6П.бр. 991/12.

Судско поравнање дефинише се као специфична диспозитивна парнична радња и посебна врста уговора који парничне странке закључују пред судом, у циљу споразумног решавања спора и има снагу извршне исправе. Оно се, сходно одредби чл. 339. ст. 1. ЗПП може побијати само тужбом.

Првостепени суд је правилно закључио да обавеза уговорних страна која је дефинисана поравнањем, а која се односи на поништај уговора о купопродаји, закљученог између парничних странака, за случај исплате уговореног новчаног износа, не може зависити од диспозиције уговорних страна, те да се у конкретном случају ради о недозвољеном располагању странака из чл. 3. ст. 3. ЗПП, које суд не може дозволити, због чега је тужбени захтев тужиоца основан, па су испуњени услови за примену чл. 103. ст. 1. ЗОО у конкретном случају.

Ово и са разлога што и по оцени овог суда, суд неће дозволити поравнање странака ако је реч о захтевима којима странке не могу да располажу, у смислу чл. 336. ст. 4. ЗПП којим је прописано да пред судом не може да се закључи поравнање у погледу захтева којима странке не могу да располажу. Осим наведеног, и одредбом чл. 47. ЗОО, прописано је да је уговор ништав кад је предмет обавезе немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив, а одредбом чл. 49. истог закона, да је предмет обавезе недопуштен ако је противан принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима.

***(Пресуда Апелационог суда у Нишу 31Гж.  
бр.4834/2017 од 10.10.2018. године)***

***Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски  
сарадник Апелационог суда у Нишу***

## СТВАРНО ПРАВО

### УСМЕНО ОБАВЕШТЕЊЕ ИМАОЦА ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА (чл.7. Закона о промету непокретности)

Понуда учињена супротно чл.7. ст.2. Закона о промету непокретности, у конкретном случају усменим обавештењем од стране продавца, не може у смислу одредбе чл.6. и 7. ст.2. и 3. Закона о промету непокретности да представља тренутак сазнања имаоца права прече куповине за купопродају и чињеницу релеванту за оцену почетка тока субјективног рока за подношење тужбе због повреде права прече куповине.

#### *Из образложења:*

Субјективни рок за остваривање права прече куповине повређеног уговором о продаји непокретности тече од дана сазнања за продају непокретности. Власник који намерава да прода пољопривредно земљиште дужан је да га претходно понуди власнику суседног пољопривредног земљишта, сходно чл.6. Закона о промету непокретности, а сходно чл.7. ст.2. истог Закона понуда мора бити у писменој форми, а према ставу 3. истог члана, понуда се мора учинити препорученим писмом. Наведене законске одредбе су императивне природе и њиме се одређује формални карактер учињене понуде имаоцу права прече куповине. Понуда учињена на други начин, у конкретном случају усменим обавештењем од стране продавца, не може у смислу наведених законских одредби да представља тренутак сазнања имаоца права прече куповине за купопродају и чињеницу релеванту за оцену почетка тока субјективног рока за подношење тужбе због повреде права прече куповине. Сазнање за продају односи се не само на фактичку продају (закључење и оверу уговора) већ и на услове под којима је непокретност продата другом купцу, с обзиром да је тужилац у обавези да код подношења тужбе у депозит суда стави новчани износ у висини купопродајне цене.

*(Решење Апелационог суда у Нишу Гж.3848/18 од 13.09.2018.године),  
аутор сентенце Мирјана Милутиновић, виши  
судијски сарадник Апелационог суда у Нишу.*

## СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ОД НЕВЛАСНИКА Чл.31 ЗОСПО

**Од лица које је крађом стекло фактичку власт на ствари не може се стећи право својине у смислу одредбе чл.31 ЗОСПО чак и у ситуацији када је тужилац као купац био савестан.**

### *Из образложења:*

Првостепени суд је правилно утврдио да у конкретном случају тужиоци, по основу купопродаје од С.М., нису стекли право својине на трактору, сходно одредбама чл. 31. Закона о основама својинско правних односа, којим је прописано да савесно лице стиче право својине на покретну ствар, коју је прибавило уз накнаду од невласника, који у оквиру своје делатности ставља у промет такве ствари, од невласника коме је власник предао ствар у државину на основу правног посла који није основ за прибављање права својине, као и на јавној продаји.

Наиме, извршењем кривичног дела не може се стећи право својине на ствари која је прибављена на тај начин. Лице које је крађом стекло фактичку власт на ствари не представља невласника који у оквиру своје делатности ставља у промет такве ствари, нити је то невласник коме је власник предао ствар у државину, сходно цитираној законској одредби. Такође, лице које је украдо ствар на њој не може стећи својину ни по основу одржаја, право својине законитог власника ствари не застарева и он увек може остваривати право на њен повраћај. У конкретном случају трактор је од тужилаца одузет од стране надлежне полицијске управе, у чијој је надлежности трагање за учиниоцима кривичних дела, као и за стварима прибављеним кривичним делом. У оквиру тих надлежности полиција има право да одузме ствар прибављену кривичним делом од лица код кога се она буде затекла, као и да исту врати њеном власнику.

Из чињеничног стања је утврђено да је лице, од кога су тужиоци купили трактор, исти прибавило извршењем кривичног дела тешке крађе и да су фабрички идентификациони подаци – бројеви шасије и мотора фалсификовани пре продаје тужиоцима, а да је законити власник ММ из В...И..... Обзиром на наведено тужиоци нису могли стећи право својине на трактору и супротно жалбеним наводима њихова савесност није од утицаја на основаност тужбеног захтева. Они право на накнаду штете могу остварити једино према лицу од кога

су прибавили предметни трактор, али не и право својине у односу на РС – ПУ С..... како су то тражили тужбом.

*Пресуда Основног суда у Лесковцу П.бр. 1619/11 од 25.03.2015.године*

*Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж бр 529/2018 од 27.09.2018.године*

*Аутор сентенце: Добрила Здравковић, судија Апелационог суда у Нишу*

## ЈАЧИ ПРАВНИ ОСНОВ КОД СТИЦАЊА ПРАВА СВОЈИНЕ

(члан 41. Закона о основама својинскоправних односа)

Када се два лица сматрају претпостављеним власницима исте ствари, коју су стекли теретно, а ствар је у државини ранијег купца, ранији савесни купац има јачи правни основ у односу на каснијег несавесног купца, без обзира што је стицање каснијег купца извршено у судском поступку, будући да, осим код преображајних права, судска одлука производи правно дејство само између странака које у поступку учествују, због чега се правно дејство одлуке донете у извршном поступку по којој је предметни стан продат друготуженом, не протеже на тужиоца који није ни био учесник у извршном поступку.

### *Из образложења:*

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у својству купца закључио са туженим у својству продавца Уговор о купопродаји пословног простора, који је оверен пред Општинским судом у Нишу под Ов.бр.1118/09 дана 30.12.2009. године, којом приликом је тужилац у целости исплатио купопродајну цену друготуженом у износу од 31.000 еура, о чему је сачињена и писана потврда од стране друготуженог и објекат је истог дана предат тужиоцу у државину. Тужилац своје право својине на основу закљученог уговора није уписао код Службе за катастар непокретности, а као власник је уписан друготужени. Утврђено је да је предметни локал у извршном поступку који се водио пред Основним судом у Нишу против извршног дужника ГП „С“, друготуженог у овој правној ствари, а под И.бр.524/13, продат првотуженом Б. Д., који је на име купопродајне цене исплатио износ од 922.793,00 динара. Тужилац је у својству трећег лица у извршном поступку поднео захтев за от-

клањање неправилности и уз исти приложио Уговор о купопродаји локала и тражио да се укине решење о продаји непокретности предметног пословног простора, а решењем 1И.бр.524/13 од 29.01.2015.године утврђена је наведена неправилност и наложено судском извршитељу да исту исправи.

Одлучујући о основаности тужбеног захтева тужиоца као у ставу један и два изреке, првостепени суд није утврђивао испуњеност услова за примену одредбе чл.41 Закона о основама својинско правних односа, имајући у виду да је тужилац у овој правној ствари поднео тужбу по основу јачег права (публицијанску тужбу), у смислу наведеног члана.

Првостепени суд није утврдио да ли је тужилац право својине на предметном пословном простору прибавио по правном основу и на законит начин, обзиром да је закључењем уговора о купопродаји исти стекао правни основ, али у смислу чл.33 Закона о основама својинскоправних односа својину на том објекту није стекао уписом у јавну књигу или на други одговарајући начин, а купопродајну цену је исплатио у целости и од купопродаје се налази у непрекидној државини предметне непокретности.

Осим наведеног, изостали су разлози првостепеног суда и у погледу **савесности** тужених у конкретном случају. Ово с тога што првостепени суд није утврђивао ни ценио да ли је у току извршног поступка тужилац као треће лице упознао извршни суд о постојању Уговора о купопродаји између њега и друготуженог и није утврдио да ли је друготуженом према околностима случаја, било познато или не, да је спорно власништво на предметном локалу, те да ли је та околност била позната и првотуженом који је као лицитант локал купио, или не, односно да ли је првотуженом било познато да купује спорно право, а ако јесте да ли се исти изложио ризику губитка стечене ствари, без обзира што је **стицање извршено у судском поступку**. Ово са разлога што осим код преображајних права, судска одлука производи право дејство само између странака које у поступку учествују, па не делује према свима. Како у извршном поступку тужилац није био учесник, то се на њега не протеже правно дејство одлуке по којој је стан продат првотуженом.

***(Решење Апелационог суда у Нишу 21Гж.бр.3624/17 од 10.01.2018. године)***

***Аутор сентенце: Тијана Митровић, судијски сарадник Апелационог суда у Нишу***

## РАДНО ПРАВО

### ИСПЛАТА УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ

(чл.3. ст.1.тач.1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (“Службени гласник РС” бр.44/2001...113/17)

**Запослени који обавља послове и радне задатке наставника разредне наставе у издвојеном одељењу у забаченом планинском селу, има право на увећани коефицијент за обрачун и исплату плате од 8%, непосредном применом чл.3.ст.1.тач.1. Уредбе о коефицијентима за обрачун исплату плата запослених у јавним службама (“Службени гласник РС” бр.44/2001...113/17), уколико плата запосленом по том основу није увећана појединачним актом послодавца којом су утврђени елементи за обрачун и исплату плате чија законитост није оспоравана у интерном и судском поступку.**

#### *Из образложења:*

Тужилац ради на пословима и радним задацима наставника разредне наставе, са 100% радног врмеена у издвојеном одељењу у забаченом планинском селу, али му плата по том основу није увећана па тужбеним захтевом тражи да се утврди да има право на увећање коефицијента за обрачун плате по наведеном основу и да се тужена школа обавезе да тужиоцу исплати разлику од исплаћене плате до износа плате обрачунате на основу коефицијента који је увећан за 8%, у наведеним месечним износима, и са законском затезном каматом, уз обавезу да тужена на досуђене износе обрачуна и уплати прописане порезе и дприносе за социјално осигурање надлежним фондовима на те износе. У току поступка тужебна је доставила доказе- обавештење од Републичког завода Служба за катастар непокретности, којим је тужена школа обавешена да се издвојено одељење школе у коме тужилац ради налази на коти од 515 до 517 метара.

Одредбом чл.60. ст.1. Устава РС прописано је да се јемчи право на рад у складу са законом и да свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду,

ограничено радно врмее, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одомр, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа, односно да се нико тих права не може одрећи.

Одредбом чл.145. Закона о основма а система образовања и васпитања ("Сл. гл. РС" бр. 72/09...88/2017), ст.1. прописано је да на решења о остваривању права обавезе и одговорности запослени има право приговора органу управљања у року од 8 дана од дана достављања решења, а ст.2. истог члана да је орган управљања дужан да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања приговора, а ст.7. да ако орган упра не одлучи по приговору или ако запослени није задовољан првостепеном одлуком може да се обрати надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке.

Одредбом чл.3.ст.1тач.5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гл. РС" бр. 44/01...58/2014), прописано је да се коефицијенти утврђени из чл.2. Ове Уредбе увећају наставнику у забаченом планинским селима (забаченим планинским селом сматра село које се налази на надморској висини преко 500 м и удаљено је од главних путева најмање 5 км) за 8%.

Код овако утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени суд поступио када је усвојио тужбени захтев тужиоца, утврдио да тужиоцу припада право на увећани коефицијент по основу рада у забаченом планинском селу, и обавезао тужену на исплату наведеног увећања, по месецима и у износима како је то утврђено налазом и мишљењем вештака, са обавезом на уплату доприноса за социјално осигурање надлежним фондовима на те износе, позивајући се на одредбе чл.3. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Без значаја је чињеница да тужилац није подносио приговор школском одбору у остављеном року против првостепеног решења којим је утврђен његов статус односно плата без наведеног увећања. Уредба тачно одређује услове потребно за остваривање права на увећање и висини тог увећања, и само постојање права зависи од испуњености прописаних услова и не постоји потреба за вођење посебног поступка ради утврђивања износа увећања. Дакле, не ради се о дискреционом праву послодавца јер је послодавац овлашћен да констатује елементе по основу којих се увећава



и утврђује плата, и није му ни стављено у надлежност да одлучује о томе, јер само постојање права зависи и од испуњености прописаних услова, и послодавац доноси деклараторну одлуку. Права на зараду за обављени рад је најважније имовинско право за запослено лице, због чега у потпуности протеже приватно правни елемент над јавно правним елементом у радном односу, па самим наведено право ужива директно судску заштиту, како је то правилно поступио и првостепени суд.

*(Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу  
Гж1.3715/2016 од 15.01.2018. године, утврђена на седници  
Одељења за радне спорове 20.07.2018. године)*

### ИСПЛАТА УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ НОЋНОГ РАДА

Када је уговором о раду или оштим актом послодавца (колективним уговором код послодавца или правилником о раду) предвиђено је да ноћни рад вредно при утврђивању основне зараде, запослени коме је обрачуната и исплаћена зарада у висини минималне зараде, запослени коме је обрачуната и исплаћена зарада у висини минималне зараде има право на увећање зараде за рад ноћу на основу чл.108. ст.1. тач.2. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005... 75/2014).

#### *Из образложења:*

Тужбом тужиоци између осталог траже исплату увећане зараде по основу ноћног рада. Правилником о раду код послодавца прописано је да је ноћни рад урачунат у основну зараду, а запосленима је исплаћивана зарада у висини минималне зараде. Према подацима из обрачунатих листи тужени није вршио обрачун зараде са увећањем на име ноћног рада. Уговорима о раду тужиоцима је утврђена основна зарада у висини од 121,00 динара по сату рада, што према налазу вештака представља минималну зараду у том периоду. Вештак је извршио обрачун увећане зараде на име ноћног рада тужилаца.

Запосленима је законом загарантована исплата минималне зараде (одредба чл.111. Закона о раду). Чл.108. Закона о раду прописано је да запослени има право на увећању зараду утврђеној општим актом и уговором о раду за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде, најмање 26% од основице,.

Зарада која у себи садржи увећање по основу ноћног рада, иста не може бити изједначена са минималном зарадом.

Стога, уколико је послодавац прописао да је ноћни рад вреднован при утврђивању основне зараде или је то наведено у уговору о раду, основна зарада у том случају не може бити изједначена са минималном зарадом, јер иста у том случају мора бити већа од минималне зараде по основу вредновања ноћног рада. Дакле, суд мора да разјасни да ли у случају када је запосленима исплаћивана зарада у висини минималне зараде, иако је Правилником о раду код туженог прописано између осталог да је ноћни рад урачунат у основну зараду, таква зарада у себи уопште садржи увећање по основу ноћног рада, јер од тога зависи и да ли запосленом у том случају припада увећана зарада по основу ноћног рада у износу како је то Законом о раду прописано.

***(Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу  
Гж1.1567/2017 од 24.05.2018. године, утврђена на седници  
Одељења за радне спорове 20.07.2018. године).***





**Pravna i ekonomska izdanja**  
za uspešno i zakonito poslovanje

---

[www.paragraf.rs](http://www.paragraf.rs)